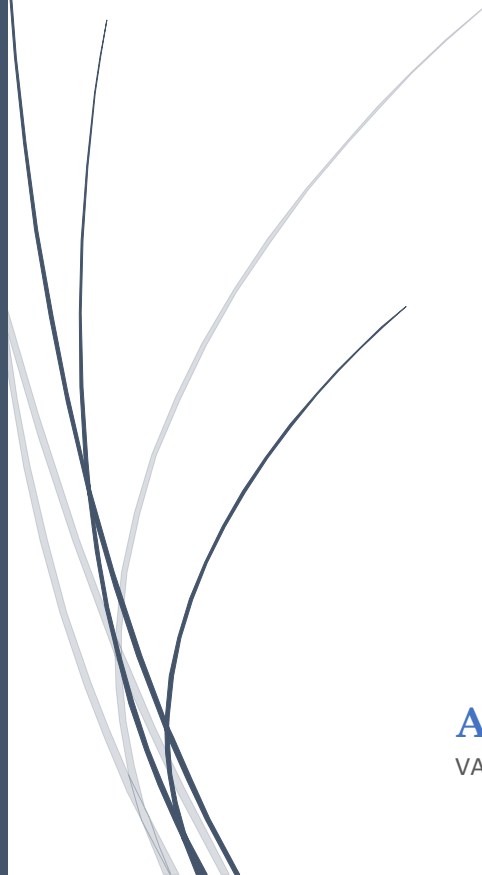




SEGUNDO SEMESTRE  
2018

# Derecho de Sociedades

Roberto Ríos



**Ariel Urzúa de la Barra**

VAGRANT

Martes 7 de agosto de 2018

# I.

## INTRODUCCIÓN Y FECHAS

- 12 de octubre, solemne escrita
- TBL (asistencia obligatoria) 25 de septiembre y 9 de octubre
- Trabajo en equipo: 6, 7 y 8 de noviembre
- Examen oral: 28 de noviembre
- 4 de octubre: clase de profesores extranjeros (discípulo de Garrigues).

### Bibliografía:

- Manual de Guerrero Zegers
- Libro de profesora Fernanda Vásquez (cuadros comparativos)
- Juan Esteban Puga, materia de sociedades anónimas
- Curso de Derecho Económico tomo II de Jequier

Un tema relevante que le gusta al profesor es **la discrecionalidad**. En materia de sociedades, existen sociedades anónimas abiertas o cotizadas (como se les dice en ordenamientos internacionales) que están sujetas a la supervigilancia o control de la autoridad. Hoy en día, la **Comisión para el Mercado Financiero**, en ciertos tipos de sociedades ejerce control, actúan con criterios de discrecionalidad en algunos casos.

**El derecho de sociedades hoy en día no es solo derecho privado.** Hay una relación constante y una conexión cada vez más profunda entre el derecho privado que rige a las sociedades y el derecho público. Esto está dado porque hay una serie de sociedades que en el ejercicio o en el desarrollo de su giro, están sujetas a un mecanismo de supervisión y control de órganos especiales que ha creado el legislador. Destacamos **la Comisión para el Mercado Financiero (que sustituyó hace muy poco a la Superintendencia de Valores y Seguros por la ley 21.000)**. Asimismo, existen otros órganos que regulan estos sectores, como la superintendencia de bancos e instituciones financieras. La superintendencia debe dejar de existir ya que se va a integrar a la comisión para el mercado financiero. *Esta comisión es un ente regulador, controlador y colegiado que se va a encargar de supervisar la actividad asociada al mercado de valores y seguros, de finanzas y de la banca.*

Hay otros órganos que controlan otro tipo de sociedades, como la superintendencia, de Isapres y lo mismo con las AFPS. Es importante la visión que podemos ver respecto del derecho público en cuanto a la actividad de sociedades. **En la Constitución Política de la República también se encuentra una regulación de las sociedades:**

**Sobre normas de carácter constitucional, se han desarrollado principios por la doctrina, como a partir del artículo 19 N° 21 de la libre iniciativa económica, o del artículo 19 N° 22 en cuanto a la no discriminación en materia económica.** Por otro lado, existe un principio que se ha desarrollado en el ámbito constitucional, es el tratamiento del principio de subsidiariedad. Esto tiene importancia, ya que la garantía de libertad económica y el principio de subsidiariedad, quiere decir que, por regla general, la actividad mercantil está reservadas a los privados, lo que no quiere decir que el Estado no intervenga en actividades mercantiles (el estado interviene claramente). Ejemplos de participación

son empresas como: Correos de Chile, Metro. Generalmente lo hace a través de leyes especiales y lo hace porque el legislador estima que el interés público y la necesidad de satisfacer ciertos requerimientos que están vinculados con el interés público y el bien común en general, justificarían la intervención del Estado en ciertas actividades mercantiles. **Lo importante es que la intervención estatal hoy en día, bajo el manto de la Constitución de 1980, debe ajustarse a ciertos criterios de igualdad, especialmente igualdad ante la ley.** La regla general, es que cuando las empresas del estado ejecutan una actividad mercantil (a diferencia de la Constitución de 1925) no tiene privilegios. Antes de la Constitución de 1980, algunas empresas del Estado tenían privilegios en cuanto a su forma de constitución, en cuanto al ámbito tributario, etc. **En cambio, en la Constitución de 1980, las empresas del Estado deben regirse por las mismas normas a las que están sujetos los privados.**

En el curso anterior, nosotros abordamos el concepto de comerciante y las razones de por qué nos preocupamos de este concepto. Criticamos la teoría objetiva del acto de comercio, resaltando teorías como la de la empresa y su titular: el empresario.

En este curso, lo que tenemos que tener en cuenta, es abordar y determinar de **qué forma** el empresario o el comerciante actúa, desarrolla su giro en el tráfico. En el derecho de sociedades, se apunta a eso. ¿De qué manera se viste el comerciante? Eso, se denomina **tipología societaria**.

**¿Por qué es relevante escoger como se viste el titular de la empresa?** R: por impuestos, por legislación aplicable.

Hay distintos tipos de sociedades: civiles y mercantiles. Dentro de las comerciales, hay sociedades colectivas, en comanditas (simples y por acciones), sociedades de responsabilidad limitada (civiles o mercantiles), sociedades anónimas (abiertas –que se cotizan en bolsa-, cerradas –no se cotizan en bolsa- y especiales). No obstante, el factor asociativo, que es el que predominaría, hoy en día hay sociedades unipersonales. Hay otras formas que el legislador ha previsto para que los privados puedan desarrollar el área comercial sin constituirse como una sociedad, como la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL). Hay una gran gama de opciones que nos permiten desarrollar actividades mercantiles.

La gran pregunta de todo esto es **¿Por qué este emprendimiento debe ser realizado más óptimamente de tal forma?** R: las razones son las siguientes:

- a) **Por la limitación de responsabilidad (+ importante):** cuando escogemos una forma o nos vestimos de una determinada manera, en general lo hacemos porque queremos ejecutar un negocio –incorporarse al mercado-, sin comprometer su patrimonio personal. Si hoy en día quiero desarrollar un negocio y me convence un joven emprendedor de adentrarnos al desarrollo tecnológico. ¿Estoy dispuesto a comprometer mi patrimonio personal para el desarrollo de este negocio? R: la respuesta puede ser: no, no estoy dispuesto. A través de los mecanismos o las formas de vestirse del comerciante o empresario, lo que se hace es limitar su responsabilidad patrimonial.

No todas las figuras societarias o societarias entregan o me garantizan esta limitación de responsabilidad. Hay algunas que no, otras que sí en menor o mayor grado.

- b) **Por la forma en cómo se constituyen estas sociedades:** hay sistemas de constitución simplificada de sociedades que agregó el legislador por recomendación de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Hay otras sociedades que requieren o tienen requisitos para su constitución: escritura pública, escritura pública e inscripción de un extracto en el registro de comercio e incluso hay algunas sociedades que requieren de la autorización autoridad que va a supervigilar, controlar y fiscalizar el ejercicio de esa sociedad.
- c) **Por mecanismos y sistemas de administración de la sociedad:** cada tipo societario tiene mecanismos o sistemas de administración diferentes:
- Hay sociedades que ejecutan su giro a través de un administrador unipersonal (gerente o factor de comercio)
  - Hay otras sociedades en que la administración recae en órganos colegiados.
  - Cuando desarrollemos el contenido del curso veremos que además en materia de administración, hay ciertas sociedades que deben cumplir con un nivel de administración bastante rígido, porque la ley establece que la administración de esas sociedades debe llevarse de esa manera.
  - Y hay otros tipos de sociedades como las SPA donde el legislador le ha entregado la determinación de la administración de la sociedad al principio de la autonomía de la voluntad, es decir deja libertad en cuanto a la forma en la que se estructura la administración en esa sociedad.
- d) **Si esas sociedades en concreto, está sujeta o no a un control o supervisión de un órgano estatal:** hay sociedades que no están sujetas a control y otras que si están sujetas a control o fiscalización de un órgano estatal específico. **¿Por qué el legislador estima que hay ciertos tipos de entidades que están sujetos a control o fiscalización?** R: porque hay giros en donde está más comprometido el interés público. Además, estas sociedades obtienen recursos del público (acciones), es decir, hay una serie de personas (mayoritarios y minoritarios) que se ven afectadas por todas las decisiones que pueda tomar el administrador de esa sociedad. Por lo que lo que lo hace el legislador con estos órganos de control es controlar y verificar que, en el desarrollo del giro de esa sociedad, **el interés social que está conformado por todos los accionistas, no se vean perjudicados unos en favor de otros**. Por otra parte, hay otro tipo de sociedades que ejercen actividades donde el interés público está comprometido o sociedades que para que puedan conformarse deben cumplir con ciertas regulaciones establecidas por el legislador (por ejemplo, el capital mínimo de un banco o una empresa de seguro). Esto se da fundamentalmente porque son giros en los que esa empresa debe responder a terceros con pagos concretos por daños sufridos.

Estas son las razones por las que se exige en ciertos casos autorización especial de un órgano en concreto. **Estos son las razones por las cuales es necesario o es importante entender la problemática societaria y la tipología societaria.** Esta tipología está vinculada fundamentalmente con un concepto asociativo o de agrupación que la doctrina ha identificado en el empresario o comerciante colectivo. Este empresario o comerciante colectivo puede ser con personalidad jurídica o sin esta última. La personalidad jurídica es aquella que permite separar o dividir a los miembros de este acuerdo asociativo de la entidad que se crea.

**Pregunta de prueba:** En este sentido hay un artículo 2053 del Código Civil (memoria); a todos los alumnos se les preguntará **¿Qué es la sociedad?**

Art. 2053. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan.

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados.

**Este es el concepto base del sistema societario chileno.** Cuando aprendemos de memoria el concepto legal, ya podemos decir “pasé”. Una vez que sabemos el concepto legal, podemos desprender los elementos.

El legislador nomina ciertas figuras contractuales y a raíz de esto se pueden desprender elementos de la esencia, de la naturaleza y los accidentales. Pero los importantes son los de la esencia, que pueden ser comunes o generales: voluntad, objeto y causa (a los que se agregan las solemnidades).

**IMPORTANTE:** Cuando el legislador nomina un contrato, le da un nombre y lo define ¿Qué elementos esenciales podemos identificar en esa definición? R: los elementos específicos o especiales de ese contrato.

Por ejemplo, en el caso de las solemnidades, se identifica una forma de exteriorizar la voluntad. Cuando se constituye una sociedad por escritura pública, la voluntad de los socios está en la escritura pública. El legislador quiere tener certeza indubitada a través de la escritura pública en la que este contenida la manifestación de voluntad de los socios que concurrieron a la constitución de esa sociedad.

---

Martes 8 de agosto de 2018

## II.

# INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SOCIEDADES

Nos adentraremos al problema del empresario y al derecho de sociedades. Analizaremos:

### 1. EL COMERCIANTE COLECTIVO

#### 1.1. El comerciante y la empresa como objeto del estudio del derecho mercantil.

El concepto de comerciante ha sido criticado por la doctrina en relación al acto de comercio y se ha intentado introducir desde este punto, el concepto de empresa.

**El comerciante colectivo o empresario, tiene la particularidad de que ha adoptado una forma concreta para desarrollar el objeto o giro comercial al que se quiere dedicar.** Esto se da por la insuficiencia del sistema individual y personal. Las sociedades surgen porque el desarrollo de la actividad mercantil que realizaba el comerciante desde el punto de vista individual, tenía una serie de desventajas. Esto estaba vinculado **al compromiso del patrimonio personal** del comerciante en el desarrollo de la actividad y además a la **limitación económica del patrimonio del comerciante**. La limitación económica del patrimonio del comerciante, impide el desarrollo o el crecimiento exponencial del negocio del comerciante.

**La historia nos demuestra que los sistemas asociativos nos sirven para resolver todo lo anterior,** porque a través de un sistema asociativo son varios los que ejecutan o efectúan un aporte para desarrollar el giro social que acordaron desarrollar. Por otra parte, cuando se opta por una forma asociativa, generalmente la historia demuestra que ese mecanismo permite obtener mayores recursos del público o financiamiento bancario. Por esto el empresario individual que no separa su actividad personal de la mercantil, va quedando atrás en este sistema de carácter asociativo, siendo reemplazado por este último.

Existen diversas formas o mecanismos asociativos, la doctrina ha distinguido algunos mecanismos con y otros sin personalidad jurídica. **La sociedad como concepto liberal se caracteriza por considerarse como un instrumento asociativo CON personalidad jurídica.**

Sin perjuicio de lo que se ha señalado, han surgido en los últimos años, ciertas figuras que no son de carácter asociativo, pero que permitirían al comerciante actuar en el tráfico, separando su personalidad, responsabilidad y patrimonio personal, del giro que pretende ejecutar en el tráfico. En ese caso tenemos dos ejemplos claros, concretos y específicos:

- **La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (regida en la ley 18.957):**
- **La sociedad por acciones, que puede estar conformada por una sola persona (art. 424 y siguientes del Código Civil):**

Estas sociedades constituyen una forma que permite crear una empresa y esa empresa tiene una personalidad jurídica. **Se produce una separación entre el individuo personal (y todos los atributos**

**de la personalidad:** nombre, domicilio, patrimonio, estado civil y capacidad) **de la empresa.** Cuando asumimos una forma con personalidad jurídica propia, hay dos elementos que podemos concluir:

- Hay una separación del patrimonio de esa entidad respecto de quien la conformó.
- Manifiesta su voluntad de una forma independiente de quien la conformó

Hoy en día el factor asociativo tiene supuestos que han sido reemplazados por estas dos figuras. Si revisamos la doctrina reciente de los últimos 10 años hacia atrás, que hace referencia al predominio del factor asociativo y la forma en como se la empresa se desarrolla, esto ha ido quedando atrás. Muchos utilizan la forma de la sociedad de responsabilidad limitada. Hoy la gran mayoría actúa por el mecanismo de las EIRL y las SPA. Incluso la EIRL ha sido reemplazado por las SPA. Pero claramente, para todos los objetivos de emprendimiento las empresas **startup** han sido fundamentales. Las empresas startup son iniciativas de emprendimiento vinculadas al aumento de la tecnología. El desarrollo de las actividades económica ha estado cada vez más vinculado a la tecnología. Crear empresas de prestación de servicios o intercambio de bienes, a través de soportes electrónicos o virtuales.

**La OCDE ha recomendado a los estados miembros que incorpore en los ordenamientos jurídicos, mecanismos que permitan facilitar este emprendimiento.** Se han creado estas iniciativas (EIRL, luego las SPA y veremos más adelante que también existen mecanismos de constitución de sociedades simplificado).

Por esta razón, hoy en día, el fenómeno asociativo vinculado al contrato, ha sido objeto de crítica y la doctrina está intentando descubrir que naturaleza jurídica se le puede dar a la EIRL y a la SPA. Tiene origen convencional, pero no un contrato. Los contratos requieren de dos voluntades, por eso no pueden estas últimas ser un contrato, estas se clasifican en el caso de la EIRL en actos unilaterales (pregunta de examen)

### **1.2. Empresa individual de responsabilidad limitada o EIRL (Paréntesis MUY IMPORTANTE)**

EIRL como instrumento de solución a la problemática del empresario personal e individual. Regulada en la ley 19.857 (solo tiene 18 artículos).

#### **a) Concepto de las EIRL**

**Artículo 2 de la ley. (memoria)** *La empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica con patrimonio propio distinto al de su titular. Es siempre comercial y está sometida al Código de Comercio cualquiera sea su objeto (es decir, aunque sea de objeto civil se registrará siempre por las leyes mercantiles. Siempre las sociedades de responsabilidad limitada y las anónimas se rigen por las normas mercantiles, son siempre mercantiles, aunque tengan giro civil). Podrá realizar toda clase de operaciones civiles o comerciales, excepto las reservadas por la ley a las sociedades anónimas.*

#### **b) Constitución de una EIRL**

Es solemne, se constituye por escritura pública y la escritura pública debe contener las menciones y presupuestos del artículo 4 y 5 de la ley (no es necesario saberse cuales son los supuestos, para eso está la ley).

---

c) Características

- Es una persona jurídica (con todos sus atributos).
- Es mercantil
- No es una sociedad
- Es solemne

d) Clasificación

La doctrina ha derivado una clasificación:

- Originaria: la que nace del artículo 2.
- Derivada: nace de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley: “En el caso de que se produzca la reunión en manos de una sola persona, de acciones, derechos o participaciones en el capital de cualquier sociedad, por regla general **esa es una de las causales de terminación de una sociedad, sin embargo, el artículo 14 de la ley de la EIRL, dice que esa sociedad conformada por varios individuos, pero que uno de ellos tiene los derechos sociales, acciones, etc. en su patrimonio, se puede transformar en una EIRL cumpliendo su propietario con las reglas de constitución que establece la ley.**

Dato: no es lo mismo EIRL con sociedad de responsabilidad limitada, que es asociativa (requiere de la reunión de dos o más personas). No hay limitación en cuanto a la transformación de una sociedad, cualquiera que sea, en EIRL. **Salvo, respecto de las sociedades anónimas abiertas, ya que tienen una cierta complejidad: se conforman de forma especial, deben incorporar sus acciones a un registro especial (mercado regulador en materia accionaria).** Una sociedad anónima cerrada podría transformarse en EIRL

Caso: Si llega una persona a consultarnos, que tiene una sociedad determinada y nos dice “mire, me están ofreciendo mis socios venderme su participación”. Con esa venta, se produciría la reunión de todos los derechos en un solo socio, por lo que terminaría la sociedad. Tampoco quiere buscarse un socio. **¿Por qué le recomendaríamos la figura de la EIRL?** Es mejor que se conforme una EIRL porque de esta manera, su patrimonio personal, queda separado del riesgo de la actividad mercantil. Por eso nacieron las sociedades y existen estos instrumentos.

e) Administración de una EIRL

**Artículo 9.** Por regla general el titular de la empresa administra, sin embargo, podría recurrir a alguna figura de administración como el gerente o los factores de comercio (auxiliares del comerciante).

f) Término

La EIRL termina por las causales enumeradas en el **artículo 15**, esto es, por:

- **La voluntad del titular de la EIRL**

- **Por el cumplimiento o vencimiento del plazo, que yo fijé en el acto constitutivo de la EIRL,** para los efectos de establecer la duración de la empresa.
- **Cuando yo aporte el capital de la EIRL a una sociedad.** Ya no se quiere seguir con esta estructura individualizada con personalidad jurídica, sino que se quiere acoger a un sistema asociativo. Este capital es aportado a un tipo societario.
- **Por dictarse una resolución de liquidación (procedimiento de liquidación forzosa)**
- **Por muerte del titular:** los herederos podrán designar un gerente común para administrar la empresa hasta un plazo de 1 años, luego de este terminará la responsabilidad limitada, por lo tanto, todos los bienes de la EIRL pasan al patrimonio personal de cada uno de los herederos. (Art. 15). Si se muere el titular, todo el activo de la empresa pasa a los herederos. Y si ellos continúan ejecutando el giro, responderán con su patrimonio personal de las obligaciones de la empresa.

**Dato:** una sociedad no puede constituir una EIRL, debe ser una persona natural.

La EIRL tiene una particularidad especial y tiene una forma a través de la cual el comerciante puede desarrollar una actividad mercantil.

## **2. COMPARACIÓN SOCIEDAD CON OTRAS FIGURAS ASOCIATIVAS**

### **2.1. Sociedad y comunidad**

Existen grandes diferencias entre ambas:

- La sociedad tiene personalidad jurídica, la comunidad no la tiene.
- La comunidad es un cuasicontrato.
- En la comunidad los comuneros actúan de común acuerdo o consuno. En cambio, en una sociedad va a depender del tipo de la sociedad.
- Existe un factor asociativo en la comunidad, pero este factor no siempre se da en las sociedades, porque puede haber sociedades de una persona.

### **2.2. Sociedad y cooperativa**

**Las cooperativas no son parte del curso, pero hay que tener en cuenta que son una figura asociativa con personalidad jurídica.** La gran diferencia entre una cooperativa y una sociedad, está radicada principalmente en el objeto. La cooperativa puede tener muchos objetos (no están predeterminados en la ley, sino que la ley refiere un objeto genérico, que está vinculado al fin por el cual fue constituida y que la ley la enuncia como **ayuda mutua**). **Es un sistema asociativo en donde varias personas se reúnen con un objeto determinado para ayuda mutua.** Esta ayuda mutua puede no estar destinada necesariamente a ser lucrativa, como **ocurre SIEMPRE SIEMPRE SIEMPRE en una sociedad.**

## **3. ANÁLISIS HISTÓRICO**

- a) Las sociedades nacen en la edad media, en periodos antiguos o en roma no hay o no se reconoce la sociedad como la conocemos hoy en día, no había personalidad jurídica propia. Si existían sistemas asociativos de una o más personas, pero no sociedades como tal. En el derecho romano

---

post- clásico y clásico, no está reconocida la sociedad, solamente otros conceptos asociativos sin personalidad.

- b) En la edad media hay dos figuras que nos acercan a esta figura de sociedad como la comprendemos hoy en día:
- **La comanda es un acuerdo en virtud del cual una de las partes aporta un capital para el desarrollo de un negocio concreto y el otro se encarga de ejecutarlo o gestionarlo.** Hay un aporte de un individuo (capital o dinero o mercadería) y otro que aporta de su trabajo (que gestiona ese negocio en particular)
  - **Luego surge la figura de la compañía** que se va a acercando a una entidad asociativa con personalidad jurídica propia y que constituye el origen de las sociedades colectivas civiles y mercantiles. Aquí ya no hay una distinción entre el que aporta el capital y el que ejecuta o administra el negocio, **sino que son distintas personas que se ponen de acuerdo para ejecutar un giro en común, pero que responden solidariamente e incluso con sus bienes propios de las deudas sociales.**

Estas sociedades o gérmenes de sociedades, tenían la particularidad de ser sociedades personalistas, es decir, que yo celebro ejecutar un negocio en virtud de la confianza que me entrega o que me da una persona, en razón de la calidad del individuo. Dependían del individuo, eran intuitu personae.

- c) **En el siglo XVII nacen las sociedades de capital.** Estas sociedades a diferencia de las de personas, se basan en la ejecución de negocios de gran envergadura, que requieren de la captación de gran capital para la ejecución de ese negocio. Los holandeses crean estas sociedades para el desempeño de grandes proyectos de exploración a principios del siglo XVII. Ellos presentaban un proyecto y buscaban los aportes de aquellos que querían participar en la expedición de dinero (de esta forma se financiaban). Ahora lo que importa no es la persona, sino el capital. La persona deja de ser relevante para la conformación de la sociedad, sino que pasa a ser el capital.
- d) **A fines del siglo XIX surgirán otro tipo de sociedades, que son sociedades de personas,** pero que o en las que la responsabilidad de los socios, **por regla general quedará limitada a los aportes que efectúen.** Si yo pacto el aporte por determinado dinero, mi responsabilidad estará limitada a este. Estas **son las sociedades de responsabilidad limitada** que nacen en Alemania, a fines del siglo XIX.
- e) Hoy en día, todo funciona bajo el mismo concepto. Cuando hay un proyecto de gran envergadura, se utiliza esta estructura de capital (a través de sociedades que se abren a la bolsa, por ejemplo). **Hoy en día, por lo que involucra la inversión, hay ciertas actividades desarrolladas solo por sociedades anónimas que deben cumplir ciertos requisitos específicos.** Esta problemática es exactamente lo que ocurre hoy en día.

Hoy en día han nacido ciertas figuras que son **sociedades unipersonales**, que están destinadas a negocios de baja envergadura o a emprendimientos. O las llamadas sociedades por acciones, donde el factor asociativo claramente queda desplazado. Estas están definidas en el artículo 424 del Código de Comercio:

Artículo 424.- La sociedad por acciones, o simplemente la "sociedad" para los efectos de este Párrafo, es una **persona jurídica** creada por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado de acuerdo con los preceptos siguientes, cuya participación en el capital es representada por acciones.

## V/S

Art. 2053. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan.

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados.

El artículo 424 define a la sociedad por acciones como una persona jurídica, en cambio el 2053 del Código Civil establece que la sociedad en general es un contrato. **¿Por qué el artículo 424 no califica a la sociedad por acciones como un contrato?** R: porque un contrato requiere de un acuerdo de dos o más voluntades, cosa que no siempre ocurre en una sociedad por acciones. La SPA es **una persona jurídica** y el legislador parece que acertó al alejarse del concepto del 2053, porque si una sociedad por acciones es constituida por una persona, no puede ser un contrato.

#### 4. VENTAJAS DEL SISTEMA SOCIETARIO

¿Por qué constituir una sociedad? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué daría el paso a constituir una sociedad y reunirme con otras personas?

Las razones que ha dado la doctrina, son las enunciadas:

- (+ importante) **La posibilidad entre varios de reunir capital para darle viabilidad al negocio que se quiere desarrollar.** Las empresas exigen comúnmente de capital que es difícil o inconveniente que lo suministre una persona. Los comerciantes se asocian y reúnen los fondos necesarios para el desarrollo del negocio objeto de la sociedad. Es la empresa colectiva la que da origen a la sociedad.
- **Además, la estructura empresarial societaria es mejor bienvenida en el sistema financiero.** Para pedirle dinero a un banco, por ejemplo. Cuando este último pida garantías, es mucho más fácil otorgárselas si se está en sociedad y de esta manera no se compromete el patrimonio personal más importante.
- **La empresa debe adoptar una forma jurídica típica o al menos, que al menos, no se encuentre prohibida por el derecho.** Estas formas, no solo tienen la particular misión de ser el condicionante de juridicidad de la actividad empresarial, sino que delimitan las relaciones del empresario con terceros quienes contratarán con la empresa, clientes y proveedores. Particularmente relevante, el concepto de tercero comprende al fisco, toda vez que la generación de riqueza inevitablemente producirá la verificación de hechos gravados que desencadenarán sucesivas pretensiones fiscales de orden impositivo.

- **Ventajas tributarias y fiscales y también algunas ventajas de carácter laboral.**
- **Cuando aumentan las exigencias financieras y/u organizativas, las sociedades están llamadas a satisfacer las necesidades de asociatividad y de distribución del resultado económico.**
- **Separación patrimonial y responsabilidad**
- **Acumulación de capitales**

## 5. MARCO REGULATORIO EN CHILE

- **Código Civil:** 2053 y siguientes. 1545 y siguientes. Normas de vicios del consentimiento y eficacia estructural del contrato.
- **Código de Comercio:** Normas de formación del consentimiento.
- **Leyes especiales**
- **Ley 3.918** Sociedades de responsabilidad limitada
- **Ley 18.045** Ley de mercado de valores
- **Ley 18.046** Ley de sociedades anónimas y su reglamento
- **DFL 251** bolsas de comercio y compañías de seguros
- **DFL N° 3** (ley de bancos)
- **Normativa dictada por los órganos de supervisión**

•  
Martes 14 de agosto de 2018

## 6. CONCEPTO Y ELEMENTOS

### 6.1. Concepto

El legislador chileno recogió una definición de sociedad en el artículo 2053 del Código Civil.

Art. 2053. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan.

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados.

La doctrina nacional ha señalado que esta definición tendría como su fuente el artículo 1838 del Código civil francés del año 1807, no obstante, la gran diferencia que existiría entre esa y esta definición, es que Bello incorpora un segundo inciso en el artículo 2053 que podríamos calificarlo de innovador, ya que refiere a la sociedad como **una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados**. Este inciso no se encuentra en el código napoleónico.

Esto tiene mucha importancia, ya que, si comparamos derechos, se hace la distinción **entre sociedades con y sin personalidad jurídica**. Generalmente en estos ordenamientos (italianos y alemanes), las sociedades de personas no tienen la personalidad jurídica, no existe diferencia entre los socios individualmente considerados y el ente que nace, a diferencia de las de capital, en las que si se produce la división entre los socios individualmente considerados y este ente que nace.

En nuestro ordenamiento jurídico la sociedad tiene la particularidad de ser considerada una persona jurídica, podemos decir que el pacto de la sociedad da origen a un ente distinto de los socios individualmente considerados y esto se refleja en que se adquiere el estatuto de la personalidad jurídica.

Sin embargo, si revisamos otros conceptos de sociedades que con posterioridad al Código Civil se han ido incorporando en nuestro ordenamiento, como por ejemplo la definición de **sociedades por acciones del artículo 424 del Código de Comercio** o el **artículo primero de la ley 19.046 que regula las sociedades anónimas**, en estos casos el legislador entiende que la sociedad **es una persona jurídica y no la califica como contrato (como en el 2053 del CC)**. Este tipo de sociedades nace y se incorporan en nuestro ordenamiento en el siglo XX y las anónimas en el año 1981 con la nueva regulación. Además, el año 2007 se incorpora la regulación de la sociedad por acciones. Y las fuentes que vienen a regular estas sociedades no son fuentes francesas.

En materia de sociedades de capital, hay una especie de mezcla entre regímenes de tradición de derecho civil continental y una fuerte influencia de regímenes anglosajones (angloamericanos). Lo que señala la doctrina chile es que hay una ruptura en el concepto de sociedad que se introduce en nuestro ordenamiento. El artículo 424 es un gran ejemplo, ya que puede nacer una sociedad con la declaración de voluntad de un solo individuo.

En nuestra doctrina encontramos algunas opiniones de algunos autores, entre ellos **Juan Esteban PUGA**. Este autor es muy extremo y nunca está de acuerdo con la doctrina en general. Y señala: *“como somos herederos del Código francés de 1807, hemos perpetuado un error conceptual y reconocido en ese ordenamiento. Al analizar las sociedades anónimas, el Código chileno tiene un error conceptual, ya que visualizar las sociedades anónimas como sociedad, es un error”*. Esto lo señala porque el Código francés refería el termino sociedad anónima como una **asociación por cuentas en participación** y estas no son sociedades, sino un contrato asociativo que no se asimila al contrato de sociedad. No es un contrato que de origen a un ente distinto de los socios. Por lo tanto, existe un error desde el Código francés y, por tanto, es un error en nuestro ordenamiento.

**A la sociedad anónima actual, en la época del Código Civil napoleónico, no se le consideraba como una sociedad.** Por lo tanto, a juicio de este autor, en el caso de las sociedades anónimas, tienen una naturaleza distinta a las sociedades propiamente dichas. Esto tiene la siguiente razón: como la sociedad que se desprende del 2053 inciso primero y del artículo 1838 del código francés, es entendida como una sociedad intuitu personae, en el caso de las sociedades anónimas no se produce este fenómeno, ya que cuando se participa de un régimen de sociedades anónimas (principalmente las cotizadas), quienes adquieren acciones que se van incorporando pueden entrar y salir y no están apuntando necesariamente repartir entre sí los beneficios que provengan del giro societario. Realizan una gestión de carácter especulativa, para obtener beneficio que mira el interés individual más que el interés común o social. Estas son las críticas que se han ido incorporando al concepto de sociedad, ya que el artículo 2053 que contiene la definición en nuestro ordenamiento jurídico, se ha ido apartando de los regímenes asociativos que han nacido desde finales del siglo XIX y el siglo XX.

## 7. NATURALEZA JURÍDICA

Hay definiciones que entienden la sociedad como una organización que está vinculada a la empresa y a través de esta se organiza la empresa. En este contexto, hay fundamentalmente dos tesis que presenta la doctrina para explicar el concepto de sociedad:

- **La tesis contractualista** que está inspirada en el artículo 1838 del Código civil francés y a través de la cual la sociedad es entendida como un contrato o negocio jurídico que nace en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Es este principio de la autonomía de la voluntad, el que inicia y desarrolla esta sociedad. Si leemos los manuales que hacen referencia a esta tesis contractualista, nos damos cuenta que es una tesis difusa, es difícil comprender cuál es la línea divisoria entre esta y la siguiente teoría.
- **La tesis institucionalista:** Esta tesis que nace a principio del siglo XX a propósito de un autor alemán, postula que en materia de sociedades prima el interés común sobre el interés individual de los socios que integran el ente societario. Esta tesis que elabora la doctrina alemana, está vinculada a la superación del concepto de comerciante, la tesis de contratación en masa y la empresa como objeto central del derecho comercial.

**La gran diferencia de lo que postula la tesis contractualista e institucionalista está dada por el rol del principio de la autonomía de la voluntad dentro del derecho de sociedades.** La contractualista le entrega un rol fundamental a este principio, la institucionalista le entrega un rol inverso. Existe una serie de normas que hoy en día son de carácter imperativas e inamovibles por aquellos que pactan el contrato de sociedad. Por lo tanto, primaría esta estructura de orden público en una dimensión de interés público, respecto del principio de autonomía de la voluntad. De acuerdo a la teoría institucionalista, los regímenes societarios serían categorizados como medios flexibles que aquellos que están asociados a la tesis contractualista.

**¿Cómo aterrizamos estas distinciones doctrinales al ordenamiento chileno?** R: si revisamos los tipos de sociedades que existen en Chile, podemos encontrar casos en que el principio de autonomía de la voluntad tiene un rol preponderante en la constitución del ente societario y el cómo se organiza la sociedad (como se reparten utilidades, como administran, etc.) y hay otros casos en que tanto el impulso de la contratación y el desarrollo societario está regido por normas imperativas, es decir de contenido inamovible. Ejemplo: todos aquellos casos en que el Estado por razones de orden público y de necesidad social, ha restringido el ejercicio de determinadas actividades a empresas del Estado.

**Históricamente podemos revisar que durante el siglo XX había muchas actividades reservadas a actividades del Estado** (por ejemplo, la minería y cobre, la comercialización de armas, la actividad de mensajería) **y este es el origen de muchas empresas del Estado que hoy siguen desarrollando su actividad y que compiten con otras empresas del ámbito privado.** Después podemos observar que hay ciertas actividades que solo pueden ser ejecutadas por ciertos tipos especiales de sociedades, que deben sujetarse a rígidas normas legales en cuanto a la forma en que se constituye y rígidas normas legales en cuanto a los sistemas de funcionamiento de la sociedad. Todas las sociedades que ejerzan giro bancario, administración de fondos de pensiones, a la actividad de seguros, etc.

En nuestro ordenamiento jurídico encontramos casos en que observamos preponderancia de la tesis contractualista y otros casos en que predomina la institucionalista. Zegers plantea que la teoría institucionalista no se comprende, el profesor dice lo contrario, pero hay situaciones en que esta teoría se presenta con más énfasis que la contractualista en algunos casos.

Esta discusión doctrinal **ha llevado a plantear un nuevo derecho de sociedades**. Esto está reflejado en que hay varios tipos de sociedades que se han ido incorporando a los ordenamientos, adicional a los clásicos tipos societarios contenidos en los códigos decimonónicos anclados al sistema intuitu personae.

Por eso, las interrogantes: ¿Qué rol juega el principio de la autonomía de la voluntad? R: Contractualista: relevante, institucionalista: morigerado.

**¿Es posible crear convencionalmente tipos o estructuras societarias praeter legem (fuera de la ley)? ¿es posible cuando el tipo contractual es nominado?** R: en materia de sociedades, la doctrina chilena ha dicho que sobre la base de la definición del artículo 2053 y la estructura de clasificación que se encuentra en el artículo 2059 y siguientes, no es posible crear tipos societarios distintos de aquellos que están considerados en el ordenamiento jurídico. Entonces el régimen de tipos societarios es **taxativo**. Existe una enumeración que es cerrada. **Solo el legislador podría incorporar nuevos tipos societarios.**

Lo importante es esto: el principio de autonomía de la voluntad en materia de creación de sociedades o estructuras societarias está limitado. Solo se pueden crear las que el legislador ha considerado. Cuando analicemos el desarrollo de un giro en concreto y escojamos para ese giro una determinada clase de tipo o sociedad, vamos a tener que ajustarnos a la tipología societaria determinada en el ordenamiento y no uno distinto. Esto tiene mucha importancia porque este tipo societario, nos determinará a nosotros el límite de responsabilidad. Es decir, si los socios responden ilimitadamente o hay una limitación. También sabremos cómo se administrará la sociedad y cómo se tomarán las decisiones. También tiene importancia para el régimen tributario de esa sociedad.

**Lo importante es que esta limitación está representada en el tipo social, pero no en el contenido.** Esto quiere decir, que cuando elegimos un tipo de sociedad, podemos encontrar distintas normas en el ordenamiento que le entregan al principio de autonomía de la voluntad, cierta libertad en cuanto a la forma de administración y la forma de distribución de utilidades o pérdidas.

En materia de sociedades por acciones, el artículo 424 señala lo siguiente: en silencio del estatuto social (en aquello que las partes no pacten) la sociedad se regirá supletoriamente y solo aquello en que no vaya en contra, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas. Lo mismo ocurre en general con la forma en que los socios se reparten las pérdidas y utilidades de la sociedad. Podemos pactar un mecanismo de reparto en las proporciones que estimemos convenientes y solo en aquellos casos en que las partes silencian, se aplicarán las normas contenidas en la ley, que, por regla general, es en proporción al valor del aporte. Puede ser una distribución diferente (con aportes iguales) si se pactan la forma de distribución, pero será proporcional si nada dicen las partes.

## 8. CLASIFICACIÓN

Nuestro ordenamiento recoge en materia de clasificación de sociedades o los instrumentos para determinar qué tipo de sociedad es, el elemento del fin (teleológico).

**Artículo 2059 del Código Civil.** *La sociedad puede ser civil o comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio, las otras son civiles.* El objeto de la sociedad

que nosotros pactemos va a determinar si la sociedad es civil o mercantil. Esto va a determinar en materia de sociedades colectivas, si nos regiremos por las sociedades mercantiles civil o las leyes de las mercantiles.

**Tenemos sociedades civiles y comerciales.** Las civiles están en el artículo 2053 y siguientes. Estas normas se aplican de forma supletoria para todo tipo de sociedades. Dentro de las sociedades civiles podemos distinguir entre **sociedades colectivas, comanditas y sociedades de responsabilidad limitada** y son civiles porque el objeto determina que son civiles.

**Luego tenemos sociedades comerciales**, reguladas en los artículos 348 y siguientes del Código de Comercio. El artículo 348 dice: "Se regulan tres tipos de sociedad, la sociedad colectiva, la sociedad por acciones y la sociedad en comandita". Pero además como sociedades comerciales tenemos **las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones**. Las sociedades de responsabilidad limitada pueden ser civiles o mercantiles.

Las sociedades anónimas y las sociedades por acciones, cualquiera sea su objeto, **SIEMPRE** serán **mercantiles**. Esto lo señala expresamente el **artículo 2064 del Código Civil**: "*La sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil*". Esto tiene su concordancia con el artículo primero inciso segundo de la ley 18.046 que regula las sociedades anónimas que reitera nuevamente la norma del artículo 2064 del Código Civil.

Lo mismo ocurre en las sociedades por acciones, que se les aplican las normas de las sociedades anónimas cerradas.

Las sociedades anónimas pueden ser **abiertas y cerradas**. Además, pueden ser **especiales**. Es la propia ley la que clasifica estas sociedades. El artículo 2 de la ley 18.046 dice que estas pueden ser de tres clases, está de forma expresa. Las sociedades anónimas abiertas son sociedades específicas que deben sujetarse a dos requisitos principalmente:

- Inscribirse en el registro de valores que para tales efectos lleva la Comisión para el mercado financiero
- Están sujetas al control o fiscalización de la Comisión para el mercado financiero.

Las anónimas cerradas no están sujetas a control ni supervigilancia, ni obligadas al registro.

Las Sociedades anónimas especiales, son un cierto tipo de S.A. que debe ajustarse a ciertas reglas generales que están establecidas en el artículo 126 de la ley de SA, por ejemplo, en materia de administración de pensiones, deben sujetarse además al decreto ley 3500. En el caso del giro bancario, además de las normas del artículo 126, deben ajustarse a la Ley general de bancos. Las que se dediquen a seguros, deben regirse además del Decreto con Fuerza de ley 251. Son sociedades especiales porque en el **proceso de constitución deben obtener una especial autorización de existencia** que le confiere el supervisor sectorial. Es decir, la AFP tiene que tener una autorización especial de existencia de la superintendencia del área. Lo mismo una sociedad especial bancaria, de la superintendencia de bancos. La que se dedique a seguros debe obtener una autorización de la Comisión para el mercado financiero.

Luego tenemos las Spa, que están reguladas en el artículo 424 y siguientes del Código de Comercio.

Además de esta clasificación, tenemos ciertas clasificaciones que ha determinado la doctrina:

- **Civiles y mercantiles**
- **De personas y de capital:** la doctrina ha señalado que es relevante esta distinción, principalmente en un doble sentido:
  - i) **En cuanto a las exigencias que establece la ley para la constitución de la sociedad** (se pueden distinguir en las de personas, sociedades consensuales como la sociedad colectiva civil y otras que son solemnes como las colectivas comerciales mercantiles y las Sociedades de responsabilidad limitada, y las sociedades de capital que normalmente son solemnes)
  - ii) **En cuanto a la administración.** En las de personas normalmente es uno de los socios, en cambio en las de capital hay un estricto control de la actividad que realiza el directorio y la alta dirección de la sociedad anónima en general representada por el gerente.

Las sociedades de capital pueden dividirse en las **sociedades cotizadas y no cotizadas**.

- **Sociedades de estructura contractualista o personalista y de estructura corporativa:** la contractualista por reglas general, los sistemas de delimitación no están sujetos a determinados tipos de control (se designa un administrador y este ejecuta el giro social y en muchos casos incluso es el socio). En cambio, en las sociedades de estructura corporativa, existen diversos mecanismos de control (en las sociedades anónimas, el gran ente fiscalizador es la junta de accionistas, pero quien ejecuta la administración de la sociedad, es el directorio a través de un gerente. En este tipo de sociedad, la junta controla el actuar de directorio).
- **Pluripersonales y unipersonales:** existe la posibilidad de una sociedad unipersonal, como la sociedad por acciones con personalidad jurídica.
- **Sociedades nacionales y extranjeras**

## 9. GRUPOS EMPRESARIALES

### a) **Justificación**

La economía globalizada, los incentivos de emprendimiento e inversión y las exigencias de la eficiencia económica.

### b) **Concepto**

“Es una forma jurídica propia de la mediana y gran empresa de nuestro tiempo cuando la empresa alcanza dimensiones económicas consistentes y está provista de la organización compleja que caracteriza a ese nuevo modo de producir al que se le da en nombre de tercerización de la industria, asume inevitablemente su configuración bajo la dirección unificada de una sociedad directora o

holding que opera por medio de una pluralidad de sociedades” GALGANO 19, N°s. 1°, 2°, 4° y 24°, de la Carta Política

c) Reconocimiento normativo (no se habló en clases)

d) Responsabilidad (no se habló en clases)

## 10. CARACTERÍSTICAS

- **Bilateral o plurilateral:** excepcionalmente unilateral (SPA)
- **Solemne o consensual:** la regla general es que sea consensual, pero hay ciertas sociedades que requieren de formalidades, estas son:
  - Escritura pública
  - Un extracto de la escritura pública que debe inscribirse en el **registro especial de comercio** (que lleva el conservador de bienes raíces)
  - La publicación de ese mismo extracto en el diario oficial de la república.

Estas son las solemnidades que deben cumplir las sociedades sujetas a ellas. Adicionalmente hay ciertos tipos de sociedades que tienen formalidades especiales, que son aquellas que deben tener una autorización de existencia del órgano de supervisión sectorial (por ejemplo, una sociedad anónima especial de giro bancario)

- **Intuito personae:** En el concepto tradicional, especialmente en la sociedad colectiva, son intuito personae. Esto quiere decir que se celebró el contrato de sociedad en consideración a las personas que se incorporan al ente societario. Esto tiene mucha importancia, porque vamos a ver más adelante que en el caso de las sociedades colectivas civiles, la particularidad intuito personae, está dada en la posibilidad de incorporar nuevos socios. Cuando en una sociedad colectiva se quiere incorporar un nuevo socio, requiere acuerdo unánime de los demás socios. Hay doctrina que ha dicho que hay prácticamente una imposibilidad absoluta de cesión de derechos (a menos que exista acuerdo). En cambio, en la sociedad de capital existe fungibilidad, ya que las acciones se transan constantemente en el mercado (En las S.A.C. pueden transferirse sin mayores complicaciones)
- **Oneroso:** que un contrato sea oneroso, significa que cada parte se grava en beneficio de la otra. Hay autores (como Guerrero y Zegers) que vinculan lo oneroso, con la frase “de repartir las utilidades de que ello provenga”, aunque el profesor está en desacuerdo. Cuando un contrato es oneroso, significa que una persona se grava en beneficio de la otra. En la sociedad la onerosidad del contrato, está en el hecho de nos obligamos a materializar un aporte. No es oneroso porque se repartan las utilidades, sino en el que nos gravemos para materializar un aporte
- **Típico o nominado:** esto está relacionado con la taxatividad.
- **¿De ejecución inmediata o de tracto sucesivo?** R: para aquellos que entienden que la celebración (tesis contractualista) del contrato de sociedad importa una continuidad, evidentemente que estamos frente a un contrato de tracto sucesivo, porque la relación contractual no termina con el

---

acto de constitución, sino que subsiste en el tiempo, hasta que se cumpla la condición o el plazo que pactan las partes para efectos del término de la sociedad. Para aquellos que entienden que hay una separación entre el contrato constitutivo y el ente que nace en razón de la personalidad jurídica, el contrato de sociedad en tanto acto constitutivo es de ejecución inmediata y luego nace un ente que se separa de ese acto y que tiene personalidad jurídica propia.

#### **11. PERSONALIDAD JURÍDICA**

La concepción francesa tradicional de la sociedad entiende como efecto del acto constitutivo la personalidad jurídica. Ello sigue con mayor fuerza nuestro ordenamiento en el inciso 2º del C.c.

En el derecho alemán primero dogmáticamente y luego *lege lata* se distinguió entre sociedades con personalidad jurídica y sociedades sin personalidad jurídica. Las primeras sociedades de personas y las segundas sociedades de capital (Wieland – Gierke). Mismo criterio acogió el derecho italiano.

Martes 21 de agosto de 2018

### III

## SOCIEDADES COLECTIVAS CIVILES

### 1. FORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS

#### 1.1. Requisitos comunes

Ya revisamos el concepto de las sociedades colectivas en materia civil. Ahora se analizarán los requisitos de conformación. Como en todo acto jurídico, el contrato de sociedad debe contener los elementos esenciales de todo contrato:

- Voluntad exenta de vicio
- Objeto lícito
- Causa lícita
- Solemnidades (para el caso de las sociedades mercantiles)

Para el caso de las sociedades colectivas civiles, son consensuales. Es decir, que el consentimiento se forma cuando concurren la oferta y la aceptación. Más adelante veremos que las sociedades anónimas, colectivas mercantiles, las de responsabilidad limitada son solemnnes y deben cumplir con ciertas solemnidades: **i) El pacto se reduce a escritura pública ii) el extracto de la sociedad publicado en el diario oficial iii) la inscripción en el registro de comercio.** ¿Hay alguna otra solemnidad que se pueda detectar en la ley? R: la autorización especial de existencia del órgano de supervisión sectorial. Hay sociedades que además de cumplir con estos requisitos, necesita esta autorización. Por ejemplo: los bancos, una compañía de seguro, etc.

#### 1.2. Requisitos especiales o específicos

- a) **La estipulación del aporte (no el aporte):** El aporte tiene una doble dimensión en la sociedad: como elemento esencial y como obligación del socio para con la sociedad. Es elemento esencial la estipulación del aporte.
- b) **Estipulación de lucro o ganancia (utilidad o beneficios):** “Con miras a repartir el beneficio que de ello provenga”.
- c) **Afectio Societatis:** es una elaboración doctrinal (no está en el 2053 del Código Civil). Sin embargo, nuestro ordenamiento la ha reconocido como tal de forma constante y permanente. En un fallo del año 2008 que señala lo siguiente: *“Es elemento de la esencia del contrato de sociedad, la afectio societatis, osea, la intención clara, precisa y definida de asociarse permanentemente y no de manera accidental o transitorio, ni menos fingiéndose asociados frente a terceros, todo para lograr un lucro, constituyéndose en el contrato, una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”*

**Si no concurren los requisitos, la sociedad es nula.** Por ejemplo, nos ponemos de acuerdo con nuestro hermano (yo no tengo </3) para comprar una propiedad. Celebramos el contrato. ¿Hay sociedad? R: por eso la doctrina ha elaborado la afectio societatis, para despejar cualquier duda respecto de la concurrencia y de la intención de las partes de conformar una sociedad. Cuando se conforma una sociedad, hay efectos jurídicos muy relevantes. Surgen formas especiales de

administración y de responsabilidad. Aquí los hermanos no compraron el bien con miras a repartirse las utilidades, ni de asociarse permanentemente.

**¿Por qué es importante este elemento de la afectio societatis?** R: ya que los regímenes de responsabilidad de la sociedad son muy diferentes a otros regímenes. Este elemento es esencial para distinguir si hay o no sociedad. Si no concurren, el efecto que se produce es que no hay sociedad. Sin embargo, el Código Civil se hace cargo de una figura que se llama **SOCIEDAD DE HECHO. Artículo 2047**: Si se formare de hecho una sociedad que no pudiera existir legalmente, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus aportes.

**¿Qué tipo de régimen se configura en esta especie de sociedad de hecho?** R: al no existir sociedad y al no poder aplicarse este régimen, deberán aplicarse las reglas generales en materia de obligaciones. Por lo tanto, si no hay pacto, deberán responder todos por igual (a menos que hubieren pactado una manera diferente de contribución a la deuda).

## **2. EFECTOS/OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE SOCIEDAD**

**¿Qué efectos produce la celebración de un contrato de sociedad?** R:

a) **El nacimiento o la conformación de la personalidad jurídica:** El artículo 545 del Código Civil.

Art. 545. Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

b) **Una vez celebrado el contrato hay que distinguir:**

- i) En las denominadas relaciones internas de la sociedad: en concreto, i) **los efectos entre los socios** y ii) **los efectos entre la sociedad y los socios.**
  - **Respecto de los socios y la sociedad:** la obligación de materializar el aporte y por otro lado, la obligación vinculada con la distribución y reparto de las utilidades y beneficios que provengan de la ejecución del giro social.
  - **Respecto de los socios entre sí:** la doctrina ha indiciado de manera transversal, dos tipos de obligaciones: vinculadas a **los deberes de lealtad y fidelidad y que no es otra cosa que una manifestación de la buena fe en la ejecución del contrato de sociedad.**
- ii) En las denominadas relaciones externas de la sociedad: i) **los efectos que provoca la celebración del contrato de sociedad y los terceros** (embargo del aporte/ bien hipotecado Art. 2096) y ii) **entre los socios y terceros** (embargo de los derechos sociales/del beneficio)

Estamos analizando los efectos que se producen en razón de la celebración de un contrato de sociedad. Destacamos el surgimiento de un ente especial y distinto de los socios individualmente considerados. Analizamos las problemáticas de la tipología societaria. Hablamos de las ventajas de esta separación. La doctrina nacional, cuando aborda las ventajas del ente societario, habla de la separación patrimonial. De manera general, esto permite morigerar los efectos que provocaría la actuación del empresario individual en cuanto al riesgo de la ejecución del giro, en una perspectiva colectiva o societaria.

Miércoles 22 de agosto de 2018

### 3. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

Nos daremos cuenta de una contradicción, respecto del origen de la limitación patrimonial y de la separación patrimonial entre la sociedad y los socios. Las sociedades colectivas por regla general, los socios si van a responder por las obligaciones con su patrimonio propio. Por esta razón, los regímenes del derecho comparado como el alemán o el italiano, las sociedades de personas no tienen personalidad jurídica en el sentido estudiado.

### 4. OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS A LA SOCIEDAD

Las obligaciones son: el aporte, el saneamiento de la evicción de la especie aportada y el cuidar de los intereses sociales

#### 4.1. El aporte

El aporte constituye una obligación, este aporte cuya estipulación debe contenerse en cualquier pacto societario, puede consistir:

- **En dinero**
- **En trabajo o servicio o industria:** en este último caso, siempre debe ser apreciable en dinero (Art. 2055 del Código Civil)

Hay una excepción al artículo 2055: en el caso de las sociedades anónimas (S.A) está excluido el aporte en servicio o en industria. Las acciones que representan el aporte de un socio en una sociedad anónima no pueden ser representativas de industrias o de organización (prestación de servicios). El aporte en las sociedades anónimas no puede ocurrir esto.

- **En especies (corporales e incorporales).**

No hay sociedad, si cada uno de los socios no pone una cosa en común.

Se encuentra regulado en los Artículos 2055, 2082 a 2087 del Código Civil y en los artículos 376,378 y 379 del Código de Comercio.

Lo importante es que cuando se pacta un aporte en trabajo, servicio o especies, debe evaluarse o referir o indicar un valor en el pacto social del bien que yo aporte y del trabajo y/o servicio. Señalamos en la clase anterior **¿Qué ocurre si no se indica en el pacto social o en el momento de acordar, el valor de la especie o cuerpo cierto?** R: la posición del profesor diría que no hay estipulación de

aporte, por lo que se afectaría la validez del acto constitutivo de la sociedad, la sociedad es nula. Esto además tiene un efecto práctico importante: cuando revisemos el mecanismo de reparto de beneficios y pérdidas del contrato de sociedad, si las partes no acuerdan nada en concreto, se establece una norma supletoria, que implica que su participación en la pérdida o beneficios de la sociedad, se hará a prorrata del aporte. Por lo tanto, es fundamental que en aquellos casos en que el aporte no sea dinerario, sea avaluable en dinero.

Otros autores dirían que con el compromiso basta. Cuando se pacta, se cumple con el requisito esencial y el socio está obligado de materializar el aporte respecto de la sociedad. La sociedad es la que puede solicitar el cumplimiento forzado del aporte y la indemnización de perjuicios. Entonces el socio se obliga para con la sociedad.

**Modalidades del aporte:** cuando el aporte es en especie o cuerpo cierto se puede aportar en **propiedad o en usufructo**. Esta diferenciación es importante ya que en el artículo 2082 se señala:

Art. 2082. Los aportes al fondo social pueden hacerse en propiedad o en usufructo. En uno y otro caso los frutos pertenecen a la sociedad desde el momento del aporte.

Esto tiene mucha importancia para efectos de determinar a cargo de quien queda el riesgo de la pérdida de la cosa aportada. En las obligaciones de género esto no tiene importancia, porque el género no perece. **Si se aporta en propiedad, el riesgo de la cosa pertenece a la sociedad en virtud de las reglas generales.** Estando pendiente la obligación de efectuar el aporte, la sociedad es acreedora.

**Riesgo de la cosa aportada:** Otro punto importante de ayer ¿Qué ocurría en el caso de la pérdida o deterioro del aporte en propiedad, especialmente respecto del cuerpo cierto? R: Ahí señalamos que el artículo 2084, establecía que se debían aplicar las normas generales sobre la pérdida de la cosa.

- Si materialicé el aporte, la sociedad es dueña del bien, por lo tanto, se aplica la regla general del artículo 1672 del Código Civil, en donde las cosas perecen para su dueño.
- En el caso de que no se haya materializado el aporte (socio sigue obligado), la regla general, en materia de riegos, es de cargo del acreedor en el caso fortuito o fuerza mayor (**Art 1550 del Código Civil, el profe lo repitió mucho**).

En el caso de retardo es del deudor ¿Si hay retardo en la entrega, hay culpa del deudor? ¿por qué? ¿Cómo se presume el incumplimiento? ¿Hay alguna norma en nuestro ordenamiento que infiera la culpa en el incumplimiento? R: artículo 1547, la prueba de la diligencia la debe probar el que le incumbe y el caso fortuito al que lo alega. Lo que ha dicho la doctrina, es que se presume la culpa. **El incumplimiento se presume culpable.** Si hay un retardo o se hace referencia a un retardo, debemos entender que ese incumplimiento siempre es culpable, lo que invierte los riesgos (pasa a ser del deudor).

**Requisitos del aporte:** debe ser:

- (i) **Siempre útil para el giro que se pactó al momento de constituir una sociedad.**

- (ii) **Debe ser apreciable en dinero.** En todos aquellos casos en que el aporte no es dinerario, no solamente debe ser apreciado en dinero, sino que debe ser avaluado en dinero, hay que fijarle un valor. **¿Qué importancia tiene la determinación del valor de las cosas aportadas?** R: el valor del bien, va a determinar el derecho del socio en la sociedad. La proporción del derecho en la sociedad, es decir, en qué medida el socio va participar en la ganancia o en la pérdida de la gestión.

**Nota:** aprenderse cuadro de sociedades en web cursos.

**Saneamiento de la evicción:** Cuando se aporta un cuerpo cierto (ya sea en propiedad o en usufructo), el socio está obligado al saneamiento de la evicción. Se aplican las reglas de saneamiento en la compraventa para el aporte de los socios. La evicción es la privación total o parcial del bien. El que aporta está obligado a sanear.

**(CLASE VICENTE IRARRÁZABAL E ISABEL MELLADO SOBRE SANEAMIENTO DE LA EVICCIÓN)**

**Art. 1837.** “La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios.”

**Art. 1838.** “Hay evicción de la cosa comprada, cuando el comprador es privado del todo o parte de ella, por sentencia judicial”

**Art. 1839.** “El vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se haya estipulado lo contrario.”

**Requisitos:**

- A) que el comprador se vea expuesto a sufrir evicción de la cosa(a ser privado de ella total o parcialmente) por una causa anterior a la venta.
- B) que comunique el vendedor la turbación de que es víctima para que concurra en su defensa, que es lo que se conoce como citación de evicción.

**Elementos:**

- A) que el comprador sea privado de todo o parte de la cosa vendida
- B) que la privación se produzca por sentencia judicial y;
- C) Que la privación provenga por una causa anterior a la venta

**Citación de evicción**

- Es un caso de sustitución procesal
- El vendedor ocupa el lugar que se tenía el comprador en el juicio. (art 584 y siguientes del cpc)
- debe ser antes de contestar la demanda y suspende el juicio por un plazo de tiempo de 10 días.

Etapas de la citación:

- Si el vendedor comparece adquiere la calidad de demandado, el comprador puede hacer parte como tercero en forma de coadyuvante.
- Si no comparece el vendedor al juicio se sigue en contra del comprador, pero en ese caso el vendedor debe responder de las resultas y prejuicios de ese juicio. Salvo que el comprador que fue el que siguió defendiendo, haya dejado de oponer una defensa o excepción **propia** y en virtud de ello la cosa fuera evicta.
- Si no se cita al vendedor de evicción no va a tener que responder por los prejuicios. Esto es un derecho que tiene el comprador

¿A quienes se puede citar?

- Normalmente al vendedor o sus herederos
- También puede el comprador citar a los antecesores del vendedor.
- Art. 1841. "Aquel a quien se demanda una cosa comprada podrá intentar contra el tercero de quien su vendedor la hubiere adquirido, la acción de saneamiento que contra dicho tercero competiría al vendedor, si éste hubiese permanecido en posesión de la cosa."

Se aplica la regla de la compraventa, porque la norma específica que regula la evicción en la sociedad, hace referencia a dicha norma. Es un acto de disposición patrimonial en el que se asimila a una compraventa.

Hay casos especiales:

- En los aportes **no se aplica la lesión enorme**, ya que es una regla específica que solo se aplica en el caso de la compraventa o cláusula penal (entre otros casos)
- **¿Puede estar sujeta a condición resolutoria o suspensiva, la obligación de aportar?** R: En general, la jurisprudencia ha sostenido que no operaría un pacto de condición suspensiva en el caso del aporte. Pero la doctrina se ha apartado de esta teoría, la práctica también. Es muy común ver obligaciones de aportar sujetas a condiciones suspensivas o a plazo. Por ejemplo: Yo me obligo a aportar un bien bajo la condición de ese bien que existe y que está en mi poder, llegue de china para poder entregarse. ¿Qué ocurre si no llega nunca? R: falla la condición y no nace la obligación para exigir el aporte.

La obligación de efectuar el aporte.

- a) **¿Qué se aporta?** Debo aportar aquello que me obligué o que está contenido en el pacto. Hay una sola **excepción** que está contenido en el artículo 2087 que se denomina infracapitalización. "A ningún socio podrá exigirse aquel aporte más considerable que aquel a que se haya obligado, pero si no se pudiere conseguir el objeto de la sociedad sin aumentar los aportes, el socio que no consienta podrá retirarse si sus consocios lo acuerdan o lo exigen". Aquí los aportes no son suficientes, por lo que se le podría exigir que aumente el aporte, pero en el caso de que no quiera, podrá retirarse y deberá hacerlo si sus socios se lo exigen. **Esta es una norma muy importante para entender que las sociedades de personas son intuitu personae, están basadas en la confianza de las personas que se integran a la sociedad.**

- b) **¿Cuándo?** R: plazo o condición
- c) **¿Como?** R: propiedad o usufructo. Si es en propiedad, tratándose de bienes muebles se materializa por tradición material por regla general. Si es bienes inmuebles tradición por inscripción.
- d) **Incumplimiento en la obligación de aportar** ¿opera la condición resolutoria tácita del artículo 1489 del Código Civil? Otros sostienen que no, sino que debe operar la acción de cumplimiento con indemnización de perjuicios (por el retardo).

**¿Qué problemas hay?** R: el artículo 2101 indica como causal de disolución de la sociedad lo siguiente:

Art. 2101. Si cualquiera de los socios falta por su hecho o culpa a su promesa de poner en común las cosas o la industria a que se ha obligado en el contrato, los otros tendrán derecho para dar la sociedad por disuelta.

Pareciera que existe una regla especial de incumplimiento que le entregaría una facultad especial de los consocios para pedir la disolución de la sociedad cuando uno de los socios (por hecho o culpa suya) no cumplen la obligación de aportar.

### **Embargo del Aporte**

La regla general, es que no se puede embargar el bien aportado. Porque las sociedades de personas son personalísimas y nadie puede entrar o incorporarse a esa sociedad, sin el consentimiento unánime de los demás socios. Por lo tanto, si se embarga un aporte o un derecho social por una deuda de un socio, de alguna manera, está provocando como resultado, que se incorpore un tercero a la sociedad.

Texto que lee el profesor: De acuerdo al artículo 380 del Código de Comercio, cuyo sentido también se encuentra en el artículo 2096 del Código Civil, los acreedores personales de los socios, no pueden embargar los derechos personales de estos, que tengan en la sociedad colectiva. El fundamento de esto, es que dichas sociedades son *intuitu personae* y su constitución es en relación a las personas que los constituyen, el carácter personalísimo se refleja en que está prohibido que se pueda incorporar un tercero, sin la aprobación de los demás socios. Así, los derechos sociales de una sociedad de personas, se encuentran dentro del artículo 445 N° 15 del Código de Procedimiento civil que declara la inembargabilidad de los derechos cuyo derecho es personal.

**Entonces hay ciertas limitaciones a los embargos que se puedan materializar respecto de derechos sociales y del bien aportado.** Respecto del bien aportado, es más evidente, ya que no está en el patrimonio del socio, sino en el de la sociedad. Y respecto de los derechos, aplica lo anterior. En las sociedades de personas sí podrían embargarse las utilidades de beneficios o ganancias, pero NO LOS DERECHOS.

En el artículo 2096: “los acreedores de los socios no tienen acción sobre los bienes sociales, sino en el caso en una hipoteca anterior. Se podrá también pedir embargo a su favor, de las asignaciones que se hagan en razón de beneficios sociales”.

### **4.2. Otras obligaciones de los socios**

La jurisprudencia, tomando ciertas normas que están expresamente consagradas en la ley de sociedades anónimas, han extrapolado la aplicación de estas supuestas obligaciones a las sociedades de personas. **No hay norma que haga referencias al deber de fidelidad y de lealtad** (a diferencia de la LSA) La doctrina ha entendido que hay ciertas normas que están contenidas en el Código Civil de las que se podrían desprender estos deberes.

Este deber de lealtad y fidelidad, puede desprenderse del 1546. Esto es, de aquí puede desprenderse. Este artículo que consagra la buena fe objetiva, es un deber que se consagra para todo el ordenamiento. Esta es la norma fundamental.

De los artículos que se podría desprender: El artículo 2083 referido al aporte social que señala que se debe aportar sin culpa y de manera diligente. El artículo 2087 apunta también a la problemática.

En cuanto al deber de lealtad dice que los perjuicios o las pérdidas que pueda sufrir la sociedad en el giro, se reparten a prorrata. (Artículo 2089 del Código Civil).

Todas estas normas son las normas base, las que se aplican supletoriamente a las demás sociedades.

## 5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

### 5.1. Deliberaciones:

¿Cómo los socios se ponen de acuerdo en el desarrollo del giro social? R: por un acuerdo que se encuentra en el artículo 2054: rige para los efectos de llegar a acuerdo, lo que se pacta al momento de constituir la sociedad. Si nada se pactare, se aplica una regla numérica. Si constituimos una sociedad con 3 personas y nosotros tenemos 50%, y los otros dos 25%, y nada se pactó para efectos de llegar a acuerdo ¿Qué sucede?

Art. 2054. En las deliberaciones de los socios que tengan derecho a votar, decidirá la mayoría de votos, computada según el contrato, y si en éste nada se hubiere estatuido sobre ello, decidirá la mayoría numérica de los socios.

Exceptúense los casos en que la ley o el contrato exigen unanimidad, o conceden a cualquiera de los socios el derecho de oponerse a los otros.

La unanimidad es necesaria para toda modificación substancial del contrato, salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra cosa.

Es importante jugar con estas reglas para que el valor de la decisión de un socio mayoritario, tenga valor al momento de deliberar.

Modificación substancia del contrato: debe haber acuerdo unánime, si es que no hay pacto en contrario. En todos aquellos casos en que se modifique el giro social, se entenderá que hubo modificación substancial. Todo esto tiene excepciones en la L.S.A.

Martes 28 de agosto de 2018

Recordemos la importancia de las normas de la sociedad colectiva civil: estas normas se aplican en lo que corresponde y en lo pertinente a todas las sociedades de personas. Son de aplicación supletoria para las sociedades colectivas mercantiles y para las sociedades de responsabilidad limitada (que tienen una aplicación práctica más frecuente que la colectiva civil en el tráfico).

Las deliberaciones tienen una gran importancia ya que son los acuerdos de los socios que se refieren al giro social. La regla general es el pacto, no obstante, ser la sociedad colectiva civil de carácter consensual, **lo normal es que se escriba para efectos de prueba**. Lo normal o común es que sea a través de escritura pública.

A falta de pacto se aplica un régimen de mayoría numérica de socios. Excepto cuando se requiera la unanimidad por ser las modificaciones de carácter substancial.

## 5.2. Administración Arts. 2071 y ss del Código Civil

¿Quién administra? Artículos 2071-2074 del Código Civil. En la sociedad colectiva civil hay tres supuestos:

- Que administre un solo socio
- Que administren dos o más socios
- Que no exista pacto de administración expreso, lo que implica aplicar una regla especial del artículo 2081 donde todos los socios desde el punto de vista de la norma, pueden ejecutar actos de administración con ciertas limitaciones.

**En aquellos casos en que se acuerde la designación de uno o más socios administradores, también es necesario hacer una distinción:**

- **Si esa designación se materializa en un acto constitutivo de la sociedad:** algunos autores sostienen que se trataría de una cláusula esencial del contrato. Aunque a juicio del profesor dice lo contrario. El profesor cree que no, porque la falta de pacto de un elemento esencial del contrato ¿Qué acarrea? R: nulidad. Pero el artículo 2081 establece una regla para el caso de que no exista un pacto respecto de la designación de los administradores.
- **O en un acto posterior.**

Esto es importante porque hay limitaciones expresas. La importancia de determinar el momento en que se designa al administrador está relacionada con dos normas referidas a la renuncia de los socios administradores o a la posibilidad de remover a este socio administrador (Art. 2072 inciso 1 y 2).

Art. 2072. El socio a quien se ha confiado la administración por el acto constitutivo de la sociedad, no puede renunciar su cargo, sino por causa prevista en el acto constitutivo, o unánimemente aceptada por los consocios.

Ni podrá ser removido de su cargo sino en los casos previstos o por causa grave; y se tendrá por tal la que le haga indigno de confianza o incapaz de administrar útilmente. Cualquiera de los socios podrá exigir la remoción, justificando la causa.

Faltando alguna de las causas antedichas, la renuncia o remoción pone fin a la sociedad.

**La importancia de la determinación del momento en que se designa el administrador está dada por la posibilidad de la renuncia o la posibilidad de remover a este último.**

(i) Cuando se designa al socio en el acto constitutivo de la sociedad, la regla general es que el socio administrador no puede renunciar, salvo que sea por causas que se hayan pactado en el mismo acto constitutivo o que las partes unánimemente hayan definido.

**Solo podrá ser removido el administrador por causa grave:** Si se pierde la confianza del administrador o el administrador cae en incapacidad para administrador, cualquiera de los socios puede pedir su remoción.

**Si falta alguna de las causas antes dichas, esto pone fin a la sociedad.** Si se produce la renuncia del socio administrador o hay una remoción del socio administrador no conforme a la norma, **esta es una causal de término de la sociedad.**

(ii) Si el administrador es designado en un acto posterior al acto constitutivo de la sociedad, puede renunciar sin limitaciones y puede ser removido por regla de mayoría (Art. 2074 del Código Civil)

**¿Qué ocurre si no contempla el acto constitutivo un pacto de designación de administrador o de administradores?** R: en ese caso, se aplica la regla del artículo 2081 del Código civil, que señala:

Art. 2081. No habiéndose conferido la administración a uno o más de los socios, se entenderá que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar con las facultades expresadas en los artículos precedentes y sin perjuicio de las reglas que siguen:

1ª. Cualquier socio tendrá el derecho de oponerse a los actos administrativos de otro, mientras esté pendiente su ejecución o no hayan producido efectos legales.

2ª. Cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social, con tal que las emplee según su destino ordinario, y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros.

3ª. Cada socio tendrá el derecho de obligar a los otros a que hagan con él las expensas necesarias para la conservación de las cosas sociales.

4ª. Ninguno de los socios podrá hacer innovaciones en los inmuebles que dependan de la sociedad sin el consentimiento de los otros.

Tiene muy poca aplicación práctica. La regla general para cuando se constituye una sociedad, es que se designe uno o dos socios a cargo de la administración de la sociedad. Tiene poca aplicación.

#### **5.2.1. Facultades del administrador o de los administradores (Art. 2077-2094 del Código Civil)**

a) **Si hay un solo administrador, este tiene libertad en el cumplimiento del encargo, salvo los límites del mismo pacto (Artículos 2075, 2077, 2078 y 2079).** Se aplica una regla similar a la regla del mandato. Las facultades pueden ser ordinarias o extraordinarias. Cuando designamos a un administrador, este deberá ceñirse al pacto y si nada se señala, los límites que tiene el administrador son el que podrá realizar todas aquellos actos de administración

ordinaria y estos actos deben estar destinados al giro o al desarrollo social pactado en el acto constitutivo de la sociedad.

Art. 2077. El socio administrador debe ceñirse a los términos de su mandato, y en lo que éste callare, se entenderá que no le es permitido contraer a nombre de la sociedad otras obligaciones, ni hacer otras adquisiciones o enajenaciones, que las comprendidas en el giro ordinario de ella.

Entonces, cuando se designa a un administrador. Este debe ceñirse al pacto y si nada se señala los límites que tiene el administrador son dos fundamentalmente:

- **Primero**, podrá ejecutar todos aquellos actos relacionados con las facultades de administración ordinarias del mandato
- **Segundo**, esos actos de administración ordinaria del mandato, deben estar relacionados con el giro u objeto social pactado en el acto constitutivo de la sociedad.

Las normas de administración ordinarias del mandato están establecidas en el **artículo 2132** del Código Civil.

**b) Si son varios administradores debemos aplicar la regla del artículo 2076.**

Art. 2076. Si la administración es conferida, por el contrato de sociedad o por convención posterior, a dos o más de los socios, cada uno de los administradores podrá ejecutar por sí solo cualquier acto administrativo, salvo que se haya ordenado otra cosa en el título de su mandato.

Si se les prohíbe obrar separadamente, no podrán hacerlo ni aun a pretexto de urgencia.

Entonces tenemos dos opciones:

- **O pactar que los socios administradores actúen conjuntamente:**
- **O pactar que los socios administradores actúen separadamente:** si decidimos esto, hay que señalarlo expresamente en el pacto, para que no exista confusión en la interpretación de la norma. Lo que usualmente se señala es que “X persona e Isabel Margarita Mellado son designadas administradoras de la sociedad y podrán actuar conjunta o separadamente”

**Puchas veces que para actos específicos se incorporan ciertas reglas de actuación conjunta para el giro de cheques o algunos actos de carácter patrimonial. Si un administrador actúa separadamente y debió actuar conjuntamente, los efectos se radican en su propio patrimonio y no obligan a la sociedad.**

**5.2.2. En cuanto a los efectos de los actos de administración. (Art. 2077 -2094 del Código Civil)**

**El acto de administración obliga a la sociedad en tanto el socio o socios administradores actúen a nombre de la sociedad expresándolo inequívocamente o se entienda que es inequívoco.** Pero, además, dentro de los límites pactados cuando hay más de un socio. Es decir, si hay actuación conjunta, debe ser conjunta. Para que se ejecute el acto en conformidad a la ley, debe ser conjunta. Si se hubiere pactado una actuación por separado, podría actuar solo.

---

**5.2.3. ¿A que está obligado el administrador? (Art. 2080)**

- a. A rendir cuenta de la gestión de la misma manera que lo hace el mandatario (Art. 2066, 2067 y 2068). Esta es de las cláusulas más importantes de la sociedad, que es la administración.

**El socio administrador está obligada a la conservación y reparación de los bienes que son parte del capital fijo de la sociedad.** Además, no puede alterarlos en su forma, hipotecarlos ni dar en prenda, aunque le parezca conveniente. **Todos estos actos requieren acuerdo de los socios, ya que no está en las facultades del administrador** (a menos que en el acto constitutivo le hayan conferido esta facultad).

**5.3. Reparto de utilidades y pérdidas**

Esta cláusula siempre –por regla general– en las sociedades colectivas civiles, en las colectivas mercantiles y en las de responsabilidad limitada. Recordemos que las normas del 2053 y siguientes del Código Civil, se aplican supletoriamente a estas últimas sociedades.

**Regla general:** Regirá el principio de la autonomía de la voluntad, el pacto (Art. 2066, 2067 y 2070). Puede entregarse la determinación de utilidades y pérdidas a un tercero (art. 2967).

Por consiguiente, el pacto puede consistir: (i) En un acuerdo expreso que determine la proporción de reparto (normalmente la de los aportes), o (ii) Encargar a un tercero la determinación de la regla.

A ninguno de los socios se le podrá encomendar el determinar cómo se distribuyen las utilidades. A falta de pacto se aplicará la regla del **artículo 2068 del Código Civil**.

Art. 2068. A falta de estipulación expresa, se entenderá que la división de los beneficios debe ser a prorrata de los valores que cada socio ha puesto en el fondo social, y la división de las pérdidas a prorrata de la división de los beneficios.

Si cada socio aporta 10 de un total de 40. Si tenemos utilidades de 200 ¿Cuánto le corresponderá a cada uno de los socios? R: 50 a cada uno.

**¿Qué pasa si un socio no obtendría ningún beneficio ni utilidades?** R: esa cláusula sería nula. Aquí falta la afectio societatis (consiste en poner algo en común con miras a repartirse los beneficios que de ello provenga). Debe obtener un beneficio apreciable en dinero (lo emocional no vale ☹). Hay ciertas figuras asociativas en las que el lucro puede no concurrir como las fundaciones, corporaciones, las cooperativas. Pero en el caso de las sociedades, el objeto central es el lucro y este beneficio siempre debe ser avaluado en dinero. En este caso, tenemos dos opciones: podríamos pedir la nulidad parcial de la cláusula y en razón de esta hacer que se aplique la norma supletoria (en la que todos tienen el derecho a reparto de las utilidades en proporción al valor de sus aportes). No es tan conveniente pedir la nulidad absoluta de la sociedad.

**Todas estas normas que estamos analizando en materia de sociedades colectivas, tienen su correlato en las sociedades colectivas mercantiles, ya que hay ciertas reglas especiales que son complementarias y están establecidas en los artículos 349 y siguientes en materia de sociedades**

colectivas mercantiles, respecto de administración, respecto de término de sociedad (especialmente de la liquidación) y respecto de responsabilidad.

Miércoles 29 de agosto de 2018

Hay dos cláusulas importantes que nosotros debemos tener en consideración:

#### 5.4. Cesión de derechos sociales

Introducción del profesor: Estamos viendo las cláusulas más relevantes en materia de sociedades colectivas y que por lo demás se aplican supletoriamente a las sociedades de personas en general. El Código de comercio, que regula las sociedades colectivas mercantiles, tiene una serie de normas especiales que están relacionadas fundamentalmente con las normas de cómo se constituye una sociedad (solemne, a diferencia de la civil), las reglas de responsabilidad y las de liquidación.

La cesión de los derechos sociales: la regla general es que no procede la cesión de derechos sociales porque se trastoca lo intuitu personae de la sociedad. Esto es a excepción de la decisión unánime de los socios, para aceptar la entrada de un tercero.

Cuando revisemos el estatuto de algunas sociedades y veamos una modificación que incorpore una cesión de derechos sociales, siempre se inserta una cláusula en la que los socios acuerdan la entrada de un tercero a la sociedad

#### 5.5. Transmisión de los derechos sociales (Art. 2103 del Código Civil)

La regla general es que la muerte del socio (siguiendo el criterio intuitu personae) implica que se disuelve la sociedad y los derechos pasan al haber de los herederos. Esto último, a menos que en el acto constitutivo las partes acuerden la continuidad con los socios sobrevivientes o con los herederos del socio fallecido (Art. 2103 Código Civil).

#### 5.6. Régimen de responsabilidad

**Cuando iniciamos la clase, una de las particularidades o efectos más relevantes del contrato de sociedad era el que forma una personalidad jurídica distinta de los socios individualmente considerados** (Bello lo incorporó en el artículo 2053 a diferencia del Código francés).

Los textos van matizando, lo que quiere decir es que la particularidad de la separación del ente social y los socios, sería la limitación de responsabilidad. Cuando vemos los textos, vemos que una de las ventajas del sistema societario es **esta separación desde el punto de vista patrimonial**. Al constituir una sociedad, todos los actos que se ejecuten y que obliguen a la sociedad, no afectan patrimonialmente a los socios. Sin embargo, esto no es tan así en nuestro sistema. El sistema italiano y el alemán, por ejemplo, no se encuentra reconocida esta separación ni se les reconoce la personalidad jurídica en las sociedades de personas. Esto, porque en materia de sociedades colectivas, los socios si responden con sus bienes propios de las obligaciones sociales. Entonces este paradigma cuando se abordan los textos en materia de ventajas de la constitución de sociedad, tiene este matiz. No existe esta separación tan absoluta entre el ente y el socio desde el punto de vista de

la sociedad. Lo que sí ha señalado la doctrina, es que es una responsabilidad de segundo grado o subsidiaria, como el beneficio de excusión en el caso del fiador.

Aquí operaría de la misma manera: dirijase en primer lugar en contra de la sociedad y si esta no tiene la capacidad patrimonial para responder, dirijase a los socios.

**¿Por qué podemos llegar a esta conclusión?** R: la lectura armónica entre el 2053 y el 2095 del Código civil nos puede llevar a esta conclusión. Es decir que, si la sociedad conforma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, debemos entender entonces que una sociedad colectiva, los terceros deberían dirigirse en primer lugar al cumplimiento de la obligación en el patrimonio social y luego respecto de los socios. Lo que implicará que el total o el saldo de la deuda se dividirá entre los socios a prorrata del interés social y la cuota del deudor insolvente gravará a los otros y no hay solidaridad, por lo que es una **obligación simplemente conjunta**.

Art. 2095. Si la sociedad colectiva es obligada respecto de terceros, la totalidad de la deuda se dividirá entre los socios a prorrata de su interés social, y la cuota del socio insolvente gravará a los otros. No se entenderá que los socios son obligados solidariamente o de otra manera que, a prorrata de su interés social, sino cuando así se exprese en el título de la obligación, y ésta se haya contraído por todos los socios o con poder especial de ellos.

Art. 2053. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan.

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados.

En el caso de las sociedades colectivas comerciales, sí hay solidaridad por norma expresa.

**El inciso segundo del artículo 2095 dice que si podrá haber solidaridad cuando así se exprese en el título de la obligación cuando ella se ha contraído por todos los socios o por la decisión de todos ellos.** La solidaridad es excepcional, puede ser **convencional, legal y testamentaria**.

El régimen de responsabilidad –este listado de ventajas- no opera de esa manera, ya que en el caso de las sociedades colectivas civiles y mercantiles, los socios si responden de las deudas sociales, en un criterio subsidiario o de segundo grado que ha señalado la doctrina (en virtud del artículo 2053 y 2095)

Donde sí hay una separación absoluta (en donde el inciso segundo del artículo 2052 opera de manera absoluta) es en el caso de las sociedades de capital, ya que en este caso los socios nunca responden con su capital de las deudas sociales.

Cuando revisemos la definición del artículo primero de la ley de SA, se define la sociedad como una personalidad jurídica. La ley no enuncia esa figura como un contrato, sino que es una persona jurídica.

## 6. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

**¿Cómo termina la sociedad? R:** hay una serie de causales que se aplican como causales de término de las sociedades colectivas. Lo importante acá, es que las causales de término de una sociedad mercantil, son las que el Código civil contempla para las sociedades colectivas civiles.

El Coco en el artículo 407 dispone:

Art. 407. La sociedad colectiva se disuelve por los modos que determina el Código Civil.

En materia de término de una sociedad colectiva, la forma y las causas de terminación son aquellas establecidas en el código civil (artículo 2098 y siguientes y artículo 407 del coco)

El segundo punto muy importante es que, **DISUELTA LA SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL, TERMINA LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y SURGE ENTRE LOS CONSOCIOS UNA COMUNIDAD. DISUELTA UNA SOCIEDAD COLECTIVA MERCANTIL, SUBSISTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA PARA LA APLICACIÓN DE UNA SERIE DE REGLAS DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD QUE ESTÁN ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 407 Y SIGUIENTES DEL COCO. (IMPORTANTE)**

Entonces, en materia de terminación y disolución de una sociedad colectiva, se aplican las reglas del código civil para las sociedades colectivas civiles y comerciales. Pero disuelta una sociedad colectiva civil, deja el atributo de la personalidad jurídica y pasamos a un cuasicontrato de comunidad, en el caso de la sociedad colectiva mercantil esto no pasa, ya que subsiste la personalidad jurídica para efectos de liquidación.

En materia de sociedades colectivas civiles, al nacer una **comunidad ¿Qué reglas se aplican?** Según el Código Civil no se puede obligar a ninguna persona a mantenerse en comunidad. Se puede pactar indivisión, aunque por un periodo de tiempo (5 años).

#### **6.1. Causales en específico que ponen término a la sociedad colectiva:**

- a. **Expiración del plazo o cumplimiento de la condición, ambas modalidades pactadas para el término de la sociedad.**

**Si las partes pactaron un plazo o condición, vencido el plazo o cumplida la condición resolutoria la sociedad termina.**

De este modo lo dispone el artículo 2098 del CC., Quedando a salvo la posibilidad de continuación de la sociedad mediante un pacto de prórroga que exige acuerdo unánime de los socios. No hay inconveniente que los estatutos sociales contemplen una prórroga automática; sin perjuicio la cláusula de prórroga puede contemplar la facultad de dejarla sin efecto mediante aviso oportuno del socio que manifiesta su voluntad de no continuar con la sociedad, y que ella termine al vencimiento del plazo pactado al momento de la constitución cumpliendo ciertas formalidades. (Para el caso de Soc. colectiva comerciales ver art. 350 del C.com.).

**Vencido el plazo sin pacto previo de prórroga, la sociedad que irrevocablemente disuelta.**

- 
- b. **Término del negocio para el cual fue constituida la sociedad:** por ejemplo, se puede constituir una sociedad con el señor Francisco Avaria y con Vicente Rodrigo para levantar un evento universitario y puede constituir esa sociedad para ese solo objeto. Por lo que cuando termina el evento, termina la sociedad.

**Es común que se pacte para disolución de una sociedad, el participar en la construcción de proyectos.**

El común que se pacte como causal de disolución de una sociedad el término del negocio que motivó su constitución en casos obras de construcción. Pactado un plazo de vigencia de la sociedad para la ejecución de un negocio específico y transitorio, prima el plazo como causal de terminación; salvo prórroga pactada, ya que el evento negativo de la no conclusión de negocio para el cual fue constituida la sociedad no provoca ipso iure la prórroga (art. 2099 CC.)

- c. **Insolvencia:** aquí hay ciertas particularidades por la ley 20.720 que derogó el sistema de quiebre y derecho concursal vigente y aplicó otro. Esto lo veremos cuando terminemos el ciclo de comercial

**En este caso, al profesor le basta que lo internalicemos como una causal, ya que el cambio de la ley 20.720 es radical, lo que implicaría adelantarnos mucha materia.**

El análisis doctrinal sobre la necesaria concurrencia o no de la declaración de quiebra ha quedado obsoleta desde la entrada en vigencia de la nueva ley concursal chilena número 20.720. En este sentido, la insolvencia en los términos del artículo 2100 del Código Civil. Excluye los casos de procedimientos reorganización o renegociación. En consecuencia, esta causal de disolución de la sociedad debiera aplicarse en los casos de liquidación voluntaria y liquidación forzosa que contempla la ley 20.720. El art. 2 de la ley pymes contextualiza el “estado de insolvencia” en la imposibilidad de pago de una o más obligaciones. Se trata de una insolvencia actual o potencial.

- d. **Pérdida total de los bienes que conformaron el objeto social**

Se trata de la pérdida total material o jurídica de los bienes que conforman el patrimonio social, que impide continuar con la ejecución del giro. No obstante, lo señalado, nuestra reciente doctrina comercial sostiene que es posible dar continuidad a la sociedad mediante la sustitución de tales bienes. En el caso de pérdidas materiales de bienes asegurados, el pago de la indemnización in natura o en dinero sustituye el bien, por consiguiente, no se configuraría esta causal. En los casos de pérdida parcial la sociedad subsiste, a menos que no pueda continuar la sociedad y los socios soliciten la disolución.

- e. **Incumplimiento de efectuar el aporte**

Vimos que, respecto del incumplimiento de efectuar el aporte en sociedades colectivas civiles, hay distintas interpretaciones en la doctrina. **Algunos autores sostienen que operaría la condición resolutoria tácita del artículo 1489, otros dicen que operaría simplemente la acción de cumplimiento** (exigirle al socio que cumpla con el aporte) por el nacimiento de un ente distinto. Pero el Código Civil le confiere en el artículo 2101 una especial facultad a los socios para que en aquellos casos en que el incumplimiento se deba a un hecho o culpa, ponerle término al contrato de sociedad.

- f. **Muerte de uno de los socios:** salvo que se pacte que se pueda continuar con los socios sobrevivientes o con los herederos de los socios.

Se justifica por el carácter personalista de este tipo societario. Salvo pacto contrario contenido en los estatutos de la sociedad, según lo dispone el art. 2103 del C.c. El o los herederos suceden al causante desde la perspectiva patrimonial, pero no como socio ¿Dese cuando se entiende disuelta la sociedad? Ver regla del art. 2103 inc. 2º.

- g. **Incapacidad sobreviniente de un socio (Art. 2106)**

**Se trata de aquellas incapacidades que sobreviene a la sociedad, no presente al momento del acto constitutivo (ya que sería nulo).** Es posible que la sociedad continúe mediante la representación legal de un curador.

- h. **Insolvencia sobreviniente de un socio (Art. 2106):** el estado de insolvencia, puede provocar que la situación patrimonial respecto del giro de la sociedad, le cause una mayor carga. Por eso el legislador entendía que una insolvencia sobreviniente, permite a los socios poner término a la sociedad.

El vocablo insolvencia del reenvía nuevamente a la ley 20.720. Nos parece que debieran primar los principios de conservación de los negocios propios de la nueva regulación concursal chilena limitando el supuesto de insolvencia a procedimientos de liquidación, sin perjuicio de continuar la sociedad mediante representación de los acreedores del socio deudor.

- i. **Acuerdo unánime de los socios (Art. 2107):** que no es otra que la aplicación del artículo 1545 del Código Civil.

- j. **Renuncia de cualquiera de los socios.**

**El carácter intuito personae de este tipo de sociedades justificaría el término de la misma por renuncia de uno de los socios. Por esta razón, la ley permite la continuidad siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos.**

La renuncia de cualquiera de los socios sería una causal de terminación de la sociedad. Esto fundamentalmente por el carácter intuito personae de la sociedad colectiva. La doctrina ha señalado que debe hacerse una distinción para los efectos de aplicar la regla de término por causal de renuncia:

- **Si la sociedad fue constituida para un negocio específico o por un tiempo limitado** (duración o vigencia limitada, sujeta a plazo), la regla general es que no procede la renuncia del socio. Solo procedería la renuncia del socio en aquellos casos en que el pacto social permita la renuncia del socio o que concurra alguna causa grave.
- **Si la sociedad tiene duración indefinida,** en ese caso no debe expresarse causa para que proceda esta figura.

Para que la renuncia tenga efectos debe (Art. 2109, 2110, 2111, 2112)

- 
- Notificarse a los socios (Art. 2109)
  - Debe ser hecha de buena fe (Art. 2101 y 2111): renuncia de mala fe el socio que lo hace por apropiarse de una ganancia que debía pertenecer a la sociedad, en este caso, podrán los socios obligarle a partir con ellos las utilidades del negocio y a soportar exclusivamente las pérdidas si el negocio tuviere malicia.
  - No debe ser intempestiva (Art. 2110 y 2112): renuncia intempestivamente el socio que lo hace cuando su separación es perjudicial para los intereses sociales. Esta es una norma bastante laxa de interpretación.

Lo más importante es que todas estas causales de disolución de la sociedad, son las mismas causales que se le aplican a la sociedad colectiva mercantil que está regulada en el Coco. La similitud que existe en el término de la sociedad es la concurrencia de causales para las sociedades colectivas mercantiles y civil, la diferencia es la subsistencia de la personalidad jurídica que si se da en las sociedades colectivas mercantiles y no se da en las sociedades colectivas civiles.

Miércoles 5 de septiembre de 2018

Vimos la clase anterior, las causales de disolución de la sociedad colectiva. Estas causales de disolución son las mismas que se aplican a la sociedad colectiva civil. En general se aplican para todo tipo de sociedades, especialmente para sociedades de personas.

## 6.2. Formalidades de la disolución

No todas las causales enunciadas operan de pleno derecho. Hay necesidad de declaración en algunas.

Hay causales ipso iure: se verifica la causal y los efectos operan:

- Expiración del plazo o cumplimiento de la condición, ambas modalidades pactadas para el término de la sociedad
- Término del negocio para el cual fue constituida
- Acuerdo unánime de los socios (formalidad colectiva comercial (Art. 350 coco))
- Renuncia de cualquiera de los socios (formalidad colectiva comercial (Art. 350 coco))

Salvedad: En las sociedades colectivas comerciales, no obstante, operar de pleno derecho e ipso iure, hay **ciertas causales que requieren o exigen el cumplimiento de determinadas formalidades**. Cuando la causal de acuerdo unánime o de renuncia de cualquiera de los socios concurre respecto de una sociedad colectiva mercantil, **deben cumplirse las formalidades que la ley establece para constituir una sociedad de esas características**.

En el caso de las sociedades mercantiles comerciales **¿Cuáles son los requisitos para que una sociedad comercial se constituya (requisitos legales)?** R: escritura pública y la inscripción en el registro de comercio. Lo que se inscribe en el registro de comercio es el extracto de la escritura pública. Para constituir una sociedad colectiva comercial, el pacto consta por escrito en un instrumento público que se denomina escritura pública. Esta escritura es cerrada y certificada a un notario. Se elabora un extracto que es un papel que contiene un párrafo largo y extenso dependiendo de las

estipulaciones. Y ese extracto lo llevamos materialmente al conservador de bienes raíces y este conservador lo inscribe en el registro de comercio.

Luego que el conservador inscribe el extracto, lo revisa con la escritura pública (cotejo). No puede haber error entre el extracto que certificó el notario y el que se inscribe en el registro. Cuando esto está listo, esto se deja (el extracto) en el diario oficial de Chile y este lo publica íntegramente (aunque en las sociedades colectivas mercantiles esto no es necesario, en las de responsabilidad limitada si lo es) tal cual consta en el registro de comercio. Debe ser igual el papel que elabora el notario, lo que inscribe en el conservador de bienes raíces en el registro de comercio y lo que se publica.

Las menciones del extracto son las que se refieren al artículo 354 del Código de Comercio. En el 352 establece lo que debe llevar la escritura como mínimo.

**En el caso de las sociedades colectivas mercantiles o comerciales dice el artículo 350 inciso segundo:** *“La disolución de la sociedad que se efectuare antes de vencer el término estipulado, la prórroga de éste, el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de la razón social y en general toda reforma, ampliación o modificación del contrato, serán reducidos a escritura pública con las solemnidades indicadas en el inciso anterior”*. Entonces, si se pone término a un negocio por mutuo acuerdo o por renuncia de cualquier socio e implica una modificación de los estatutos, debemos cumplir las formalidades del inciso primero del artículo 350.

Cuando estamos en presencia de una sociedad colectiva civil, la expiración del plazo o del término del negocio, produce sus efectos y los socios no pueden desconocer la ocurrencia de esa causal, porque fueron ellos los que participaron en la constitución del pacto social.

**Luego tenemos ciertos tipos de causales de disolución que operan pero que requieren de resolución judicial** (no opera de pleno derecho).

- **En el caso de la insolvencia**, como en el sistema concursal fue sujeto a una reforma. Cuando la ley hace referencia a la insolvencia, debemos entender dos supuestos:
  - La resolución judicial que acoge la solicitud de un deudor de someterse a un procedimiento de liquidación voluntaria
  - La resolución judicial que se pronuncia por la solicitud de un acreedor de una liquidación forzosa. Hoy no existe declaración de quiebra. Cuando nos referimos a la insolvencia, la doctrina y jurisprudencia previo a la ley señalaban que debía concurrir una resolución de quiebra. Esto ya no existe, porque la ley de quiebra fue derogada.

**¿Qué otro caso requiere de resolución judicial? R:**

- **Pérdida total de los bienes que conforman el objeto social**
- **El incumplimiento de efectuar el aporte:** los socios pueden solicitarla judicialmente.
- **Muerte de uno de los socios** (en concreto la resolución del tribunal que da cuenta de la muerte del socio y que dicta la posesión efectiva de los herederos)
- **La incapacidad sobreviniente de uno de los socios:** que se declare interdicto a una persona (resolución judicial también).
- **Insolvencia sobreviniente de un socio** (Resolución de liquidación voluntaria o forzosa)

### 6.3. Los efectos de la disolución:

Disuelta la sociedad procede su liquidación de acuerdo a la regla general de partición.

- **Hay que hacer la distinción respecto de las partes y respecto de terceros:**
  - Respecto de las partes la resolución producirá sus efectos una vez que las partes tomen conocimiento de concurrencia de la causal respectiva. Y se formará una comunidad.

En estos casos, para los efectos de la liquidación se aplican las reglas generales en materia de partición.

**Pregunta de prueba:** Las causales de disolución de la sociedad colectiva mercantil: son las mismas de la sociedad civil (art. 407 del Coco). **Si la sociedad colectiva comercial termina por una causal de disolución la personalidad jurídica subsiste.** Por otro lado, la sociedad mercantil **NO** se liquida conforme a las normas de partición de la sociedad civil. Esta es una diferencia.

- Respecto de terceros, Artículo 2114 del Código Civil.

Art. 2114. La disolución de la sociedad no podrá alegarse contra terceros sino en los casos siguientes:

- 1º. Cuando la sociedad ha expirado por la llegada del día cierto prefijado para su terminación en el contrato;
- 2º. Cuando se ha dado noticia de la disolución por medio de tres avisos publicados en un periódico del departamento o de la capital de la provincia, si en aquél no lo hubiere;
- 3º. Cuando se pruebe que el tercero ha tenido oportunamente noticia de ella por cualesquiera medios.

**En el caso de las sociedades colectivas mercantiles, es importante que deban cumplirse los requisitos o formalidades que referimos al artículo 350 inciso segundo.** La publicación (esta no es necesaria en la colectiva mercantil, pero sí en la de responsabilidad limitada) e inscripción son formalidades que tienen por objeto dar publicidad a la ocurrencia de ciertos actos jurídicos, en este caso a la constitución, a la modificación o el término de una sociedad colectiva mercantil.

### III.

## SOCIEDADES EN COMANDITAS

### 1. ORIGEN Y CONCEPTO

Las sociedades en comanditas, es el germen de los sistemas asociativos que surgen en la edad media. En esta época los regímenes societarios se enmarcaron en la encomienda, donde una de las partes encargaba la gestión de un negocio concreto a otro.

Los procesos de codificación del siglo XIX recogieron la conformación de un tipo societario o asociativo que de acuerdo a nuestro Código Civil (Art. 2053) tendría personalidad jurídica, que se denomina sociedad en comandita. Estas sociedades en comanditas están reguladas en los artículos **470 y siguientes del Coco.**

Art. 470. Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o sus delegados y en su nombre particular.

Llámense los primeros socios comanditarios, y los segundos gestores.

Se pueden distinguir dos tipos de socios: **los socios comanditarios** que realizan un aporte itinerario o en bienes (apreciados en dinero) y **los socios gestores** que se encargan del desarrollo del giro social pactado en las sociedades. Lo importante de la distinción, es que hay un régimen de responsabilidad distinto para el caso de los socios comanditarios, respecto de los gestores. En el caso de las sociedades colectivas civiles y mercantiles, vimos que todos los socios respondían de la misma manera, pero que estaban sujetos a un mismo régimen de responsabilidad. **En el caso de las sociedades colectivas civiles**, los socios responden de forma simplemente conjunta o mancomunada (los socios responden ilimitadamente con sus bienes, pero es una responsabilidad en segundo grado). **En el caso de las sociedades colectivas mercantiles**, la responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada.

En el caso de las sociedades en comandita, existe un régimen distinto para la responsabilidad de los socios gestores y para la de los comanditarios.

**Hay dos especies de sociedades por comandita:** las sociedades en comandita simple y las sociedades en comandita por acciones.

Art. 471. Hay dos especies de sociedad en comandita: simple y por acciones.

Art. 472. La comandita simple se forma por la reunión de un fondo suministrado en su totalidad por uno o más socios comanditarios, o por éstos y los socios gestores a la vez.

Art. 473. La comandita por acciones se constituye por la reunión de un capital dividido en acciones o cupones de acción y suministrado por socios cuyo nombre no figura en la escritura social.

El capital de la sociedad en comandita por acciones, es suministrado por los socios comanditarios y que luego es dividido en acciones. Luego tenemos a los socios gestores.

Los requisitos que deben cumplirse para que se forme una sociedad en comandita simple o por acciones:

- Cuando constituimos una sociedad en comandita (contrato) debemos comprobar que tengan los elementos de todo contrato: **voluntad exenta de vicios, objeto y causa, capacidad y solemnidades**
- **Además, los requisitos especiales:** Debe haber **afectio societatis, estipulación de aportes y fines de lucro (reparto de utilidades o ganancias)**.

La sociedad en comandita puede tener como objeto uno civil o uno mercantil. **Si es civil va a ser consensual y si es comercial, es solemne.**

Miércoles 12 de septiembre de 2018

Esta clase terminaremos con las sociedades de personas. En las sociedades en comanditas, esta particularidad *intuitu personae*, se diluye y nos vamos acercando cada vez más a la estructura de una sociedad de capital.

En términos generales de acuerdo a lo que hemos visto **¿Cuál creen ustedes que es la diferencia más evidente y relevante entre una sociedad de personas y una de capital?** R: la relación de confianza recíproca. Por eso la sociedad de personas tiene esa calidad. Por eso el mandato es un contrato donde uno más puede observar esta calidad *intuitu personae*. En las sociedades de capital no aparece este carácter, ya que solo es importante los aportes.

Esta absoluta del factor de confianza que existía hace 20-30 años atrás, ha sufrido matices importantes en las sociedades de capital. Si vamos a la bolsa o un establecimiento bursátil, hoy se fijará cual es el comportamiento de esa sociedad o a que grupo empresarial está inserto. Hoy no es tan absoluto que este factor esté totalmente desarraigado en las sociedades de capital.

Sigamos con las sociedades en comanditas.

## **1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN**

El origen es la encomienda, donde hay una parte que le encarga a través de una colocación de un aporte, una gestión. Estaba destinado principalmente al comercio marítimo

¿Qué particularidades tienen?

- Están las sociedades en comanditas simples
- Están las sociedades en comanditas por acciones

En ambos casos, podemos distinguir dos tipos de socios: el socio gestor y el socio comanditario. Lo relevante o lo que destaca, **es que el estatuto de responsabilidad del socio comanditario respecto**

**del socio gestor**, es absolutamente diferente. Aquí hay una ruptura en la clasificación que hemos presentado en el transcurso del semestre, respecto del estatuto de la responsabilidad.

En las sociedades colectivas civiles **¿Cuál es el régimen de responsabilidad?** R: responden los socios ilimitadamente de las deudas sociales. Y la responsabilidad entre los socios es una responsabilidad en donde podemos observar que hay una pluralidad en sujetos pasivos. Esto significa que es la regla general, **simplemente conjunta**. En el caso de las colectivas mercantiles responden de forma ilimitada y solidaria.

a) **En el caso de las sociedades en comanditas los socios gestores responden como si fueran socios de una sociedad colectiva.** En el caso de la sociedad en comandita simple que puede tener objeto civil o mercantil, el socio gestor responderá bajo el régimen del socio colectivo civil o mercantil como corresponda.

b) **En el caso de las sociedades en comanditas por acciones, son siempre mercantiles y los socios gestores van responder bajo el régimen de responsabilidad que se aplica a los socios de una sociedad colectiva mercantil.**

**Pero en el caso de los socios comanditarios: ¿Cómo responden?** R: el socio comanditario responde limitadamente hasta el monto de su aporte o hasta el monto del valor de la acción en el caso de las comanditas por acciones. Esta es la particularidad más relevante que podemos observar en la sociedad en comandita.

## 2. CONSTITUCIÓN

- **¿Cuáles son los requisitos para constituir una sociedad en comandita simple?**
  - **Los mismos que tienen que concurrir para toda sociedad o contrato. En el caso de que la sociedad de comandita simple sea civil no tiene ninguna formalidad y se ajusta a las reglas de la colectiva civil (consensual).** Pero se aconseja que se deje por escrito para efectos probatorios.
  - **Si se trata de una sociedad en comandita de objeto mercantil,** deben cumplirse las solemnidades para las mercantiles: escritura pública e inscripción del extracto en el registro de comercio.

El artículo 474 lo establece:

Art. 474. La comandita simple se forma y prueba como la sociedad colectiva, y está sometida a las reglas establecidas en los siete primeros párrafos de este Título, en cuanto dichas reglas no se encuentren en oposición con la naturaleza jurídica de este contrato y las siguientes disposiciones.

Veremos, sin embargo, algunas particularidades especiales. Dijimos que los requisitos eran la escritura pública y la inscripción del extracto. La particularidad es que el nombre de **los socios comanditarios no figura en el extracto**. El nombre del comanditario (del que aporta en el capital) no figura en el extracto. Veremos después que, en las sociedades en comandita por acciones, los comanditarios no figuran ni siquiera en la escritura pública de constitución de la sociedad. En el caso

de las simples, el socio comanditario está semi oculto, ya que no aparece en el registro de comercio, sino que solo en la escritura de constitución. Pero además **el nombre de un socio comanditario no puede ser incluido en la razón social de la escritura**. Es decir, en una sociedad en comandita simple, el socio comanditario solo aparece en la comparecencia de la escritura, pero no aparece en el nombre o en la razón social de la cláusula correspondiente de la escritura de constitución y tampoco aparece el nombre en el extracto.

Esto tiene origen histórico, ya que los miembros de la aristocracia no participaban en el comercio por considerarlo deshonoroso y quienes pertenecían al clero no podían ejercer el comercio. Entonces se creó esta figura que viene de la comanda, precisamente para que los aristócratas o los miembros del clero pudieran ejercer una actividad mercantil de forma oculta. Luego, esta dimensión histórica tendrá una aplicación importante en el tiempo, porque de alguna manera el socio capitalista busca obtener rendimiento del capital, pero no aparecer de manera tan evidente en la gestión de una sociedad o negocio concreto. **¿De quien se querrá ocultar el socio comanditario?** R: de los acreedores de la sociedad.

Este tipo de sociedades van en decadencia o desuso (principalmente por la transparencia actual), pero existen y se usan. Es muy **importante esta particularidad de las sociedades en comandita simple respecto del socio comanditario (no aparece en el extracto (solo para las mercantiles) ni en la razón social)**. Tanto de objeto civil como mercantil.

**En cuanto a la razón social, si es de objeto civil los socios tienen plena libertad y en el caso de la sociedad en comandita mercantil deben incluirse el nombre de los socios gestores y se excluye el de los comanditarios. (Art. 476)**

Art. 476. La sociedad en comandita es regida bajo una razón social, que debe comprender necesariamente el nombre del socio gestor si fuere uno solo, o el nombre de uno o más de los gestores si fueren muchos.

El nombre de un socio comanditario no puede ser incluido en la razón social.

Las palabras y compañía agregadas al nombre de un socio gestor, no implican la inclusión del nombre del comanditario en la razón social, ni imponen a éste responsabilidades diversas de las que tiene en su carácter de tal.

### 3. ADMINISTRACIÓN

En las sociedades en comanditas la administración corresponde siempre a los socios gestores. La regla general es que le está inhibido al socio comanditario ejercer una actividad de administración en la sociedad. Que por lo demás sería absurdo, porque no se entendería oculto el socio comanditario.

**La doctrina y la jurisprudencia ha señalado que el socio gestor no tiene una relación de vínculo o de subordinación (dependencia/laboral) respecto de la sociedad en comandita.** No recibe una remuneración, sino que lo que recibe a cuenta de la gestión es la participación en las utilidades del negocio.

**La regla general es que el socio comanditario no puede intervenir en la administración y solo tendrá derecho a voz.** (art. 484 y 485). Aquí volvemos al límite de la responsabilidad. El socio comanditario responde hasta el monto de sus aportes (responsabilidad limitada) y el socio gestor responde de la misma manera que un socio de una sociedad colectiva.

El artículo 480 dispone:

Art. 480. Los comanditarios tienen la responsabilidad que impone y el derecho que otorga a los accionistas de las sociedades anónimas el artículo 456.

Como el artículo 456 del Cocio fue derogado (ya que las sociedades anónimas están reguladas en la ley de sociedades anónimas 18.046), la interpretación que debe hacerse del artículo 480 es **entender que el socio comanditario responde de la misma manera que el de una sociedad anónima: limitado a sus aportes** (que en una sociedad anónima es limitado al valor de la acción).

Lo mismo ocurre en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. En ese caso ¿Qué expresión debe tener la razón social para que se cumpla con el presupuesto de la limitación de responsabilidad? R: "LTDA". Esto debe ser en la cláusula de la razón social. En caso de duda se entiende que es colectiva (Art. 490).

Por lo tanto, el socio comanditario responde de la misma manera que un socio de una sociedad anónima y que uno de una sociedad de responsabilidad limitada.

#### **4. CESIÓN DE DERECHOS**

Otra de las diferencias respecto de las sociedades de personas, está en la normativa de cesión de derechos. Sabemos que en las colectivas hay limitación, pero en materias de sociedades en comanditas, **el comanditario puede ceder sus derechos, no hay limitación**. Este factor de cesión de derechos, es uno de los elementos que nos lleva a apartarnos del factor intuitu personae de la sociedad, recordemos que, en el caso de las colectivas, uno de los fundamentos de la limitación de la cesión de los derechos (que implica la incorporación de un tercero y que exige el consentimiento de todos los socios restantes) estaba sustentado en el carácter intuitu personae. Como el comanditario puede ceder, se va diluyendo este carácter en esta sociedad.

#### **5. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**

Está regulada en los artículos 491 y siguientes y definida en el 473.

Art. 473. La comandita por acciones se constituye por la reunión de un capital dividido en acciones o cupones de acción y suministrado por socios cuyo nombre no figura en la escritura social.

En el caso de las sociedades en comanditas por acciones, esta finalidad de ocultación va más allá de la comandita simple, ya que el socio comanditario ni siquiera aparece en la escritura social.

##### **5.1. Constitución y requisitos**

**Debe haber escritura pública e inscripción del extracto (además de los requisitos de todo AJ).** Como la comandita por acciones es siempre mercantil, siempre debe cumplir con estas solemnidades. Pero hay ciertas solemnidades especiales que está relacionadas con la suscripción y pago del total del capital. Por lo tanto, en materia de sociedades en comanditas por acciones la doctrina ha señalado que se cumplen o deben cumplirse dos formalidades que se cumplen por etapa:

- 
- La escritura pública
  - La inscripción del extracto
  - El pago de la cuarta parte de las acciones suscritas por parte de los socios comanditarios

---

## IV.

### ASOCIACIÓN DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN

La sociedad de cuentas en participación está tratada en el título VII libro segundo en los artículos 507 a 511 y supletoriamente se le aplica las normas de la sociedad en comandita y en sociedad comercial.

Asociación es diferente de sociedad. Toda sociedad es asociación, pero no toda asociación es una sociedad. La principal diferencia es que las asociaciones no necesariamente tienen personalidad jurídica y no necesariamente tienen fines de lucro. En el caso de la de la asociación de cuentas en participación, no tiene personalidad jurídica, pero si debería tener fines de lucro al estar tratada en esta parte del Código de Comercio.

Art. 507. La participación es un contrato por el cual dos o más comerciantes toman interés en una o muchas operaciones mercantiles, instantáneas o sucesivas, que debe ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, a cargo de rendir cuenta y dividir con sus asociados las ganancias o pérdidas en la proporción convenida.

#### 1. ELEMENTOS

- **Es un contrato**
- **Existen entre dos o más comerciantes:** Uno es el asociado gestor y otro es el asociado partícipe u oculto.
- **Se trata de una o más operaciones mercantiles**
- **Que se ejecuta a nombre y riesgo del gestor, con obligación de rendir cuenta al asociado partícipe**

Esta definición tiene problemas. **Primero ¿es posible hacer una asociación respecto de comerciantes o puede haber no comerciante? ¿Solo puede versar sobre operaciones mercantiles?** Hay autores que señalan que solo pueden ser comerciantes y solo operaciones mercantiles, debido a la literalidad del artículo. Pero PUELMA señala que la liberalidad de nuestro derecho permitiría que existiera una asociación de cuentas en participación por no comerciantes y no de operaciones mercantiles. Esto porque el artículo 2060 del Código Civil dice que una sociedad no comercial, puede pactar que se rija por las normas de las sociedades mercantiles. Además, el artículo 508 permite que los asociados convengan sobre determinados elementos de la sociedad, entre ellos, su objeto.

**Otra característica es que es un contrato oculto.** Es un contrato consensual de carácter privado, no tiene personalidad jurídica, no tiene razón social, no tiene patrimonio propio, no tiene domicilio y además el gestor es el único dueño del negocio en cuanto a su relación con terceros. Los terceros solo ven al socio gestor. Puelma dice que es un contrato meramente vinculatorio respecto de los asociados, pero que además es inoponible respecto de terceros.

Siempre deben existir dos tipos de asociados: **siempre debe haber un socio gestor y un socio partícipe**. No se podría constituir una asociación solo con asociados gestores o solo con partícipes, según una parte de la doctrina (PUELMA). Según la otra parte, amparada en el 508, dice que da mucha libertad respecto de pactar todo lo referido a la asociación y por lo tanto podría darse una sociedad con solo gestores. En este sentido CERVANTES dice que sería una asociación colectiva en

---

**participación si las partes convienen asociarse para una o varias operaciones y contratar colectivamente bajo riesgo de todos.**

## 2. NATURALEZA

La doctrina se divide en dos planos. Algunos dicen que es una sociedad y otros que es una asociación que el Código trata bajo el título de la sociedad, pero que no se configuran los elementos para esto.

Los que no consideran que es una sociedad, argumentan que todas las sociedades tienen personalidad jurídica independiente de los socios. Además (italianos) señalan que los derechos de la sociedad son de participación directa y a título gratuito del resultado de esta gestión. Es decir, todos los socios tienen derecho a participación y además a título gratuito y en las sociedades de cuentas en participación, no todos los socios participan de la gestión propiamente tal.

Además, **VIVANTE** señala que otra de las características para no considerarla sociedad, es que existe una mayor rigurosidad respecto de la obligación de entregar algo a la asociación, porque en la sociedad no hay una personalidad jurídica distinta, sino que un patrimonio distinto. Entonces existiría una mayor rigurosidad de los socios que aportan en la sociedad a una tercera persona, que los asociados que aportan en este contrato.

Los que consideran que sí es una sociedad: PUELMA dice que la falta de injerencia en el partícipe no es decisoria. Esto se da también en la sociedad en comandita. Respecto del argumento de Vivante, dice que no es cierto que exista una menor rigurosidad respecto del aporte, tanto el partícipe como el gestor en la asociación de cuentas de participación tienen que aportar algo, lo que pasa es que el gestor aporta la administración. El socio partícipe aporta cualquier otra cosa.

**PUELMA** se pregunta si puede existir una asociación de cuentas en participación, sin cumplir los requisitos esenciales de la sociedad: que exista un beneficio para los socios, que exista un aporte de los socios a la sociedad y que los socios tengan derechos a beneficio social y que soporten las obligaciones sociales. **PUELMA** dice que si a todo.

Por último, **PUELMA** dice que nuestro legislador dice que es una sociedad. en el artículo 508 inciso segundo, por ejemplo, habla de socios. Además, la trata dentro de las sociedades. incluso, pone de normas supletorias las de la sociedad en comandita y de la colectiva. Por lo tanto, Puelma la considera como una sociedad a pesar de no tener personalidad jurídica.

## 3. EFFECTOS

- a. **Respecto del socio gestor**, el efecto de esta sociedad es que está obligado a efectuar las negociaciones con terceros y está obligado a rendir cuentas al socio partícipe.
- b. **Respecto del socio partícipe**, este está obligado a realizar un aporte a la asociación (puede ser un inmueble, dinero, etc.). Debe ser un aporte diferente de la administración, sino sería gestor.
- c. **Es inoponible a terceros.**

- 
- d. **Es exclusivamente mercantil:** está tratada en el código de comercio. Si aceptamos la teoría de que pueden conformarla personas no comerciantes y en operaciones no mercantiles, aun así se rige por las normas del Código de Comercio
- e. Si entendemos que es una sociedad, **sería un contrato pluripersonal**, que puede ser de dos o más personas.

#### 4. LIQUIDACIÓN

El Código de comercio les da mucha libertad a los asociados para determinar muchas cosas. Por lo tanto, si falta un pacto respecto de la liquidación o como se efectuará, hay una parte de la doctrina que dice que tenemos que ir a las reglas de las sociedades mercantiles, especialmente la colectiva, porque es la norma supletoria de esta asociación (solo cuando no hay pacto).

**Pero hay otra parte de la doctrina** que dice que en virtud del artículo 221 N° 1 del Código de Procedimiento civil **(no me sale cuando lo busco, así que asumiré que era el 227 del Código orgánico de tribunales, porque esa norma habla del arbitraje forzoso ☹)**, sería un arbitraje forzoso realmente. Esto porque esta asociación genera una verdadera comunidad respecto de los bienes aportados, entonces independiente de su carácter mercantil y de que existan supletoriamente normas de las sociedades mercantiles, se debería aplicar de forma supletoria, salvo las modificaciones resultantes de la naturaleza jurídica y la naturaleza jurídica sería que sea una comunidad, que es materia de arbitraje forzoso.

Miércoles 26 de septiembre de 2018

## V.

# SOCIEDADES ANÓNIMAS

### 1. ANÁLISIS HISTÓRICO E IMPORTANCIA ECONÓMICA

Las sociedades anónimas tienen una relevancia económica, a partir del siglo 20 en adelante. Hoy en día generalmente las grandes empresas de los grupos económicos, están estructurado sobre la base de las sociedades anónimas. Esto por dos razones:

- a. Forma de obtener financiamiento del público en general para poder iniciar el desarrollo o puesta en marcha del objeto para el que fue constituida la sociedad
- b. O para la continuación de giro o de la actividad de la sociedad anónima en concreto a través del aumento de capital.

Por esta razón cumple un rol fundamental en la sociedad. Eso, por una parte. Por otro lado, como hemos ido mencionando, **hay ciertos giros o actividades que en nuestro ordenamiento jurídico solo se pueden ejecutar a través de una tipología societaria particular** (sociedades anónimas) como los bancos, fondos de inversión, compañías de seguros, etc. Estas son las ventajas que podemos identificar en esta tipología societaria.

Además, en virtud de la libre cesibilidad de ir transfiriendo el derecho social representado en la acción, se limita la responsabilidad de los socios al aporte que efectuó a través de la acción que adquiere en relación a la constitución de la sociedad. Hay una ausencia de responsabilidad de los socios, por regla general no responden de su patrimonio propio por el desarrollo del objeto social, salvo el valor de la acción. **El compromiso patrimonial del socio con la sociedad, está limitado al valor de la acción.**

Todas estas sociedades de capital están vinculadas con el emprendimiento de nuevas empresas, nuevas ideas a través del aporte o financiamiento de la parte que pone el capital y la empresa que ejecuta este financiamiento.

Las sociedades anónimas nacen o tienen su origen en los grandes emprendimientos comerciales que fueron desarrollados por los holandeses e ingleses especialmente en el siglo XVIII en adelante, a través de una figura muy especial que se llamaba **Octrooi**. Esta era una carta especial que emitía el estado (representando por el monarca) y que autorizaba el desarrollo o la ejecución de una empresa (de carácter marítimo de búsqueda de riqueza) y que era generalmente vinculada a esta figura de estado o autorización. **Esta intervención del Estado representado por el monarca, se va a mantener en el tiempo, incluso respecto de las primeras regulaciones en materia de sociedades.** El monarca tuvo una gran influencia en el origen y nacimiento de estas sociedades.

Hay varias sociedades o emprendimientos relevantes, estas ejemplifican el germen inicial de estas sociedades anónimas. De estructuras societarias que tienen su fundamento en la posibilidad de captar dinero del público para el desarrollo de su giro.

**En cuanto al desarrollo histórico en Chile:**

- **La primera ley fue la de sociedades anónimas de 1854** que reconoce la posibilidad de constituir sociedades de capital. Nace para un emprendimiento concreto que era el ferrocarril Santiago-Valparaíso y que tenía las particularidades que incluso fueron recogidos por el Código de Comercio de 1865.
- **El Código de Comercio de 1865 regulará expresamente las sociedades anónimas.** Estas sociedades tenían ciertas características que la diferencian de la actual. Se regía supletoriamente por las normas de las sociedades colectivas comerciales y civiles. Eran sociedades de capital fijo, sin posibilidad de disminución. Tenían un consejo de administración que es lo que hoy llamamos directorio y este consejo de administración se regía por las normas de administración de las sociedades colectivas mercantiles. **La gran diferencia es que esta regulación inicial contenida en el Código de Comercio, era la libertad de cesión o libre cesibilidad de la acción y por tanto del socio.** Esta fue la diferencia que marcó este tipo societario respecto de las sociedades de personas. Subsiste la exigencia de autorización de existencia por decreto presidencial que venía contenido en la ley de 1854.
- **El decreto con fuerza de ley 251 de 1931** (control estatal) se crea la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y por primera vez las SA abiertas, quedarán sujetas a la supervigilancia o control de una entidad pública, un órgano estatal. En este punto histórico (1931) hay dos particularidades respecto de la constitución de una sociedad anónima: se requiere **siempre** de la autorización estatal para la constitución de una sociedad anónima y además está sujeta al control de la superintendencia de valores y seguros
- **En el año 1981 se dicta la ley 18.046** que la encontramos en el apéndice de cualquier código de comercio. La importancia de la ley 18.046 es que:
  - Deroga íntegramente la regulación de sociedades anónimas del Código de comercio.
  - Elimina la exigencia de la autorización pública, sin el decreto aprobatorio del presidente de la república.
  - Se elimina la fiscalización o supervisión de la SVS para las S.A cerradas, estas salen del marco de supervisión del órgano supervisor o regulador.
  - Se distingue entre S.A.A (sociedades anónimas abiertas) y S.A.C (sociedades anónimas cerradas).
  - Por último, en materia de resolución de controversias entre accionistas, o entre estos y la sociedad y sus administradores se reemplaza el sistema de arbitraje forzoso a cargo de la SVS por uno voluntario y opcional para la parte demandante.

**¿Es un arbitraje legal?** R: sí, porque la ley de SA lo contempla como solución de controversias (arbitraje)

- **Ley 19.705 del 2000 sobre reforma al mercado de capitales y en lo pertinente a la ley de S.A.** incorpora el régimen jurídico de las ofertas públicas de acciones y gobiernos corporativos.

**La ley de oferta pública de acciones es para proteger a los accionistas minoritarios.** De manera que los accionistas mayoritarios no puedan realizar transacciones o movimientos accionarios que

impliquen un movimiento del control societario, sin que los minoritarios tengan conocimiento o que incluso tengan posibilidad de acceso a la definición de acciones que se oferta.

**Las normas de regulación de gobiernos corporativos**, son normas que incorporan exigencias de buenas prácticas especialmente en materia de administración societaria, **para evitar en general dos problemas:**

- Que los actos de la administración perjudiquen el interés social en la dimensión de los accionistas minoritarios
- Que se perjudique o que se afecte la fé pública
- **Ley 20.382 de 2009 sobre gobiernos corporativos** (incorpora más exigencias del gobierno corporativa, destaca la regulación sobre comité de directores y directores independientes).
- Se agrega la ley 21.000 que reemplazó la SVS por la Comisión para el Mercado Financiero.

## 2. MARCO NORMATIVO

Hay dos normas que se cruzan en materia de sociedades anónimas: ley 18.046 y el reglamento de las Sociedades Anónimas (Decreto supremo 702). NO PUEDEN LEERSE SEPARADAMENTE.

La ley 18.046 se ocupa de:

- a. **Concepto y categorización** (art. 1)
- b. **Constitución** /Art. 4, 5, 5ª, 6, 6ª, 126, 127 y 128)
- c. **Nombre** (art. 8): complementado por el reglamento
- d. **Objeto** (art. 9): complementado por el reglamento
- e. **Capital social** (art. 10 y 11): complementado por el reglamento
- f. **Acciones y accionistas**
- g. **Administración:** el reglamento, regula en específico cómo funcionan los directorios, las sesiones, como deben conformarse y constituirse. Cuando nos refiramos o analicemos la ley, debemos leer el reglamento.
- h. **Juntas de accionistas:** la ley 18.046 hace referencia a juntas y especifica las ordinarias y extraordinarias, pero el funcionamiento está en el reglamento.
- i. **Filiales**
- j. **División, transformación y fusión**
- k. **Disolución y liquidaciones**
- l. **Arbitraje**

Otras normas importantes:

- Ley 18.045
- DFL 251
- Ley 19.499 sobre saneamiento de vicios de nulidad
- Normas emitidas por la SVS
- Leyes especiales para S.A Especiales

---

### 3. CONCEPTO

#### Artículo 1 ley SA. 18.046 (MEMORIA)

Art. 1° La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes (valor de la acción) y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables.

La sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil.

De esta definición, se desprenden estas particularidades:

- No es un contrato, es una persona jurídica.
- Es un fondo común, característica de las sociedades de capital.
- Ese fondo común se suministra por accionistas que responden solo por el valor de su acción

La particularidad de esta definición, está en que el legislador la define como una persona jurídica (se aparta del 2053 del Código Civil que la define como un contrato). **Lo que se quiere resaltar es esta división que se produce por una sociedad legalmente constituida y los socios desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial por los actos que ejecuta el ente social.** En este caso, propiamente tal, existe una verdadera separación entre el patrimonio del socio y el patrimonio social, en cuanto a la responsabilidad.

La sociedad anónima es siempre mercantil. Siempre se regirá por aquellas normas que regulan la ley de S.A (18.046 y complementarias) y las que regula el Coco en materia de sociedades mercantiles.

### 4. ELEMENTOS

Hay elementos confusos. Se confunden elementos de la estructura negocial, con las particularidades y características que tienen las sociedades como las sociedades anónimas. Se identifican como elementos a raíz de esto la:

- **Personalidad jurídica**
- **Administración centralizada**
- **Libre transferencia de acciones**
- **Responsabilidad limitada**

Por su parte Guerrero y Zegers distinguen como elementos:

- **Personalidad jurídica**
- **Fondo común**
- **Capital social suministrado por accionistas**
- **Responsabilidad limitada de los accionistas**
- **Administración especial**
- **Interés social como rector del giro social y por consiguiente de su administración**

Otros autores (María Fernanda Vásquez) más bien distingue entre características (más preciso). **A nuestro juicio lo que enuncian los citados autores se refieren a características y no elementos en su dimensión jurídico negocial. En este sentido, Vásquez Palma enuncia las siguientes características:**

- Se trata de una asociación de capitales
- Forma una personalidad jurídica
- Limitación de responsabilidad
- Administración a cargo de un órgano especial denominado directorio
- Es siempre mercantil.

**En cuanto a los elementos esenciales en la dimensión contractual de una sociedad anónima, serán los mismos que cualquier otro contrato.** Debe haber: voluntad exenta de vicios, objeto y causa. Además, deben de cumplirse los requisitos que se desprenden en el derecho de sociedades.

¿Qué elemento como esencial que analizamos está ausente en la Sociedad Anónima? R: **La que no está presente es la *afectio societatis* (discutible), ya que las sociedades de capital**, nosotros no nos incorporamos al ente societario por los demás socios, sino que la motivación está más bien vinculada con la rentabilidad propia del negocio, incluso en S.A con intereses especulativos. No me interesan los socios, lo que, si me podría interesar, es **quien administra.**

#### 5. INTERÉS SOCIAL (¿Elemento?)

No está definido en la ley. No hay ninguna norma que lo definan o lo expresen. La doctrina ha entendido que es el interés vinculado a la ejecución del giro y a la obtención de beneficio o lucro pactado al momento de constituir la sociedad y que no puede ser vulnerado, trastocado o dejado de lado, por el órgano de la administración que es el directorio.

Por eso, la doctrina ha desprendido la existencia de este interés social de los denominados **deberes fiduciarios** que son deberes de fidelidad y lealtad que recaen en la persona que tienen el carácter de director del directorio de la sociedad.

Hay una serie de normas que regulan la conducta de los directores de la sociedad. Estas normas tienen por objeto evitar que este directorio tome decisiones que perjudiquen el resultado final del desarrollo del objeto social, que provoca un perjuicio a los accionistas (dueños finales de este tipo de sociedad)

#### 6. TIPOS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

**Podemos identificar 3:** Sociedades anónimas abiertas (S.A.A), Sociedades anónimas cerradas (S.A.C) y Sociedades anónimas especiales (S.A.E.)

**Artículo 2 de la ley de S.A.A:**

Artículo 2°. Las sociedades anónimas pueden ser de tres clases: abiertas, especiales o cerradas.

**Son sociedades anónimas abiertas aquellas que inscriban voluntariamente o por obligación legal sus acciones en el Registro de Valores.**

Son sociedades anónimas especiales las indicadas en el Título XIII de esta ley.

Son sociedades anónimas cerradas las que no califican como abiertas o especiales.

#### 6.1. **Sociedades Anónimas Abiertas:**

Lo importante es que sepamos que son las que transan sus acciones en bolsa. **Estas sociedades son aquellas que se inscribirán voluntariamente o por obligación legal en el Registro de Valores.**

- Voluntariamente: esto quiere decir, que se somete a un mecanismo de transacción o cesibilidad de esas acciones en bolsa.
- Y hay otros casos en que obligatoriamente debe inscribirse en el registro de valores correspondiente. Esto según lo establece el artículo 5to de la ley de mercado de valores, en la letra c) (establece los casos).

##### Elementos diferenciadores:

- a) **En cuanto a su forma de financiamiento se financian con la caja social del público. SE TRANSA EN BOLSA**
- b) **Hay una serie de normas que tienen por objeto proteger a los accionistas minoritarios** (por ejemplo, las OPAS).
- c) **Están sujetas al control pública de la Comisión para el mercado financiero (CMF)**
- d) **Libre circulación de acciones, no se admiten restricciones por pacto**
- e) **Están sujetas a sistemas de auditoría:**

Todos los deberes de información, deberes de lealtad y fidelidad y sus normas reguladoras, son más estrictas en estas sociedades.

#### 6.2. **Sociedades Anónimas Cerradas:**

Son sociedades que NO se transan en bolsa y no ejecutan objetos que la ley restringió para cierto tipo específico de sociedades. Un banco nunca va a poder ser una sociedad anónima cerrada, ya que tiene que cumplir requisitos al ser especial.

##### Elementos diferenciadores:

- **En cuanto a la forma de financiamiento, el fondo o capital social se conforma por aporte privado, en el sentido opuesto a lo público o mecanismo de captación en el mercado de valores.**
- **No están sujetas a la fiscalización de la SVS**

- 
- **No se admiten pacto que limiten o restrinjan la libre cesibilidad de acciones**
  - Poseen una particularidad personalista o de confianza. Hay un **hibrido entre un factor personalista y de capital**.
  - Existe un germen no menor de affectio societatis en la conformación de la sociedad. Se constituye esta sociedad teniendo en cuenta a los demás socios, a diferencia de las abiertas.

### 6.3. Sociedades Anónimas Especiales

La característica más importante de este tipo, está en que la S.A.E. están sujetas a exigencias de ciertas formalidades en materia de constitución y exigencias de capital mínimo (para efectos de conformarse legalmente). Estas están reguladas en el artículo 126 de la ley 18.046 de Sociedades Anónimas.

Tienen mecanismos y órganos de fiscalización especiales según los casos, además de formalidades especiales de constitución y exigencias de capital mínimo para los efectos de formarse y constituirse legalmente. Unido a la autorización por parte de la autoridad.

### 6.4 Clasificación

Podemos identificar 3:

- S.A.A: son aquellas que se inscribirán voluntariamente o por obligación legal en el registro de valores de la SVS. En este último caso, el artículo 5 de la LMV precisa en qué casos deben inscribirse y para el caso concreto de las S.A (letras c y d)
- S.A.C: las que no se califican como abiertas o especiales. Que no se transan en bolsa y no ejecutan objetos que la ley restringió para ciertos tipos específicos de sociedades. Un banco no puede ser una cerrada nunca porque debe cumplir ciertos requisitos y particularidades.
- S.A.E: Son aquellas que tienen requisitos especiales establecidos por ley.

Jueves 27 de septiembre de 2018

## 7. CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

### a) **Regla general**

Una sociedad anónima del régimen ordinario es bastante simple de constituir. Se necesita una **escritura pública, se hace un extracto** (hecho en teoría por el notario, aunque en la práctica lo hacen los abogados), **se inscribe en el registro de comercio del domicilio de la sociedad y se publica en el diario oficial**. Antes requerían la autorización de la autoridad, era una superintendencia, un organismo, etc. Eso se eliminó por completo en el año 1981. Chile en comparación a otros países, es bastante liberal al eliminar esa autorización de la autoridad. Se inscribe en el registro de comercio del domicilio de la sociedad. Se publica en el diario oficial.

### b) **Sociedades anónimas especiales (Art. 126 y ss. LSA)**

**Son aquellas sociedades que por un mandato legal y por su rol en la sociedad, el legislador le pone requisitos adicionales.** El legislador no quiere que cualquier persona abra un banco o una compañía de seguro o una isapre. No se quiere que gente no preparada tome un rol social de estas características, incluso podría prestarse para fraudes.

Este artículo (126 y ss. LSA), **se complementa** con la ley especial del tipo de sociedad anónima especial. Por ejemplo, si se quiere constituir un banco, se va a la ley general de bancos.

La diferencia: ahora tengo que ir a la autoridad que regula a esas sociedades. Debe hacerse una escritura pública y se necesita una autorización de existencia (varía según la autoridad que lo emite: CMF, SBIF, Superintendencia de Pensiones, etc.). Es la propia autoridad la que realiza el extracto (verificando la escritura), que se llama **“autorización de existencia”**. Luego se inscribe en el registro de comercio del domicilio social y se publica en el diario oficial.

¿Cómo se computa el plazo? R: **en la ley de sociedades anónimas, para inscribir es de 60 días.** En las especiales el caso es particular, ya que si se demora mucho en inscribir por temas de burocracia estatal sería injusto para los socios. En estos casos el plazo de 60 días se cuenta desde que se emite el acto de la autoridad que autoriza la existencia (para inscribir y publicar)

#### 7.1. Menciones Escritura pública (Art. 4 LSA):

Estas reglas generales son aplicables a las otras sociedades anónimas.

- A. El nombre, profesión u oficio, el domicilio de los accionistas que concurren a su otorgamiento. Esto es evidente, ya que es un acto jurídico y siempre se debe individualizar a las partes que concurren con su voluntad a formar este acto.
- Hasta aquí es regla general, pero además es necesario individualizar a los socios que fundan la sociedad para determinar la responsabilidad solidaria de los socios en caso de nulidad.
  - Debe saberse el día en que se constituye, quienes van a ser los que responderán con su patrimonio.

Es requisito esencial: Requisito del A.J, de la E.P, y necesaria para determinar la responsabilidad de los socios en caso de nulidad.

#### B. El nombre y domicilio de la sociedad

- Nombre debe indicar “S.A” o “Sociedad anónima”: **Esencial.** Aquí se le dice al mercado que solo responde con el capital común
- El domicilio relevante para determinar **nacionalidad, conservador de comercio y juez competente.** ¿Es esencial? (Art. 5 A LSA), se estima que sí, pero supletoriamente va a ser la del lugar donde se celebró la escritura (por parte de la doctrina). El profesor estima lo contrario, al haber norma supletoria.

#### C. La enunciación del o de los objetos específicos de la sociedad

El objeto de una sociedad anónima puede ser muy amplio y puede ser más de uno. Esto es una innovación. Lo importante es que se especifiquen.

- Mención **esencial**
- **En este caso, no determina el carácter civil o mercantil de la sociedad. ¿Por qué? En este caso se reputa siempre mercantil.**
- **Determinante para ámbito de actuaciones de la administración** (Art. 40)
- **Giro social, para efectos tributarios.** El giro social cuando se inscribe en el SII, se extrae del objeto. La relevancia es que hay solo algunos giros afectos a IVA y otros no. El IVA se determina por la actividad que se desarrolla. Hay determinados impuestos que se les cobran a los habituales y no a los no habituales. Por ejemplo, si mi sociedad es inmobiliaria, es evidente que comprar y vender inmuebles es habitual.

Art. 40. El directorio de una sociedad anónima la representa judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social

La cancha está rayada en torno al objeto. Esta es la importancia de determinar bien en la escritura social, cual es el objeto.

**D. La duración de la sociedad, la cual podrá ser indefinida y, si nada se dice, tendrá este carácter:**

- Mención no esencial porque la misma ley da en el mismo artículo, que es que las sociedades anónimas tendrán el carácter de indefinida.
- Naturaleza de la S.A. como sociedad de capital (EJ: muerte de un socio de empresas Copec). Hemos visto las sociedades más intuitu persona a la reina de las sociedades de capital, aquí da lo mismo quien es el socio y si vive o muere.

**E. El capital de la sociedad, el número de acciones en que es dividido con indicación de sus series y preferencias si los hubiere y si las acciones tienen o no valor nominal; la forma y los plazos en que los accionistas deben pagar su aporte, y la indicación y valoración de todo aporte que no consista en dinero**

- Mención esencialísima: aquí consta el aporte
- Destinaremos la próxima clase a ver Capital y Acciones en detalle.

**F. La organización y modalidades de la administración social y su fiscalización por los accionistas**

- Autonomía de la voluntad limitada: siempre administra un directorio, hay requisitos al número de directores, Comité de Directores, etc. Está limitada porque debe ser administrada por un directorio. En las SAC son 3 directores, en la SAA son 5, etc.
- De todos modos, los accionistas deben acordar las cuestiones propias a la administración de la sociedad.
- El órgano directivo superior va a ser siempre el directorio y su regulación está por ley.

**G. La fecha en que debe cerrarse el ejercicio y confeccionarse el balance y la época en que debe celebrarse la junta ordinaria de accionistas**

- No es esencial
- Solución supletoria: el 99% de las sociedades cierra su ejercicio el 31/12 y la junta ordinaria de accionistas siempre se pronuncia el primer cuatrimestre de cada año.

- Podrían modificarlo, pero no es muy práctico.

#### H. La forma de distribución de las utilidades

- No hay sociedad si no participan de las utilidades
- **Regla general: a prorrata de sus acciones, pero puede haber series de acciones privilegiadas.** Existen acciones ordinarias y todas tienen el mismo derecho (nos llevamos los mismos derechos), y, por otro lado, se pueden diseñar las extraordinarias (por ejemplo, para atraer inversionistas) que gozan de derechos particulares, como más utilidad o poder designar a un director extra.
- Dividiendo mínimo de 30% de las utilidades líquidas anuales en las SAA. Esto se puede modificar solo por la unanimidad de los socios, aunque esto nunca se ve.

#### I. La forma en que debe hacerse la liquidación

- No es esencial
- Solución supletoria: título X LSA.

#### J. La naturaleza del arbitraje a que deberán ser sometidas las diferencias que ocurran entre los accionistas en su calidad de tales, o entre estos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación.

- No es esencial.
- **Solución supletoria:** arbitro arbitrador, designado por la justicia ordinaria. No les gusta mucho el árbitro arbitrador, porque no fallan conforme a la ley. Si se designa un arbitrador él puede tener un criterio de justicia diferente. Lo que se hace más común es el de derecho o el mixto.
- No se puede nominar a árbitros específicos en el estatuto, pero si se pueden determinar las normas para designarlos. No puede ser alguien con nombre y apellido.

#### K. La designación de los integrantes del directorio provisorio y, en las sociedades anónimas abiertas, de los auditores externos o de los inspectores de cuentas, en su caso, que deberán fiscalizar el primer ejercicio social.

- No es esencial. Aunque en la práctica es fundamental tener un directorio provisorio. Esto, ya que complica mucho hacer una junta de accionistas posterior, sin tener un órgano con que citarlos. Lo que se hace, es que en un artículo transitorio que no forma parte de los estatutos se dice “el director provisorio será tal persona” hasta la próxima junta de accionistas.
- Solución supletoria: los nombra posteriormente la junta de accionistas

#### L. Los demás pactos que acordaren los accionistas

- Espacio para autonomía de la voluntad, aunque no es tan así. Hay espacio para la autonomía de la voluntad, pero las SA por la función social que cumplen en una comunidad, van a estar sujetas a una serie de normas de orden público.
- Abundantes normas de orden público que no pueden ser modificadas. Ejemplos:
  - Se prohíben las acciones de industria (Art. 13 de LSA)
  - Se prohíben las limitaciones a la transferencia de acciones en el estatuto (Art. 14 LSA)

- Si los accionistas deciden que una SAC va a tener 2 directores, no valdrá la disposición porque son mínimo 3 directores
- Si se acordare que el gerente general tendrá un 20% de participación en el capital sin haber trabajado y solo es un socio industrial, esta disposición es nula.

**El plazo de inscripción de la escritura es de 60 días.** Debe tener las menciones del artículo 5 de la LSA. (Cuestiones principales). REVISAR ESTE ARTÍCULO.

## 8. MODIFICACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

Las cosas en el derecho se deshacen como se hacen. **¿Cómo conciliar esto con sistemas de mayorías, múltiples accionistas, etc.? Es imposible lograr que todos los accionistas firmen la modificación en una notaría.** Las sociedades anónimas, su órgano superior de administración es la junta de accionistas. Se citan conforme a los estatutos legales, acuden unos cuantos, se toma la decisión, por ejemplo, por el 70% de los que acudieron y esa acta se **reduce** a escritura pública y eso es lo que se inscribe y publica.

- a) La escritura pública se reemplaza por el acta de la junta extraordinaria de accionistas que acordó la modificación, **reducida** a Escritura pública. En aquellas juntas de accionistas en que se acuerden reformas o modificaciones a los estatutos sociales, debe estar presente el notario público.
- b) Un extracto de la misma se inscribe y publica, conforme las mismas reglas que la constitución
  - El extracto hará referencia al contenido de la modificación, solo cuando afecte alguna de las menciones del artículo 5 LSA.
  - El plazo es 60 días que se cuenta desde la reducción de escritura pública.
- c) **¿Qué pasa con las S.A.E?** R: el plazo se cuenta desde la reducción de escritura pública en las sociedades anónimas normales, pero en las especiales siempre se va a estar siendo fiscalizada por el órgano correspondiente, por lo que se cuenta desde la aprobación de la autoridad.
- d) Una vez inscrito y publicado dentro del plazo, se entiende modificado a la fecha de la escritura.
- e) Si se modifica algo que no está dentro de los numerales del artículo 5, el extracto solo dirá “que se modificó”
- f) En las modificaciones a los estatutos sociales debe estar presente el notario público

## 9. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES

A. **Nulidad de pleno derecho: Art. 6 A LSA** “la sociedad anónima que no conste de /i/ E.P., /ii/ **ni de instrumento reducido a E.P.**, /iii/ **ni de instrumento protocolizado, es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada**”. (La enumeración es nuestra). Es la más grave de las sanciones que contempla el derecho societario. Es diferente de la nulidad absoluta en derecho civil. La nulidad ipso iure es una sanción especial en materia de derecho societario que dice que “no existe”. Es una nulidad especial.

### a. Víctor Vial:

- i. No requiere ser declarada judicialmente.
- ii. No se sana por el transcurso del tiempo

- iii. Este artículo es un argumento a favor de la teoría de la inexistencia del A.J. Esta nulidad ipso iure, en nada se asimila a la nulidad absoluta del Código Civil. Es una propiedad, una sanción de inexistencia. Esta modificación social viene a ser uno de los principales argumentos para la inexistencia. Es de los pocos casos en que se dice que el acto no existe.
- b. **Sandoval:** única manera de revivirla es “repactándola”.
- c. ¿Qué hay entonces, si de hecho existía una S.A.? Hay una comunidad entre los miembros.
  - i. Distribución de utilidades y pérdidas, así como devolución de los aportes, se hará según lo pactado.
    - a. Si no se pactó nada, conforme a las reglas de la S.A (proporcional).
  - ii. Los miembros responden solidariamente frente a terceros con quienes hayan contratado en nombre y en interés de la sociedad. **Sanción grave.**

B. **Nulidad Saneable:** Art. 6 LSA.

- a. **Causales:**
  - i. Si la sociedad consta en instrumento reducido a E.P o protocolizado
  - ii. Si se omiten las menciones de los números 1,2,3 o 5 del art. 4 de la LSA.
  - iii. Si el extracto se inscribió o publicó tardíamente, o si no se ha inscrito.
  - iv. Si en el extracto se omite alguna de las menciones del artículo 5 LSA.
- b. **A diferencia de la nulidad ipso iure del artículo 6ª, esta nulidad si debe ser declarada judicialmente y es saneable.**
  - i. Si se declara judicialmente, la sociedad se disuelve y debe liquidarse. Conserva sin embargo la P.J. para efectos de liquidación.
  - ii. La acción de nulidad prescribe en el plazo de 4 años contados desde el acto viciado.
  - iii. ¿Qué pasa si el extracto se prescribe y publica en tiempo y forma, pero el contenido difiere de la escritura? R: se equipara a la omisión.

¡OJO! Se equipara a la omisión, cualquier disconformidad esencial entre la escritura y su extracto.

Consideraciones finales: Mas adelante se revisará en detalle la Ley de Saneamiento de los Vicios de Nulidad en las Sociedades, Ley 19.499.

Martes 2 de octubre de 2018

Las normas de las sociedades anónimas rigen supletoriamente para las sociedades por acciones.

## 10. **FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA**

En el funcionamiento de una S.A. podemos distinguir entre tres tipos de órganos:

- **El órgano de gestión o de administración:** el directorio de la sociedad
- **El órgano deliberante:** es la forma de la manifestación de la voluntad del ente social que es la junta de accionistas

- **Los órganos de control:** que están representados por los auditores externos, inspectores de cuentas y el comité de directores.

Cuando abordemos la problemática del control, nos daremos cuenta que en las sociedades anónimas abiertas y cerradas, existe una diferencia en materias de control. En las S.A.A el control es más intenso que en caso de las cerradas. Esto es así, porque en las abiertas, el sistema de captación de recursos, está sustentado en la confianza pública.

### 10.1 Directorio

Es el órgano de administración por esencia de toda sociedad anónima. De esta manera, la ley no lo define, sino que ha sido la doctrina la que se ha encargado de entregarnos un concepto de directorio. Sí el artículo 31 y siguientes de la LSA y el artículo 70 y siguientes del reglamento de S.A, se ocupan de enunciarlo como un órgano de administración y su funcionamiento, como se revocan los miembros, si son remunerados, etc. Además se fijan en **la responsabilidad de los directores.**

**Definición de Puga:** *Es un órgano colegiado de la sociedad cuya función principal es la administración superior de la misma.*

**Definición de Guerrero y Zegers:** *Es un órgano colegiado y permanente de la sociedad anónima cuyos miembros se designan periódicamente por la junta de accionistas y cuya función es realizar todos los actos de administración ordinaria y extraordinaria, representando a la sociedad ante terceros, asumiendo la responsabilidad solidaria por las infracciones a los deberes que les impone la ley, los reglamentos y los estatutos.*

Uno de los conceptos más importantes que se han introducido en los últimos años en materia de SA, especialmente aquello vinculado con la administración, está relacionado con las buenas prácticas del gobierno corporativo o buen gobierno corporativo. Luego revisaremos en detalle todo lo relacionado a los gobiernos corporativo, pero enunciaremos lo siguiente:

El buen gobierno corporativo consiste en administrar la sociedad teniendo como pase u objetivo central el interés social (interés más allá del de los accionistas), es decir, el interés de la sociedad en su conjunto. Para todos aquellos socios que se van uniendo (en virtud de la libre cesibilidad de acciones) es fundamental que la sociedad desarrolle su objeto, de tal manera que cumplan todos los objetivos que lo llevaron a incorporarse a la sociedad y que no se vulneren esos objetivos por los intereses de los socios mayoritarios.

**Estas buenas prácticas en el gobierno corporativo, impone una serie de deberes y obligaciones que recaen en los directores.** Además de los deberes de fidelidad y lealtad, hay otros deberes que están dispersos en la ley y que son muy importantes en el desarrollo de la gestión: por ejemplo, el deber de informarse y el de informar. Hoy en día, se recomienda que los directores deben capacitarse para el ejercicio de sus funciones, deben cumplir cierto grado de idoneidad respecto de la gestión en la que participan.

Es más, para la constitución de ciertas sociedades anónimas, cuyos giros son muy sensibles (bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, etc.), cuando se está en el proceso de constitución de la sociedad, se debe elaborar un prospecto que debe entregar a la CMF, para que sea revisado. Dentro de este prospecto, debe comprometer o generalmente se compromete en razón no solamente de la

idoneidad del director, sino que también en cuanto a la capacitación del director. El buen gobierno corporativo, cobra importancia en las S.A.A y S.A.E.

#### 10.1.1. Características del directorio:

- **Es un órgano colegiado o cuerpo orgánico:** los directores no ejercen una función de gestión u administración de forma individual. Es el órgano el que administra, no los directores individualmente considerados. No es relevante la voluntad individual del director, sino que es importante como el órgano delibera, resuelve o decide. Esto, no obstante, la responsabilidad personal y solidaria que establece la ley en concreto, de cada director.
- **Es un órgano permanente:** requiere de continuidad en la gestión para el correcto desarrollo del giro social. Eso no quiere decir que no puedan ser revocados en sus funciones, no tienen el derecho de propiedad sobre sus cargos.
- **Sus miembros son designados por la junta de accionistas periódicamente:** es la junta la que decide quienes serán las que lo integrarán.
- **Es el órgano de administración de la sociedad:** puede delegar sus facultades en un gerente o varios gerentes.
- **Representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad frente a terceros**

Además, si bien nuestro ordenamiento le llama directorio, si se analiza, en Europa el directorio no existe como concepto, sino que se llama concejo de administración.

#### 10.1.2 Nombramiento de directores

Los directores son designados siempre por la junta de accionistas. Esto porque la junta de accionistas es el órgano deliberante y el que decide el destino de la sociedad. Es el órgano a través del cual la sociedad manifiesta su voluntad. El directorio es conformado por miembros que son designados por la junta de accionistas y adquieren la calidad de tal, una vez aceptado el cargo.

Art. 37. La calidad de director se adquiere por aceptación expresa o tácita del cargo.

Además, el artículo 56 N° 3 establece como atribuciones o funciones de la junta ordinaria de accionistas, la de elegir o revocar los miembros titulares o suplentes del directorio. El director es designado por la junta de accionistas y adquiere el carácter de director una vez que acepta expresa o tácitamente el cargo.

**Es importante saber que todo lo relacionado con administración y directores está regulado en el artículo 31 y siguientes de la LSA y el artículo 70 y siguientes del reglamento.** El reglamento hace la distinción entre tipos y clases de directores y regula los deberes o derechos de los mismo. Además, regula las sesiones.

No obstante, lo señalado, cuando se constituye una sociedad anónima, el acto constitutivo supone que no ha concurrido o no se ha celebrado aun la primera junta, por lo tanto, en el acto constitutivo de una sociedad anónima, **lo general o normal es que se designen directores provisionales o provisorios que normalmente son ratificados en la junta.**

Los directores por regla general y no obstante su permanencia, no tienen una duración ilimitada de sus cargos, durarán en sus cargos lo que indique el pacto de constitución, con una limitación que establece el artículo 31 de **3 años**. En el caso de que no exista ningún pacto que haga referencia al periodo o tiempo del director, será el que establece la ley y se renovarán cada año. **El carácter transitorio de los directores es fundamental.**

### 10.1.3 Número de directores

Aquí hay una diferencia dependiendo el tipo social. En el caso de las S.A.A se requiere de un mínimo de 5 directores. En el caso de las S.A.E la ley exige un mínimo de 7 directores y en el caso de las S.A.C se requiere de un mínimo de 3 directores. En la práctica, siempre están entre 5 y 7.

### 10.1.4 Tipos de directores

Existen los **directores provisionales**, que son los que se designan en el acto constitutivo (ya mencionados).

Existen los **directores definitivos**, que son los designados por la primera junta ordinaria de accionistas. Respecto de estos, podemos distinguir:

- **Titulares:** los designados por la junta para ejercer el cargo de director en todos los actos de gestión y administración
- **Suplentes:** en el caso de impedimento o ausencia de titular, ejercen la labor de director, supliendo al titular. En las sociedades, de acuerdo al artículo 70 del reglamento de S.A, en que usted opte a tener directores suplentes, se deberán postular conjuntamente con el titular y a su respectivo suplente.
- **Reemplazantes:** aquellos que sustituyen a aquellos directores que en el ejercicio de sus funciones han sido revocados de su cargo. La función es dar continuidad y dar cumplimiento a esta característica de permanencia del directorio.

### 10.1.5 Revocación de directores

La facultad de revocar a los directores es privativa de la junta de accionistas. Está consagrado en el artículo 1º, 38 y 56 N°4 de la LSA.

### 10.1.6 Renovación del directorio

El directorio es de **carácter transitorio**. ¿Por qué? R: Porque es la manera en que le legislador entiende, a través del órgano que se denomina junta de accionistas de pedir cuenta de la gestión que desarrolla o ejercita el directorio de una sociedad.

### 10.1.7 ¿Cómo funciona un directorio?

**Como concepto general, tanto el directorio como la junta de accionistas funcionan en sala legalmente constituida.** Que sea sala legalmente constituida quiere decir que deben cumplirse de manera precisa las formalidades que establece la ley.

Según el artículo 81 del reglamento se conciben **sesiones ordinarias y extraordinarias**. Las ordinarias son las que se celebran en las fechas y horas predeterminadas por el propio directorio en su primera sesión y que no requieren de citación especial. Son materias de sesión ordinaria todas aquellas relacionadas con la gestión o administración de la sociedad normales.

El directorio debe funcionar a **lo menos una vez al mes**. ¿Qué pasa si en un pacto social se establece que un directorio funcionará cada 30 días? R: Está MAL, porque la CMF entiende que hay meses de menos días.

**Dato:** El profesor subió una circular respecto del directorio a través de sistemas telemáticos

Las extraordinarias son aquellas en que se citan por el presidente o por indicación de uno o más de los directores, previa calificación del presidente del directorio.

Las sesiones deben realizarse por regla general de **forma presencial y por regla general en el domicilio social**. Deben funcionar de forma colectiva y en sala legalmente constituida. Esto significa que se deben cumplir los quóruns (pactados en el acto constitutivo, o en su defecto por la ley) para el funcionamiento del directorio (para que puedan sesionar). Hay dos quóruns: el de funcionamiento y el de deliberantes (asistencia y votación).

Lo que sucede en la práctica es que a pesar de que la facultad de designar directores suplentes es facultativa, es muy recomendable, ya que eso permite dar continuidad al funcionamiento del directorio. Puede que no se cumpla el quorum de asistencia, por lo que los suplentes ayudarían a que se lograra sesionar.

**El director no puede delegar sus funciones de director.**

#### 10.1.8 Facultades del directorio

- a) **Ejecutar todos los actos de administración de la sociedad. Esta es la esencial**
- b) **Las conferidas en los estatutos**
- c) **Las conferidas por la ley**
- d) **Las funciones del directorio (NO DE LOS DIRECTORES), pueden ser delegadas en un gerente.** El director no ejecuta actos de administración por sí solo, sino que actúa dentro de una estructura colegiada, por eso solamente el directorio puede delegar (Art. 40):

- Gerentes
- Subgerentes
- Abogados

#### 10.1.9. Remuneración de los directores

Los estatutos determinarán si la función de director es o no remunerada. En este último caso el monto de remuneración se acordará en junta ordinaria de accionistas (Art. 35 LSA)

Martes 16 de octubre de 2018

#### 10.1.10. Responsabilidad de los directores. Consideraciones generales

La característica más importante es que es un órgano colegiado y realiza sus funciones de forma conjunta o colegiada. Los directores no actúan de forma separada.

Si bien el directorio es un órgano, es decir, es una entidad que está encargada de la administración (regir, gobernar y dirigir) y que la ejecuta en forma colegiada. **Los directores individualmente son responsables por el ejercicio de su función dentro de este órgano colegiado.** Hay una serie de aspectos que la doctrina ha discutido en el último tiempo respecto de la responsabilidad de los directores considerados individualmente. Esta discusión está centrada fundamentalmente en dos dimensiones o perspectivas.

- a) La primera es determinar la naturaleza jurídica de la responsabilidad del director.
- b) La segunda, vinculada con la determinación del tipo de la responsabilidad jurídica, es precisar el estándar de conducta que le podemos asignar al director.

Estos son los grandes elementos o factores que hoy se discuten en doctrina. Cuando nos referimos a la **determinación de la naturaleza jurídica ¿a que nos referimos?**

- A si es contractual
- O a si es extracontractual

Y cuando nos referimos al estándar de conducta, nos referimos a la diligencia debida, a la **culpa**. Cuando nos hacemos cargo de la naturaleza de la responsabilidad de los directores nos dirigimos al estatuto contractual y extracontractual y cuando nos hacemos cargo a los estándares de conducta, nos referimos a la culpa o a la diligencia debida del director en el ejercicio de sus funciones.

#### i) Estándar de conducta de los directores y sus deberes

En este contexto, hay doctrina que ha señalado o ha presentado una serie de elementos que en el caso de la función que ejercen los directores, deben concurrir para los efectos de precisar y determinar cuál es el estándar de conducta que deben cumplir los directores.

Estos son tres (según Enrique alcalde):

- **Prudencia:** en los negocios que emprende, evitando operaciones que sobrepasen el riesgo que suele ser admisible en la actividad desarrollada por la sociedad. Desde este punto, los directores son los primeros responsables de todo lo que está vinculado con la administración de sociedades anónimas, sean abiertas o cerradas.
- **Prevención:** se entiende como la determinación anticipada dentro de un periodo determinado de tiempo de las variables económica que va relacionado con el objeto que desarrolla la sociedad

- **Eficacia:** consiste en la facultad de ser activo y resolutivo en el desempeño del cargo que desarrolla.

**Estos tres elementos deben complementarse, ya que determinan el estándar de conducta del director.** No nos confundamos, que ese estándar de conducta (sea que recojamos la teoría contractual o la extracontractual) siempre está o puede ser interpretada dentro del ámbito o del régimen de culpa que contempla nuestro ordenamiento. El profesor nos adelanta que la doctrina mayoritaria opina que la regla general es la **culpa leve**. Luego de este estándar que nuestra doctrina ha pretendido incorporar en el régimen de responsabilidad de los directores, **se derivaría una serie de especiales deberes a cargo del director en el ejercicio de sus funciones:**

- **Un deber de vigilancia o in vigilando** que consiste principalmente en ocuparse de ejercer una adecuado control o vigilancia de aquellas personas que están a cargo de la ejecución o de la operación de la sociedad
- **Un deber in eligendo** que significa el deber de los directores de preocuparse de designar a las personas más idóneas y capaces para ejercer los cargos de alta dirección en la sociedad.
- **El deber de informarse**, los directores tienen el deber de informarse no solamente del desarrollo normal de las operaciones de la sociedad, sino de una serie de factores que están relacionados con la previsión de carácter económico por una parte y de carácter legal por otra parte, para el correcto desarrollo del giro social.

Un director hoy en día, debe ser una persona que debe tener las cualidades y capacidades idóneas para ejercer el cargo. Debe estar al tanto de las distintas variables económicas que afectan al negocio y además debe tener la **gerencia legal de las compañías**, deben estar al tanto del marco normativo legal sobre el que se desarrolla la sociedad. No puede no estar al día en la vigencia de todas aquellas normas que puedan afectar el giro de la sociedad.

Dato: Por esta razón, hoy en día, nosotros hemos pasado de la tradicional estructura de fiscalía que existía de antaño respecto de quienes integraban o de quienes se hacían cargo de la supervisión de la sociedad a los gerentes legales corporativos. Estos tienen la obligación de administrar de forma legal mantener actualizado al directorio de la nueva normativa que puede afectar a la sociedad.

- **Tienen el deber de prever, organizar y controlar la actividad de los ejecutivos de la sociedad.**

Estos deberes están relacionados con el concepto de **gobierno corporativo**. Estas son buenas prácticas del gobierno corporativo. En materia internacional se habla de “ordenanzas del gobierno corporativo”. Si bien hoy no se ha asentado qué efecto puede provocar esta emisión de normas de carácter general de parte del regulador, sin duda que este estándar al que debe ajustarse cada director en su función, ha ido mutando y completando y ha ido generando mayor complejidad en la función que ejerce el directorio.

Por ejemplo, en S.A.E como bancos o aseguradoras, la CMF hace responsable al directorio de la elaboración de todas las políticas relacionadas con conductas de mercado. Son los directores los que están obligados a elaborar todas las normas de conductas de mercado. Estas son:

- Trato justo a los clientes (fair treatment of customers)
- Gestión de conflictos de interés (management of conflicts of interest)
- Protección de la información de los clientes
- Promoción del desarrollo de mercado a través del principio de transparencia. (Promotion of market development through transparency)

Ha sido la CMF la que ha dictado normas de carácter general para fortalecer el buen gobierno y dentro de estas normas se contienen estos cuatro principios. Esto es muy importante, porque hoy en materia de control o supervisión estamos en un periodo de transición de un sistema de supervisión basado en normas a un sistema de supervisión basado en riesgos o principios. La diferencia es que el segundo tiene una finalidad objetiva preventiva y está basado en la **autoevaluación**.

¿Cómo opera este sistema? R: la autoevaluación consiste en que el órgano supervisor somete a las entidades sujetas a su control a una serie de cuestionarios o preguntas que deben responder y sobre la base de esto el supervisor ejecuta un control con un cierto grado de discrecionalidad o discriminación. ¿Y que pasa si hace trampa?

Como comentario en paréntesis: para la crisis subprime en Inglaterra, los ingleses solo tenían un órgano de supervisión y este sistema estaba sustentado principalmente en la autoevaluación. Ellos creían firmemente en la autoevaluación. Cada entidad que desarrollara una actividad regulada, podía implementar sistemas de autoevaluación para cumplir con los objetivos de conductas de mercado, protección a los consumidores y solvencia.

Luego de la crisis subprime, la literatura económica llegó a la siguiente conclusión: el sistema de autoevaluación no fue eficiente. No le permitió a la autoridad realizar un adecuado control y supervisión. Como elemento adicional que es lo que veremos hoy en día, el sistema de supervisión integrado no resultó porque los órganos tienden a ser enfáticos en ciertos objetivos (en la crisis subprimer se enfatizó más a consumidores que a solvencia).

Vamos a ver si en este país resulta la intención del legislador de un sistema integrado concebido en la ley 21.000.

### **Responsabilidad de los directores como tal**

Tenemos una idea general. Hay que recordar que en materia de responsabilidad civil existe una discusión entre los estatutos aplicables y lo que hemos revisado hoy está más relacionado con los estándares de conducta.

**¿Cómo debemos entender la culpa leve en el caso de la función del director?** En toda esta teorización de la doctrina chilena, hay mucha influencia angloamericana que es lo que provoca confusión. Por ejemplo, el factor de responsabilidad es un elemento extranjero, que se ha ido estableciendo de a poco en Chile.

¿Qué tipo de responsabilidad puede incurrir un director en el ejercicio de sus funciones? R:

- 
- a) **Responsabilidad civil:** la sanción podría ser la indemnización de perjuicios, podemos encontrar en la LSA ciertos casos en que la sanción o efecto es la sanción de restitución. Cuando el director de alguna manera ha incorporado ciertos bienes sociales (por actos de enajenación de la sociedad) o ha obtenido ciertos beneficios en desmedro del interés social. Y por último la nulidad por infracción de normas que producen ineficacia
  - b) **Responsabilidad administrativa:** que va de la aplicación de censura a multas (Ley 21.000 art. 35 y siguientes)
  - c) **Responsabilidad penal:** la veremos en detalle más adelante, las contenidas en la ley de mercado de valores y otras normas especiales.

**Independiente de lo revisado respecto de estos factores que permiten precisar el estándar de conducta de los directores y los deberes que se desprenden de estos factores de conducta,** el ordenamiento jurídico chileno en concreto la doctrina ha elaborado o enunciado dos tipos de deberes que recaen en la función del director:

- **Deber de cuidado o diligencia:** que se desprende de los artículos 31,39,42,47 de la LSA
- **Deber de lealtad:** Art. 42 LSA.

De estos deberes vamos a distinguir una serie de otros deberes que permiten determinar si el director incumplió con estos deberes.

Luego, en materia de responsabilidad de los directores y en concreto los efectos derivados de la responsabilidad del director, podemos encontrar dos supuestos fundamentalmente. Primero, la responsabilidad del director vinculada a las **relaciones internas** (daños accionistas) y la responsabilidad de las **relaciones externas** (daños del directorio a terceros). Para estos efectos la LSA contiene tres artículos: 41, 133 y 133 bis.

#### **A. Deber de cuidado o diligencia**

*¿De donde se desprende?* El artículo 41 de la LSA dispone que los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones, *el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad o a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culposas.* **Los estándares de conducta que hoy se exigen a los directores (las normas o exigencias de la OCDE) exigen un estándar de culpa más alto que el que exige la ley.**

Existe un régimen de **solidaridad** y este punto es bastante relevante, porque la doctrina chilena ha señalado que existen mecanismos que permitirían al director **exonerarse de responsabilidad**, especialmente en la responsabilidad solidaria dejando o dando cuenta en la sesión correspondiente de disenter del acuerdo (además, debe fundamentarlo) que se adopta o solicitar que se dé cuenta de la imposibilidad de asistencia a la sesión correspondiente. Esta norma es la columna vertebral o base en la determinación de la responsabilidad del director y en la imposición de este principal deber de cuidado y diligencia. El director se podría exonerar de la responsabilidad, en el caso de que represente frente a determinadas decisiones. Esto debe quedar en el acta de la sesión correspondiente. Debiera entenderse que no participa en el acto que causa el daño.

Hay una serie de otras normas que completan este deber de diligencia o cuidado.

- 
- **Los directores están obligados a adoptar las decisiones de acuerdo al procedimiento establecido legalmente** (Art. 39 y 47 de la L.S.A). En el artículo 39 inciso primero se consagra que las funciones del director son indelegables y que debe funcionar en sala legalmente constituida. El directorio debe funcionar de acuerdo a las normas del estatuto y aquellas normas contenidas en el reglamento de sociedades anónimas. Además, en el artículo 47 se consagra que el funcionamiento del directorio debe ajustarse a ciertos quórums de asistencia y los acuerdos del directorio deben ajustarse a ciertos quórums de deliberación, además de la posibilidad de que los directores puedan participar a través de mecanismos tecnológicos, siempre que se asegure la continuidad de la función. (Art. 47 inciso final y circular 1530)

Siempre esta sesión del directorio debe cumplir con normas de transparencia, equidad y resguardo del interés social. Es decir, todos los acuerdos que adopte el directorio deben estar orientados al resguardo y a la persecución del interés social. Los directores no pueden adoptar acuerdos que vayan en beneficio de ciertos accionistas en perjuicio del interés social.

- **Deber de imparcialidad:** deben ajustar sus decisiones al interés social y no al de uno o más accionistas o a los intereses del controlador (Art. 42 Número 1). Este artículo lo dispone de forma negativa, ya que dispone ciertas provisiones a las que están sujetos los directores en el ejercicio de sus funciones. Este artículo 42 N° 1 dice: *“Los directores no podrán adoptar decisiones que no tengan por fin el interés social”*.
- **Deben respetar la ley interna de la sociedad contenida en los estatutos.**
- **Deber de informar e informarse:** los directores que participan en la adopción de ciertas decisiones deben hacerlo debidamente informados. Tienen la obligación de informarse. Por eso dentro de los tres elementos que vimos al principio de la clase (prudencia, previsión y eficacia), los directores deben tener claridad de cuál es el estado del mercado y deben saber cuál es el marco jurídico al cual debe ajustarse la decisión concreta en la que participan. Es muy importante este deber.

El deber de informar se establece tanto a favor de los accionistas, CMF (SvS, hecho esencial) y público en general (Art. 46 LSA) Correlativo al deber de reserva del artículo 43 de la LSA (Art. 80 Reglamento).

Hecho esencial: ver artículo 9 LMV

Se trata de un deber que se cumple de modo orgánico, ya que los directores tienen un deber de reserva en razón de su cargo (Art. 43 de la LSA).

Los artículos que permiten deducir este deber de informar: 7 inciso 2º, 46, 54, 56,74, 75 y 126 de la LSA.

El deber de informarse: deben considerarse los costos de obtención de información, la diligencia debida como criterio general los obliga a poseer información de la sociedad y sobre el mercado (Art. 78 reglamento): límite. Este deber de informarse tiene una dimensión individual. Tiene frente a este deber el correlativo derecho a ser informado por los ejecutivos de la sociedad (Art. 39 inciso 2º)

- **Deber de actuar de buena fe y no propiciar actuaciones ilegales**

### Límite al deber de cuidado del director

“El contenido del deber y el grado de diligencia exigido dependerá de diversos factores: dimensión de la sociedad; actividades adscritas al objeto social; volumen y complejidad de los negocios; oportunidad en la toma de decisiones” (Alcalde Enrique)

“El estándar exigido en el contexto de los artículos 41 y 133 de la LSA sería culpa leve, según Alcalde”. Alcalde plantea el estándar de culpa como el de culpa leve. Alcalde hace referencia a una doctrina norteamericana (lo que es complicado trasladar a Chile) de la regla sobre el juego de negocios que hace referencia a la negligencia grosera, que en nuestra concepción debería ser el régimen de culpa levísima. El director es una persona que es remunerada y toda la normativa en materia de gobiernos corporativos deben ser personas que tienen la idoneidad suficiente y deben tener parámetros que se correspondan al nivel de diligencia que deberían tener.

### **B. Deber de lealtad**

La primera delimitación del deber de lealtad la encontramos en las prohibiciones del artículo 42 de la LSA. Este contexto de prohibiciones se complementa con la regulación sobre conflicto de intereses de los artículos 70 y 79 del reglamento y las normas pertinentes de la ley 18.045.

Además de parámetro del conflicto de intereses que nos permite delimitar este deber de lealtad, encontramos otras reglas que permiten contextualizarlo como la prohibición de bienes sociales para su beneficio y el manejo indebido de información privilegiada.

Miércoles 24 de octubre de 2018

Resumen de las cosas importantes: Continuamos con el directorio. Los directores deben cumplir con un cierto estándar en el ejercicio de su función. Si señalamos que la administración está a cargo del directorio, decimos que el directorio actúa como un ente integral, pero no quiere decir que los directores individualmente puedan delegar. El director suplente no actúa por delegación, sino que se eligen conjuntamente y lo sustituye. De esa manera se pactó en el acto constitutivo de la sociedad.

Todos los directores en el ejercicio de sus funciones están sujetos a su deber de cuidado y de lealtad.

### **ii) Naturaleza jurídica de la responsabilidad del director**

El punto siguiente es identificar cual es la naturaleza jurídica de la responsabilidad del director. **¿Qué importancia tendrá determinar la naturaleza jurídica? ¿contractual o extracontractual?** R: el ordenamiento jurídico chileno reconoce dos estatutos de responsabilidad. Se entiende que la responsabilidad en los directores (en la doctrina PUGA) se trataría de una especie de responsabilidad sui generis. Según el profesor no existe esta clase de responsabilidad. La determinación de la naturaleza jurídica de la responsabilidad del director tiene importancia.

**Esta determinación, si es contractual o extracontractual ¿tendrá algún tipo de relevancia?** R: cuando se distingue entre ambas, hay un punto que está relacionado con la culpa, que está vinculada a la conducta que ejecuta el director en el ejercicio de las funciones. En la responsabilidad extracontractual no se gradúa la culpa, es la del artículo 44 del Código Civil: falta de diligencia debida. El contenido

del estándar varía dependiendo del caso a caso. En la contractual la culpa se gradúa y se presume. En la extracontractual no se presume la culpa.

Este ejercicio es importante, ya que, en materia de responsabilidad de directores, podemos distinguir tres legitimados activos de la acción de responsabilidad: **(Importante)**

- **La sociedad**: los daños o perjuicios que le pueda causar el director a la sociedad en el ejercicio de las funciones
- **Los accionistas**: los daños que puedan tener por la función del director
- **Los terceros**

**La doctrina**: PUGA sostiene que para todos los casos: tanto de responsabilidad que reclama la sociedad y los accionistas y terceros es extracontractual. Su confusión es que cuando determina el estándar, dice que es culpa leve. En este caso se cae este argumento (ya que aquí no hay graduación)

**Otra parte de la doctrina** sostiene que, en el caso de la sociedad al existir un vínculo contractual entre la sociedad y el director, la responsabilidad es contractual y en los demás casos es extracontractual. Además del régimen de culpa, hay otros elementos de la responsabilidad del director respecto de los que interesa esta distinción:

- En cuanto a la prescripción: contractual son 5 y extracontractual son 4.
- La obligación de indemnización o reparación tiene varias formas. En el caso de los directores, la responsabilidad es **solidaria**. Esto es importante, ya que, si es contractual, la responsabilidad o la obligación es solidaria **porque la ley establece que es solidaria**. En el caso de la responsabilidad extracontractual, no obste lo que refiere la LSA, la regla general es que es solidaria (Art. 2317 del Código Civil)

Esto es muy importante. Respecto de Juan Esteban Puga (autor disidente), respecto de la culpa y solidaridad, **sostiene que las obligaciones de los directores son de medio y no de resultado**. Cuando se dice que son de medios (invención doctrinal), la norma del artículo 1547 (que establece el régimen general de la culpa en materia contractual) no aplica. Por lo tanto, quien reclama o quien busca que se declare la responsabilidad, **deberá acreditar la conducta negligente del director**. Hay otros autores que dice que no es así, que hay un régimen de presunción de la culpa, que facilita la prueba al invertir la carga.

Frente a esta problemática de la responsabilidad de los directores, se ha desarrollado o han surgido una serie de instrumentos o mecanismos que tienen por objeto:

- **Amparar el patrimonio personal de los directores**
- **Buscar mecanismos o instrumentos que de alguna manera garanticen la posibilidad de reparación**, estas se denominan las pólizas de seguros de B & O de directores y ejecutivos (generalmente es la misma sociedad la que contrata a favor de sus directores). Ninguna empresa y ninguna S.A.A olvida contratar estas pólizas. Estos son seguros que tiene por objeto:
  - Amparar la integridad patrimonial del director (por montos de indemnización)
  - Conferir cobertura por las sanciones de carácter pecuniario que aplica el órgano de fiscalización o control, en concreto la CMF.

## 10.2. El gerente.

**La función del directorio (no del director) puede delegarse en un gerente.** El gerente es nombrado por el directorio y **es el directorio el que determina la amplitud de los poderes del gerente de la sociedad.** En la práctica, con apoyo normativo, la regla general es que el gerente es el que representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad, es decir, todos los procesos de suscripción de convenios, contratos y todas las acciones judiciales se notifican al gerente general de la sociedad y no al directorio. Esas funciones se ejercen por delegación.

Lo que si debemos tener en cuenta es lo siguiente: **el gerente está sujeto a las mismas reglas de los directores en cuanto incompatibilidades e inhabilidades, en cuanto a los deberes de cuidado y al régimen de responsabilidad en general.**

**La regla general es que el directorio controla las funciones delegadas al gerente.** Hay ciertas responsabilidades que son del directorio y que no pueden ser delegadas al gerente general: por ejemplo, hay una serie de normas de cumplimiento de políticas del buen gobierno corporativo. Todo el desarrollo o determinación de las políticas del buen gobierno corporativo son del directorio y no se puede delegar al gerente. Lo que se podría delegar al gerente es la implementación de estas políticas.

### ESTO ES DEL PPT

#### Nombramiento y actuación

- Nombramiento: los designa el directorio de la sociedad (Art. 49 LSA)
- Poderes: actúa en el marco de los poderes conferidos por el directorio de la sociedad
- Responsabilidad: similar al de los directores (Art. 50 LSA)

El gerente es quien ejecuta actos de administración por mandato conferido por el directorio de la sociedad. Es el directorio quien lo nombra. (Art. 49 inciso 1º de la LSA).

Es incompatible con el cargo de director y auditor.

Los poderes de administración son aquellos conferidos por el directorio. Además, y según lo dispone el artículo 188 del reglamento, le corresponde la representación judicial de la S.A. Está investido de las facultades de ambos incisos del artículo 7 del CPC.

Tiene derecho a voz en las sesiones del directorio.

En cuanto a la responsabilidad, el artículo 5 le hace aplicable una serie de normas propias de los directores:

- Prohibiciones de cargo (Art. 35 de la LSA)
- Incompatibilidades (Art. 36 de la LSA)
- Aceptación del cargo (Art. 37 de la LSA)
- Deber de cuidado (Art. 41 de la LSA)
- Obligación de guardar reserva (Art. 43 de la LSA)
- Deber de informar (Art. 46 de la LSA)

### 10.3. Junta de accionistas

#### A. Regulación o régimen legal

Los artículos 56 y siguientes de la LSA y los artículos 101 y siguientes del reglamento son las que se refieren a la junta de accionistas. El profesor no pedirá que nos aprendamos esto, es excesivamente reglamentario.

#### B. Concepto

**La junta de accionistas es el ente principal a través del cual se manifiesta la voluntad de la sociedad. NO es un órgano de administración.** Este es el órgano que decide el destino y el buen desarrollo del objeto social. Hay ciertas materias que podemos entender que si se contienen en actos de la administración y que están restringidas a la voluntad de la sociedad (por ejemplo, la disposición de artículos de la sociedad).

Su función es:

- a) Controlar a la administración.
- b) ya que designa a los directores y revoca a los directores.
- c) Realiza actos de administración especiales y,
- d) tiene la facultad de modificar los estatutos.

**Es decir, el pacto social que determina el objeto de la sociedad, solamente puede ser modificado en virtud de una junta de accionistas.** Cuando la junta de accionistas cuya sociedad quiere potenciar su giro o ampliar su giro y captar más capital **¿Cómo lo hace?** R: se emiten acciones, lo que aumenta el capital.

Hay una serie de modificaciones en el estatuto de la sociedad, por ejemplo, aumento y disminución del capital que son actos exclusivos de la junta de accionistas. Es decir, hay ciertos actos que podríamos calificar de actos de la administración, que están relegados a la junta de accionistas. **La junta no administra ni se hace cargo de la administración ordinaria de la sociedad que permite el desarrollo del giro.**

PUGA: “La junta es un órgano cuyo ámbito de atribuciones lo fijan la ley y los estatutos sociales y que por lo mismo participa de la estructura interna de la sociedad anónima”.

#### C. Clasificación

Hay juntas de accionistas ordinarias y juntas extraordinarias.

**Las ordinarias** son las que se celebran una vez al año, en la época fijada en los estatutos sociales o a falta de estipulación dentro del primer cuatrimestre del ejercicio (Art. 55 inciso 2 y 58 inciso 1) Sus materias están en el artículo 56 de la LSA:

Art. 56. Son materias de la junta ordinaria:

- 1) El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la sociedad;
- 2) La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos;
- 3) La elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del directorio, de los liquidadores y de los fiscalizadores de la administración, y
- 4) En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

- Quien está a cargo de la administración, que es el directorio (o por delegación el gerente), presenta todos los años un balance y se debe evaluar el balance.
- La distribución de utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos. En materia de aumento de capital, ¿tendrá que decir algo la junta de accionistas?
- La elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del directorio, de los liquidadores y de los fiscalizadores de la administración, y
- Cualquier materia de interés social que no sea materia de junta extraordinaria.

Las extraordinarias son aquellas que se celebran en cualquier tiempo al deliberar y decidir sobre materias especiales que los estatutos o la ley establezca.

Sus materias las señala el artículo 57 de la LSA:

- Disolución de la sociedad
- Transformación, fusión o división de la S.A
- La enajenación de activos de la sociedad o el otorgamiento de garantías reales para caucionar obligaciones, también es materia de junta extraordinaria.

Art. 57. Son materias de junta extraordinaria:

- 1) La disolución de la sociedad;
- 2) La transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus estatutos;
- 3) La emisión de bonos o debentures convertibles en acciones;
- 4) La enajenación del activo de la sociedad en los términos que señala el N° 9) del artículo 67;
- 5) El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, excepto si éstos fueren sociedades filiales, en cuyo caso la aprobación de directorio será suficiente, y
- 6) Las demás materias que por ley o por los estatutos, correspondan a su conocimiento o a la competencia de las juntas de accionistas.

Las materias referidas en los números 1), 2), 3) y 4) sólo podrán acordarse en junta celebrada ante notario, quien deberá certificar que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión.

#### D. Formalidades y funcionamiento.

Si no se cumplen estas formalidades esenciales, pueden afectar el correcto desarrollo del giro social, además de causar daños a terceros.

- 
- a) Condiciones de acceso: ser accionista de derecho a voto, pero pueden ir representantes. (Art. 64 representación).

Por esta razón, cuando estemos a cargo del desarrollo de una junta de accionistas, hay dos actos que se deben realizar: la convocatoria y la calificación de poderes.

- b) Convocatoria (Art. 58 LSA y 59) (Art. 60: auto convocatoria)
- c) Participación (Art. 62-64 de la LSA): todos los accionistas tienen derecho a asistir y votar; lo que puede hacer de forma representada (calificación de poderes para evitar duplicidad)
- d) Presidencia: La junta la preside el presidente del directorio de acuerdo a lo que señala el artículo 107 del reglamento)
- e) El quorum: hay dos tipos:
- **Constitución**: mayoría absoluta de los accionistas que hayan sido citados y que tengan derecho a voto en primera citación y en la segunda citación es mayoría absoluta de los asistentes
  - **En acuerdos**: la regla general es la mayoría absoluta y hay ciertos quórum especiales que establece la ley, por ejemplo, el artículo 67 inciso segundo
    - Dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto para los siguientes acuerdos:
      - **Transformación, división y fusión de la sociedad.**
      - **La modificación del plazo de duración de la sociedad**
      - **La disolución anticipada de la sociedad**
      - **El pacto de disminución de capital social**
      - **La enajenación del 50% o más de los activos de la sociedad**
      - **Y la enumeración completa que establece el artículo 17.**
      - Al profesor le basta con que nosotros nos aprendamos 3 o 4. Las subrayadas son las bacanes ;)

Es una exigencia idéntica en su concepto a las sesiones de directorio: **Las juntas de accionistas debe desarrollarse en sala legalmente constituida.** Esto quiere decir que debe ocuparse quien está a cargo de presidir la junta, que se cumplan los quórum y todos los requisitos formales que establece la ley para que se produzca la junta de accionistas.

#### 10.4. Control de la administración

Haremos una referencia a los órganos especiales encargados de realizar un control en los directores (órgano de administración) El primero o más importante es **la junta de accionistas.**

Sin embargo, hay 4 órganos o entidades especiales que realizan una función de control y de apoyo al control en la gestión que realiza la administración en la sociedad anónima. En eso podemos distinguir:

- **Audidores externos:** Ellos elaboran estudios y le entregan información a la junta, que le permite tomar decisiones y controlar adecuadamente a la administración). Además, constituyen un relevante apoyo para la CMF (órgano controlador de aquellas sociedades que están sujetas a la supervigilancia del órgano supervisor). Todas las S.A cotizadas y especiales, están sujetas por ley: 18.045 respecto de las cotizadas y leyes especiales para las S.A.E. a sistemas de control financiero, en donde los auditores externos cumplen una función fundamental. Y toda esa información en copia siempre para la CMF. De esta manera se cumple una función preventiva en el ejercicio de la función de todas estas sociedades que captan dinero del público.
- **Inspectores de cuentas** (personas naturales que realizan auditoría pero que están muy en desuso)
- **Finalmente**, un órgano que tiene poco tiempo en nuestro ordenamiento como mecanismo de control de ciertas sociedades anónimas especiales (las que cumplen con las características del 50 bis de la LSA) están sujetas al control de un **comité de directores**. Este órgano es un órgano de control de la función que realiza el directorio y que cumple una función complementaria a la actividad que realizan los auditores externos y tienen por finalidad vigilar que la actividad del directorio de ejecute dentro de los marcos que establece la ley y dentro de las normas que establecen los estatutos. **Está compuesto por directores independientes**. Si la sociedad cuenta con más de un director independiente, no hay ningún inconveniente en la conformación de este comité que debe tener 3 miembros. Si la sociedad no cuenta con más de 2 directores independientes, **el director independiente podrá elegir de entre los directores que conformen el directorio a los otros 2 miembros que conformarán parte de este comité**, que tiene por objeto supervigilar el correcto desarrollo de la función del directorio en el ejercicio de su función. (El profesor lo dijo enredado)

Esto es lo que dice el ppt, para su mayor comprensión: Formado por tres directores. A lo menos dos deben ser independientes. Si hay un solo director independiente este designará a los otros dos miembros de comité.

Con esto, hemos terminado todo aquello relacionado con sociedades anónimas, en concreto con la administración y con los órganos que están encargados de manifestar la voluntad social.

Miércoles 3 de octubre de 2018 (Ferrada nuevamente)

**11. PACTOS DE ACCIONISTAS**

Existen dos niveles de relaciones jurídicas:

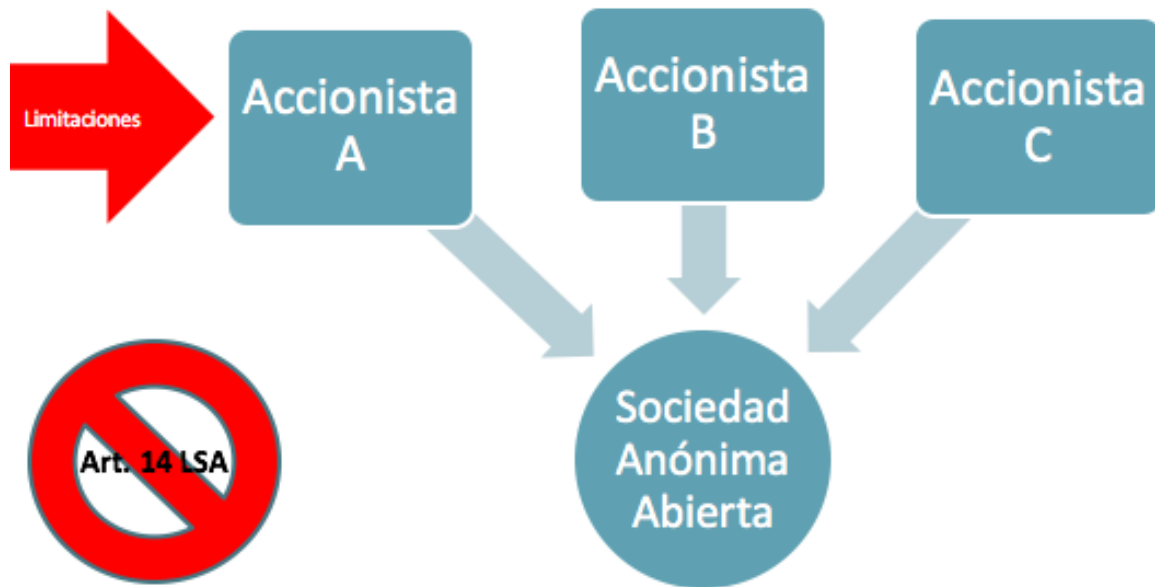


Hemos hablado todo el semestre de los estatutos sociales. Estos regulan la sociedad misma, es como el manual de convivencia. Pero sí puede haber otro pacto entre dos o más accionistas. **Estos son los denominados pactos de accionistas.** Los pactos de accionistas pueden tener un diverso contenido, pero lo que a la ley más le interesa, es cuando los pactos de accionistas ponen límites a la **libre cesibilidad de los derechos**. Lo que el legislador quiere en las S.A. es que sean lo más líquidas posibles, que la riqueza circule en la sociedad.

En el caso de las S.A.C el artículo 14 de la LSA permite poner limitaciones. Esto puede estar tanto en el estatuto social, como en el pacto de accionistas. En el caso de las S.A.A. se encuentra prohibido poner limitaciones en el estatuto social a la libre transferencia de las acciones, pero lo que sí se puede hacer, es acordarla con dos o más accionistas en un pacto. La ley no va a dejar que los accionistas de empresas COPEC estén prohibidos de vender sus acciones por una disposición de estatuto, ya que la ley quiere que empresas COPEC pueda recaudar dinero del mercado en general y los ahorrantes puedan aportar y salir cuando quieran. Se quiere que la riqueza circule.

Ahora, nada obsta a que si yo, mis hermanos y mi papá que somos accionistas de empresas COPEC, nos pongamos de acuerdo entre nosotros en el modo en que vamos a votar para elegir directores.

Existen dos niveles de relaciones jurídicas:



Seamos muy cuidadosos con la palabra “limitar”. Se puede **limitar**, pero no se puede restringir totalmente.

- Por lo tanto, las limitaciones a la libre cesibilidad de las acciones pueden constar en:
  - Estatutos: Solo SAC.
  - Pactos de Accionistas: SAA y SAC.

**¿Qué son los pactos de accionistas? ¿Regulan exclusivamente la cesibilidad de las acciones?**

- Son convenciones entre dos o más accionistas.
- Regular diversos tipos de materias, incluyendo la **limitación** a la transferencia de acciones (la más importante). También pueden tratar:
  - Administración de la sociedad (votos, directores, poder de veto, etc.)
  - Obligaciones respecto de nuevas inversiones.
  - Cláusulas de no competencia.
  - Eventos de salida: si llega un tercero y nos ofrece un buen precio, nos obligamos todos a vender.
  - Solución de controversias.
  - Etc.

| <b>Estatutos</b>                                                                                                                | <b>Pactos de Accionistas</b>                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Relaciones sociedad-accionistas.                                                                                                | Relaciones accionista-accionista (ciertas excepciones en SAC).                        |
| Acto colectivo, vincula a todos los accionistas (actuales o futuros, estén o no de acuerdo con sus disposiciones) (art. 22 LSA) | Limitados y vinculantes solo para quienes lo celebraron, y sus continuadores legales. |
| Velan por el interés social y de todos los accionistas.                                                                         | Velan por el interés de los accionistas que lo celebraron.                            |
| Los efectos de sus obligaciones se regulan principalmente en la Ley (responsabilidad del directorio, IDP, etc.).                | Mayor espacio a la autonomía de la voluntad, cláusulas penales, multas, etc.          |

**Art. 14 LSA.**

- Requisito para su oponibilidad frente a terceros: estar depositados en el Registro de Accionistas. Esto significa que se va donde el gerente y se le dice que tales acciones están sujetas a gravamen.
- Obligación de la sociedad de inscribir los trasposos aunque infrinjan el pacto de accionistas.
- ¿Y si la limitación estaba en el estatutos (S.A. Cerrada)?
  - Art. 12 inc. 2do.
  - **¿Puede el gerente general infringir los estatutos a sabiendas?**
    - Puelma: No, la Sociedad está obligada a respetar sus propios estatutos.

**Cláusulas más comunes sobre cesión de acciones:****i. Right of First Refusal (ROFR)**

**En todos los ejemplos, habrá una sociedad con dos accionistas:** un socio quiere vender su acción y el otro es quien se quiere quedar en la sociedad.

En este caso, un socio quiere vender su acción y le llega la oferta de un tercero. Mediante esta cláusula, ese socio está obligado a llevarle la oferta al otro socio y este tendrá que decir si iguala o no la oferta. Si no la iguala, ella es libre de vender a ese mismo precio o a uno más alto al tercero que le propuso la oferta.

**¿Puede el socio llevar una oferta por 10 y terminar vendiendo por 9?** R: no, debe ser una oferta igual o mayor.

**ii. Right of First Offer (ROFO).**

**En este caso, un socio quiere vender su acción, pero antes de salir al mercado a ofrecerla, debe ofrecérsela primero al otro socio.** El otro socio podrá aceptar o no. Si rechaza la oferta, ella tiene derecho a salir al mercado a vender su acción. Siempre tiene que venderla a un precio igual al que le

ofreció al socio o más cara. Si baja el precio porque no logró venderla, tendrá que nuevamente comunicarle al otro socio y solo si rechaza podrá ofrecerla al mercado a ese precio más rebajado.

### iii. Call Option. (Opción de compra)

Imaginemos que yo soy un inversionista “ángel” y otra persona desarrolla un negocio que me interesó financiar. Si nos asociamos, la persona que desarrolla el negocio podrá acordar conmigo que, si le va muy bien en el negocio, ella tendrá el derecho de recomprarme el 49% de la sociedad que me acaba de vender. De esta forma, se fija un precio determinado o determinable, se fija un plazo o condición que fija la época de la opción.

- **Precio determinado o determinable.**
- **Plazo o condición que fija la época de la opción.**
- **Derecho a comprar, no obligación: no tiene que obligadamente comprarlas en esa época.**
- **¿Cuándo le interesará al accionista comprarle a sus socios?** R: cuando a la empresa le ha ido muy bien, puede suceder que el precio con el que pacté que podría comprarle las acciones es mucho más barato del que efectivamente valen actualmente por la prosperidad del negocio. Me interesa comprar cuando el valor de mercado de ese activo es mucho más alto que el valor que tengo pactado en el pacto.

### iv. Put Option. (Opción de venta)

Es lo mismo que el anterior, pero es una opción de venta. Tengo el derecho, pero no una obligación de forzar a mi co-accionista a que me compre mis acciones a un precio determinado o determinable en un plazo o condición que fija la época de la Opción.

- **Precio determinado o determinable.**
- **Plazo o condición que fija la época de la opción.**
- **Derecho a vender, no obligación.**
- **¿Cuándo le interesará al accionista venderle a sus socios?**

### v. TAG-Along. (“pegado” Derecho de venta conjunta)

Es el derecho que tiene un accionista a ir “pegado” a la venta de otro accionista. Por lo general será un minoritario. Imaginemos que soy un socio de 10% de una cervecería y el otro 90% es otro socio, naturalmente, ese socio mayoritario saldrá al mercado y tendrá un muy buen precio, ya que tiene lo que se denomina **la prima del control**. Tiene la posibilidad de escoger a todos los directores, gerentes, etc. El precio que podría obtener por acción, es mucho más alto del que yo podría obtener con mi 10%. Pero yo también quiero la prima por control, por lo que firmo un pacto con el socio mayoritario: “cuando vendamos esta cervecería, yo quiero tener el mismo precio de acción que tú” “Entonces, cuando tu salgas a vender, estás obligado a llevarme contigo”. Esto permite que el socio minoritario participe de los beneficios de **la prima por control**.

Tema aparte: si yo le compro a un socio el 51% de una sociedad, no solo compro el 51% de las utilidades, sino que tengo mayor derecho para nombrar directores, gerentes, etc., que son beneficios que el que tiene 49% no tiene. Por esta razón estas acciones valen en la práctica mucho más (más allá

de la diferencia cuantitativa). De hecho, la ley de OPA tiene por objetivo repartir este mayor beneficio entre los socios

vi. **DRAG-Along. (Derecho a forzar la venta)**

- Derecho a “arrastrar” a otro accionista a la venta.
- Por lo general, es una protección para el mayoritario.
  - Por lo general se fijan precios mínimos de venta.
  - Está pensado para cuando el tercero quiere comprar el 100% de las acciones.

Si soy dueño del 90% de una sociedad y pacté el Drag-Along con mi socio minoritario, si me llega una oferta para comprarme la sociedad, pero quiere el 100%, yo podré arrastrar a mi socio minoritario para que también venda conmigo.

Además, este pacto también ayuda a no quedar preso de ser socio con alguien del que no se quiere ser socio.

vii. **Lock-Up.**

- Se restringe la venta de acciones por un determinado período de tiempo, o respecto de determinadas personas.
- Por lo general, el plazo va asociado a un determinado plan de negocios o proyectos.
- El periodo debe ser restringido: se permite la limitación a la venta de acciones, no su restricción absoluta.
- Siempre va asociado a un motivo como un plan de negocios
- Afecta a todos los accionistas, es como cerrar con candado una sociedad.

Este no tiene que ver tanto con la transferencia de acciones. En este caso, se restringe la venta de acciones o la toma de decisiones por un cierto periodo de tiempo. Imaginemos que yo compro una determinada sociedad (51% o más), pero yo necesito que el otro socio se quede en la compañía y la haga crecer, ya que él es el que sabe más del tema. Aquí se puede pactar el Lock-Up para que no pueda vender sus acciones. Es ponerle “un candado” a la sociedad. También puede consistir en **no venderle a determinadas personas**.

**Efectos del incumplimiento del pacto**

- **Remedios contractuales establecidos en el mismo pacto:** debe entenderse como cualquier otro contrato. Debe distinguirse cuales son las obligaciones: si son de dar, hacer o no hacer y debe distinguirse si las partes han regulado cual será el efecto de su incumplimiento. Normalmente los pactos contienen los remedios contractuales o efectos de las relaciones particulares reguladas por las partes, por ejemplo:
  - ❖ **Deadlocks:** mecanismo de solución alternativa de controversias. Cuando se llega a un punto en el que la discrepancia no tiene solución, los accionistas pueden regular el mecanismo de salida. Si los accionistas no se ponen de acuerdo en determinadas decisiones, el pacto regula mecanismos de solucionar este conflicto sin ir donde un juez. “Uno le compra a otro”, “mediador”, etc. “Por ejemplo, si no nos ponemos de acuerdo en tal plazo, va a pasar lo

siguiente (puede ser llamar a un tercero para que sin forma de arbitraje, le de la razón a alguna de las partes)

- ❖ **Cláusula Penal:** regulación anticipada de los perjuicios.
  - ❖ **Multas:** en caso de incumplimiento, se le impone una multa X.
  - ❖ **Otros.**
- (Si no se estipulare nada) Reglas Generales Derecho Civil (Art. 1489 C.Civil).
    - ❖ **Son los derechos que le asisten a acreedor incumplido: resolución del contrato o cumplimiento forzado, ambos con indemnización de perjuicios.**
    - ❖ ¡OJO! Casos de incumplimiento de prohibiciones (obligaciones de no hacer en la gran mayoría de los casos): Art. 1555 C.Civil. Muchas veces, lo que subyace a ellas es la prohibición de enajenar. Esto hace que su cumplimiento forzado se dificulte bastante y a la larga termina siendo solamente indemnización de perjuicios. Ellas en la práctica, derivan en indemnización de perjuicios y no invalidan la enajenación al tercero.
    - ❖ **Puelma:** indemnización de perjuicios, pero no afecta la validez de la enajenación.
    - ❖ **Enrique Barros:** si el pacto estaba inscrito en el Registro de Accionistas, es oponible a terceros, ya que el supo o debió saber que esa acción tenía una prohibición y si el tercero compró igual, a sabiendas, lo que el ha hecho es convertirse en un cómplice de un incumplimiento contractual. Por lo tanto se podría demandar al tercero **por responsabilidad extracontractual por interferencia dolosa en contrato ajeno** (esta institución es poco común en derecho chileno (a diferencia del anglosajón) Es responsable aquel tercero que causa el incumplimiento ajeno o interviene en él). A este tercero, se podría perseguir, a sabiendas de haber incumplido o haberme hecho a mí incumplir. El profesor opina que aun estando en el registro, se mantiene la validez de la enajenación.

#### Otros acuerdos que limitan la cesión de acciones

- **Prenda** (Art. 47 Reglamento S.A): las acciones se pueden preñar y muchas veces van aparejadas con una cláusula de no enajenar.
- **Usufructo** (Art. 46 Reglamento S.A).
- **Gravámenes Judiciales:** embargos y medidas precautorias (Art. 48 Reglamento S.A). Si quiero recuperar las cosas y quiero cobrar un crédito, puedo pedir medidas precautorias como prohibiciones de no enajenar sobre los bienes del deudor, entre ellas las acciones.

#### Otras normas legales que afectan la libre cesión de acciones:

- **“Ley de OPAs” (Título XXV Ley de Mercado de Valores).** No cualquiera puede comprar en cualquier minuto. No puedo comprar el control por bolsa. Debo hacerle la oferta a todos los accionistas.
- **Control de Operaciones de Concentración (DL. 211).** Porque produciría problemas de competencia.
- **Squeeze-Out:** pérdida forzosa de la calidad de accionista. Es cuando el accionista mayoritario puede obligar al minoritario a venderle sus acciones.

#### Autonomía de la voluntad bastante amplia, son comunes:

- **Administración de la sociedad** (votos, directores, poder de veto –derecho a impedir las claves de negocios que importan gravar a la sociedad en más del 50% de su patrimonio por ejemplo-, etc.): el “como vamos a votar”, por ejemplo, todos votan de la misma manera.

También se podría establecer como se van a regular los directores: “de los 7 directores de falabella, nosotros como pacto tenemos derecho a escoger 4”. También está el derecho a veto.

- **Pactos de Actuación Conjunta** (Art. 98 LMV): lo mismo de antes.
- **Obligaciones respecto de nuevas inversiones, planes de negocios** (por ejemplo, si se compra un campo que ya ha sido plantado, se puede armar un plan de negocios al establecer que en tal plazo se venderá la fruta. En este mismo caso podría pactarse un aumento de capital para tal fecha por parte de los accionistas), **presupuestos de mediano-largo plazo**.
- **Deadlocks**.
- **Cláusulas de no competencia, uso de oportunidades de negocio, participación de familiares en la empresa** (podría ocurrir que en la medida que entran familiares la empresa se va llenando de personas no tan calificadas, por lo que puede regularse)
- **Operaciones con partes relacionadas**: las partes podrían poner requisitos adicionales para las operaciones con partes relacionadas o bien en una S.A.C. que no está regulado por el capítulo XV que regula las operaciones con partes relacionadas en las S.A.A. hacerlo aplicable.
- **“Eventos de Salida” (venta)**: hoy hay una industria que se llama PE & V.C. El primero es una compañía full profesional y muy buenos administradores de empresas que compran empresas baratas mal administradas y luego de mejorar los números, los vende. El segundo es propiamente tal cornershop. Con un emprendimiento muy chiquitito se sale al mercado (que son los fondos de venture capital) . Estos dos tienen en común los eventos de salida. Ya sea los fondos que se pusieron en el private equity o quien pone plata en el start-up, se regulan los eventos de salida. No se quiere ser productor de un fondo muy sofisticado. Los eventos de salida dirán: “después de 5 años, las partes deberán poner la sociedad a la venta la sociedad, a tal precio (un mínimo de 6 veces las utilidades, por ejemplo) y en tales condiciones”.
- **Solución de controversias**.
- **Derechos y deberes de información**.
- **Cláusulas propias de empresas de Venture Capital & Private Equity**.

Miércoles 10 de octubre de 2018

### Resumen clases anteriores:

- i. Constitución de una S.A.
  - a. Regla General.
  - b. Sociedades Anónimas Especiales.
- ii. Modificación de una S.A.
  - a. Regla General.
  - b. Sociedades Anónimas Especiales.
- iii. Sanciones por incumplimiento de solemnidades.
  - a. Nulidad de pleno derecho.
  - b. Nulidad absoluta.
- iv. Pactos de Accionistas.
  - a. Limitaciones a la transferencia de acciones.
  - b. Otras cláusulas.

### 12. CAPITAL EN LAS S.A.

**Capital:** *“fondo suministrado por los accionistas, que se divide en títulos negociables denominados acciones, que representan parte de él”*. El capital es muy importante, lo hemos visto anteriormente con el nombre de aporte. Es el aporte que hacen los accionistas. Cuando decimos que son títulos negociables, nos referimos a las acciones: una acción es igual a la otra.

Las acciones tienen igual valor, salvo que haya series de acciones (en el estatuto siempre deben estar reguladas en la cláusula del capital) o prima por el control.

- **Privilegios:** las acciones pueden ser ordinarias o privilegiadas. Una ordinaria da derechos económicos y políticos de los que se hablará posteriormente: los **políticos** son asistir a las juntas, votar, etc. **Los económicos** son a recibir dividendos y eventuales devoluciones de capital. Las acciones privilegiadas pueden tener todos los derechos económicos y políticos y, además: se le puede agregar o privilegiar una serie, es decir, a pesar de no tener el porcentaje para designar un director, se lo otorgan. Por ejemplo: en este caso a pesar de que no les alcanza el porcentaje en el capital para designar un director, se le permite. Otro privilegio es que un accionista se pague con un dividendo X primero (a pesar de que se tenga que distribuir las mismas utilidades entre todos, se paga el socio privilegiado primero).
- **Cargas:** al igual que los privilegios, se establecen en el estatuto.

#### 12.1. El capital en Sociedad colectiva vs en la S.A

**¿Contra qué se dirigen los acreedores en la sociedad colectiva?** R: En la sociedad colectiva, a nadie le interesa el capital de la sociedad. Ya que, si no solventa la deuda, se dirige contra los socios posteriormente.

En cambio, en las sociedades de capital (en este caso S.A.), solo se pueden pagar del patrimonio de la Sociedad. Una parte esencial del patrimonio sobre todo en los primeros años de la sociedad, es el capital. Lo que los accionistas aportaron en su minuto

#### 12.2. ¿Por qué es importante el capital?

- Es parte relevante del patrimonio de la sociedad
- Refleja el aporte de los socios
- En él se hace efectiva la responsabilidad de la sociedad

La ley lo cuida celosamente y está muy reglamentado. No se da mucho espacio a la autonomía de la voluntad. Esto da origen a dos principios:

- **Principio de la efectividad del capital (Esto es lo importante)**

*“Que el capital que la sociedad dice tener, esté efectivamente adentro y pagado”*. Esto porque es muy fácil hacer entender cosas diferentes a terceros. La ley establece ciertos requisitos para asegurar este principio:

- **Los aportes no consistentes en dinero** (constitución) **deben evaluarse por todos los accionistas**. Por ejemplo: asegurarse que el auto valga tal precio.
- **Los aportes no consistentes en dinero (aumento de K) deben evaluarse por peritos** (salvo unanimidad, no basta la mayoría)
- **Se prohíben las acciones de industria:** me da lo mismo que el señor se diga ser el mejor gerente de Santiago y que su aporte lo valore en mucho dinero. Se quiere la platita sonante y cantante.
- **Plazo máximo para pagar:** 3 años (OJO: no confundir con SPA, ya que el plazo es de 5 años)
- **Prohibición de adquirir acciones de propia emisión (inflaría el capital):** Una sociedad con un capital de 200 millones dividido en 200 acciones (1 millón por acción), si esa sociedad realiza un aumento de capital a 400 millones, pero esos 200 adicionales no los sale a vender al mercado, sino que los compra ella misma, lo que hace es inflar artificialmente su capital, ya que no ha entrado 200 acciones. Se produciría un efecto ficticio de inflar el capital, cuando la sociedad saca plata de su bolsillo para salir a comprar sus propias acciones. Estas cuentas deberían medirse y verificarse para que no se produzca el efecto de inflación. En las fusiones, cuando se absorbe a una empresa, se pueden tener que absorber acciones de la propia empresa continuadora.

Hay casos en que puede tener, pero son casos reglados en la ley y con plazos máximos. Un ejemplo: el profesor tiene dos clientes: pacífico 5ta región y Pucobre. Pucobre absorbió a pacífico y dentro del activo de Pucobre, venían 200 mil acciones de pacífico. Entonces junto con absorber autos, trabajadores, contratos, etc, absorbió acciones de ella misma, ya que era accionistas de Pucobre. En este caso se permiten las acciones de propia emisión, pero tiene que vender estas acciones dentro del plazo de un año (si no, se disminuye el capital).

Otro ejemplo es cuando se paga el derecho a retiro. Esto sucede cuando un accionista no quiere fusionarse y tiene el derecho a retirarse. Este derecho a retiro, es susceptible de ser comprado por la sociedad y sería la misma sociedad la que compra sus acciones, por lo que al igual que el caso anterior, deben venderlas en un plazo de un año.

- **Principio de conservación del capital:** que el capital se mantenga el valor en el tiempo. Si en virtud del principio de efectividad ya sabemos que el capital es real, ahora tenemos que conservarlo. (Esto es lo importante)
  - **Salos insolutos de capital se reajustan en UF:** se quiere que lo que entra a la caja social esté ajustado al valor actual. Se aumenta por IPC
  - **Prohibición de adquirir acciones de propia emisión** (autocartera).
  - **Estricta reglamentación de disminución de capital**
  - **Dividendos se pagan solo sobre utilidades líquidas del ejercicio, o de las retenidas de ejercicios anteriores** (y se absorben previamente las pérdidas acumuladas). Si pago dividendos sin tener utilidades, lo que hago es disminuir el capital.
  - **Revalorización del capital propio** (ajuste de pleno derecho por la aprobación de la JOA). Dentro de las materias ordinarias de la junta de accionistas se encuentra la aprobación de balance financiero.

### 12.3. Clasificación del capital

- ❖ **Capital nominal:** el que se establece en los estatutos. Ahora, puede que no paguen y pase el plazo (y no paguen). Este sería solamente el capital en papel, pero no en la práctica. Es una mera declaración de los accionistas.
- ❖ **Capital suscrito:** el que se ha colocado entre los accionistas (en forma de acciones). Una persona jurídica se ha obligado a pagar una determinada cantidad de dinero por una determinada cantidad de acciones. Esta es la que confiere la calidad de accionistas, aunque las acciones no estén pagadas, la calidad de accionista se confiere al momento de suscripción (lo único que se le limita son los derechos económicos).
- ❖ **Capital Pagado:** ya ha ingresado a la caja social.

**Capital es diferente de patrimonio.** En el minuto en que la sociedad se constituye puede que sean parecidos. Luego de esto el patrimonio podría ir aumentando o disminuyendo conforme a si les va bien o les va mal, en cambio el capital sería el mismo. Las obligaciones también se encuentran dentro del patrimonio. Las normas de protección van más referidas a la protección del capital, para efectos de proteger a terceros (no tanto al patrimonio).

#### 12.4. **Respecto del pago de las acciones**

- ❖ Saldos insolutos se reajustan en UF
- ❖ En caso de transferencia de acciones suscritas y no pagadas, cedente y cesionario responden solidariamente por el pago de sus acciones
- ❖ En el título deberán constar las condiciones de pago. El título era tremendamente relevante y es una dimensión de la acción en materia de sociedades. Ahora ya no tanto por el comercio electrónico. El título debe decir cómo se pagaron las acciones.
- ❖ **¿Qué derechos tienen las acciones suscritas y no pagadas?** (Ojo: no es una norma de Orden Público)
  - Derechos políticos (voto): Sí
  - Derechos económicos (dividendo y devolución de capital: no).
  - Independientemente que en los estatutos diga algo diferente.

#### **¿Cómo se exige el pago de las acciones?**

- ❖ La sociedad puede vender en bolsa, por cuenta y riesgo del accionista moroso, el número de acciones que sea necesario para pagarse. (Art. 17 LSA)
- ❖ Otros arbitrios establecidos en los estatutos (Art. 17 LSA)
- ❖ Demandar judicialmente el cumplimiento. Hay que pensar que es un contrato.
  - ¿Puede el directorio abstenerse del cobro?: Sí, autorizado por la junta extraordinaria de accionistas (2/3), caso en que se reduce el capital a la cantidad efectivamente pagada (Art. 24 LSA)

Jueves 11 de octubre de 2018

Hoy nos adentraremos en el concepto de acciones.

#### 12.5. **Aumento de capital**

**¿Qué es, en propiedad? R:** Es uno de los elementos esenciales en el estatuto social. Cuando hablamos de un aumento del capital, hablamos de una modificación de los estatutos y por lo tanto, debe sujetarse a los requisitos de modificación.

#### **12.5.1. Formalidades:**

- i. JEA ante Notario (Art. 57 LSA)
- ii. Mayoría prevista en los estatutos (Art. 57: Sociedades Anónimas Cerradas, mínimo: mayoría absoluta de las acciones emitidas con derechos a voto)
- iii. Reducción a E.P. (del acta), inscripción + publicación en 60 días. En las especiales, este mecanismo ante notario se cambia por la autorización de existencia del organismo correspondiente.

La LSA permite que hasta un 10% del capital se destine a planes de incentivos para trabajadores (Stock options). Art. 24 LSA. No todo es para ganar plata o traer inversiones, sino que también puede ser para promover talento o a sus trabajadores. “Si haces esto, te doy tanto porcentaje de la sociedad”. Esto normalmente consta en el contrato de trabajo, pero como es un aumento de capital debe constar en los estatutos.

#### **12.5.2. Formas de realizar un aumento del capital**

- a. **Emisión de nuevas acciones de pago** (salir al mercado): por esas acciones que vendo al mercado, recibo tanta plata y esta entra a la caja social.
- b. **Capital de utilidades acumuladas u otras cuentas.** Aquí no se sale al mercado. Imaginemos que todos somos una sociedad y ganamos mil millones. Repartimos el mínimo legal de 30% y nos quedamos con 700 adentro. Lo que se puede hacer es capitalizar las utilidades, es decir, invertir. Los accionistas “renuncian” a la posibilidad de llevarse esa plata para la casa y la invierten en la sociedad. Esto en rigor es un aumento del capital. Esto porque esa plata pasa de las utilidades retenidas a la cuenta de capital. A diferencia de la emisión de nuevas acciones de pago, la plata ya estaba “adentro de la sociedad”. También se podrían capitalizar otras cuentas o por ejemplo un accionista puede capitalizar un crédito (un accionista mayoritario le presta de su bolsillo tanta plata. Y hay un minuto en que la sociedad está algo corta de plata y le ofrece al socio que prestó, que esa deuda se transforme en acciones, es decir, se aumenta el capital por la vía de capitalizar un crédito que uno de los accionistas tiene, para esto, se va a necesitar que todos los otros accionistas renuncien a su derecho de suscripción preferente).

El derecho de suscripción preferente es que cuando hay un aumento de capital, cada socio tiene el derecho de suscribir las nuevas acciones correspondientes a su proporción. En el caso de la capitalización del crédito, lo que se quiere es compensar al accionista que concedió el crédito a la sociedad, por lo que es este el que tiene el derecho de suscribir las acciones que resulten de este aumento de capital.

Este tipo de aumento de capital, puede producir los siguientes efectos:

- **Aumento de valor nominal de las acciones.** Las acciones ahora son representativas de un mayor capital. Cuando se capitalizan utilidades (los capitales se expresan: X cantidad de dinero/ X

cantidad de acciones) y no se sale al mercado por plata, ya que son las utilidades de los mismos accionistas que ya estaban, no se está obligado a emitir acciones, ya que los accionistas ya las tienen y la proporción será la misma. Entonces al aumentar el capital, los valores de las acciones son representativos de más valor ( $2x$  cantidad de dinero /  $x$  cantidad de acciones).

- **Emisión de acciones liberadas de pago (crías)**: en este caso, al capitalizar las utilidades, se opta por emitir más acciones porque les permito vender algunas y otras no, por ejemplo. Entonces el capital quedaría en  $2x$  cantidad de dinero /  $2x$  cantidad de acciones, sin perjuicio de que las acciones nuevas emitidas, se distribuyen entre los mismos accionistas, pero como eran utilidades, los accionistas no tendrán que pagar por ellas. No se pagan porque son como crías, “uno no paga el potrillo que sale de la yegua”

#### 12.6. **Disminución de capital** (normalmente por sobre-capitalización)

##### Requisitos:

- i. Formalidades propias de cualquier reforma de estatutos
- ii. Súper Mayoría: 2/3
- iii. Aviso adicional: diario de circulación nacional + página web de la sociedad (S.A.A)
- iv. Autorización del SII

##### También son casos de disminución de capital

- **No cobrando saldos insolutos de suscripción de acciones**, no le cobremos a los accionistas morosos y sencillamente cancelemos sus acciones.
- **Dividiendo la sociedad y asignando parte del capital a una nueva sociedad que se crea** (“escindida”, en contraposición a la escidente o continuadora legal). Entonces se podría repartir el capital a la mitad entre una u otra. Lo que sí, es que la estructura de capital que había en la sociedad original, se va a replicar en la escindida (si eran 200 accionistas en la original, habrá 200 accionistas en las otras)
- **Comprando acciones de propia emisión**, en los casos en que la ley lo permite. Por ejemplo, el derecho a retiro, compra de acciones cuando se fusionan, etc.

#### 13. **ACCIONES**

Es la reina de la fiesta: toda la normativa de S.A. gira en torno a las acciones. Es la acción la que confiere la calidad de accionista en la sociedad (aun cuando no esté pagada, basta que esté suscrita).

La acción (unidad de medida) determina la cuantía de derechos que corresponden al accionista en:

- Dividendos
- La liquidación
- Derecho de suscripción preferente
- Derecho a voto
- Derecho a pedir que se cite a junta: al menos 10%
- En general, cualquier otro derecho político o económico.

---

### **13.1. Concepto de acción**

No está definido en la ley. No es tan importante definirla, ya que tiene más de una dimensión. Sin embargo, la ley le da al menos 3 dimensiones:

- **Parte alícuota** (una proporción del capital)
- **La expresión y título de la calidad de accionista**
- **La acción y los derechos que confiere.**

#### **13.1.1. La acción como parte alícuota**

La acción designa una proporción del capital. “Yo soy dueño del 10% de esta sociedad (en términos coloquiales)” ¿Cuál es el valor de esta porción?:

- **Valor nominal:** Capital/número de acciones. No me da información de cuánto vale cada acción.
- **Valor Libro:** Patrimonio/ número de acciones. Si liquidáramos la sociedad, podríamos dimensionar cuánta plata recibiremos. Se utiliza cuando las acciones no tienen presencia bursátil. El valor libro se saca al mirar el estado financiero aprobado y se divide patrimonio en número de acciones. Esto nos da el valor libro por acción.
- **Valor de Mercado:** valor libremente determinado por el mercado. En el caso de las S.A. que cotizan en bolsa, se mirará esos valores. Este es el importante, ya que es el valor libremente asignado por el mercado. Lo importante es el valor bursátil que tenga la acción (su presencia en el mercado, es decir, cuan frecuentemente se transan). Pocas acciones se logran vender a su valor real.

#### **13.1.2. La acción como título**

La LSA y RSA regulan el título propiamente tal, y todo el procedimiento de registro de las acciones:

- Registro de accionista
- Quién se entiende accionista –Art 10 LSA- “los que se encuentren en el registro de accionistas a la medianoche del 5to día hábil a la fecha” (leer artículo mejor)
- Procedimiento en caso de pérdidas del título
- Etc.

Las acciones son nominativas. Rol del registro de accionistas: requisito de oponibilidad para la sociedad y para terceros, sin perjuicio de que la cesión sea válida entre las partes. El registro no es el medio para hacer la tradición (oh, no denuevo por favor)

#### **13.1.3. La acción como derecho**

En síntesis (veremos varios de estos derechos más adelante):

- Derecho a la información: de cómo van los negocios y una serie de temas.
- Derecho a voto: a menos que exista una serie sin derecho a voto.
- Derecho a dividendos

- 
- Derecho a recuperar su aporte –o parte- en la liquidación
  - Derecho a ceder sus acciones (recordar que la regla general es que se puedan vender o transferir)
  - Derecho de suscripción preferente de acciones emitidas en aumentos de capital
  - Derecho a convocar a juntas de accionistas
  - Derecho a retiro (solo en los casos del art. 69 LSA).

### **13.2.Las acciones preferentes**

*Son las privilegiadas, a las que se les concede un derecho adicional por sobre el resto.*

Requisito de toda preferencia:

#### **1. Debe estar establecida en los estatutos sociales.**

-la creación, modificando o supresión de preferencias es materia de JEA (junta extraordinaria de accionistas), y tiene un quorum de 2/3 (NO DE LAS ACCIONES) de la serie afectada [OJO EN ESTO].

**2. La preferencia debe constar en los títulos de las acciones.** No es necesario que tenga una larga explicación, el cartón al menos dirá 100 acciones de la serie A conforme a los privilegios establecidos en la escritura de fecha tanto].

¿Cuál será el contenido de la preferencia? Autonomía de la voluntad, sujeta a ciertas limitaciones. Las preferencias pueden incluso ser extralegales.

#### **Limitaciones al establecimiento de preferencias**

1. No pueden establecerse preferencias sin precisar su plazo de vigencia
2. No puede pactarse una preferencia que consista en el otorgamiento de dividendo que no provengan de utilidades líquidas del ejercicio o de utilidades retenidas (ppio de mantener el capital)
3. En SAA, las preferencias que otorguen a una serie de acciones preeminencia en el control de la SA podrán ser por un plazo máximo de 5 años (renovable pero por JEA)
4. No pueden establecerse serie de acciones con voto múltiple, ya que haría que se perdiera la democracia dentro de la sociedad.

Jueves 18 de octubre de 2018

### **13.3.La acción como fuente de derechos**

En esta clase veremos dos derechos, que debemos analizar:

- Derecho a retiro: es más complejo, por eso se analizará.
- Dividendo: se analiza porque es el más importante, queremos ganancia.

#### **A. Derecho a retiro en las S.A.**

En determinadas circunstancias (Art. 69 LSA y otros casos establecidos en la Ley) *es la facultad del accionista de “venderle” sus acciones a la Sociedad, a un determinado precio.* Este no es un derecho permanente, es en circunstancias particulares. No es un put option en el que en cualquier momento

puede venderle las acciones a la sociedad. La ley establece determinados casos en que se puede ejercer este derecho (esto porque recordar que la venta de acciones de propia emisión infla el capital). **Esta facultad de vender sus acciones a la sociedad, se gatilla por un hecho determinado, se regula un plazo y un precio.**

- **SAA:** la determinación del precio es más sencillo. La ley distingue:
  - **Con presencia bursátil:** Art. 132 RSA. Presencia bursatil se refiere a que existen transacciones activas en las bolsas de comercio. La CMF lo determina. Es muy cotizada. Lo que dice la ley es *pagar un promedio del valor en una determinada fecha: entre 30 y 60 días contados hacia atrás desde la junta. Es el promedio de su valor de mercado.*
  - **Sin presencia bursátil:** Valor Libro. Todo lo contrario, no se transan casi nada en bolsa. Hay que dividir el patrimonio en el numero de acciones.
- **SAC:** Valor libro.

Particularmente relevante en SAC, o SAA con poca presencia bursátil, porque protege a accionistas con muy poca liquidez (normalmente minoritarios). Quizas el valor libro es super alto, pero si por ejemplo tu tienes el 20% y eres honrado y ordenado, y el otro 80% lo tiene gente desprestigiada. Nadie querría integrar una sociedad en la cual el 80% esta en manos de personas desprestigiadas. Entonces si quisiera salir al mercado nadie me compraría. Por esta razón, **si se toma una decisión con la que no se está de acuerdo, se le puede exigir a la sociedad que compre mis acciones a un precio justo.**

- En cierto sentido perjudica a los acreedores, por lo que la Ley limita su aplicación a casos extraordinarios, y se suspende en caso de procedimiento concursal de liquidación o reorganización. Esto porque “supondría una disminución de patrimonio”. Por esta razón, la ley menciona dos limitaciones: la primera es la que ya mencionabamos, los casos en los que aplica el derecho a retiro deben estar regulados. La otra es que en el derecho a retiro se suspende el pago en dos hechos muy relevantes: procesos concursales de liquidación y reorganización.
- Es uno de los excepcionales casos en que la Sociedad está autorizada para adquirir acciones de propia emisión.

#### **Casos en que procede el derecho a retiro: artículo 69 LSA:**

1. **La transformación** de la sociedad: por ejemplo de S.A a SPA.
2. **La fusión de la sociedad:** por ejemplo si soy dueño mayoritario de una sociedad y dueño completo de otras, puedo querer fusionar las dos sociedades. Pero perjudicaría a los minoritarios de la primera si es que le asigno o sobrevaloro la sociedad.
3. **Las enajenaciones a que se refiere el N° 9) del artículo 67;** (3 escenarios):

Art. 67. Los acuerdos de la junta extraordinaria de accionistas que impliquen reforma de los estatutos sociales o el saneamiento de la nulidad de modificaciones de ellos causada por vicios formales, deberán ser adoptados con la mayoría que determinen los estatutos, la cual, en las sociedades cerradas, no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto.

Requerirán del voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto, los acuerdos relativos a las siguientes materias:

9) **ESCENARIO 1:** La enajenación de 50% o más de su activo, sea que incluya o no su pasivo, lo que se determinará conforme al balance del ejercicio anterior, **ESCENARIO 2:** y la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un monto que supere dicho porcentaje; **ESCENARIO 3:** la enajenación de 50% o más del activo de una filial, siempre que ésta represente al menos un 20% del activo de la sociedad, como cualquier enajenación de sus acciones que implique que la matriz pierda el carácter de controlador;

#### 4. El otorgamiento de las cauciones a que se refiere el N°11) del artículo 67;

11) El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros que excedan el 50% del activo, excepto respecto de filiales, caso en el cual la aprobación del directorio será suficiente;

Las sociedades tienen su patrimonio y van a responder por las operaciones de sus filiales, pero no van a responder por las operaciones o transacciones de terceros, por ejemplo, del socio controlador. Si me compro una casa y soy controlador de una sociedad y quiero pedirle que me afiance una obligación personal, se configura este caso.

5. **La creación de preferencia para una serie de acciones o el aumento, prórroga o la reducción de las ya existentes.** En este caso, tendrán derecho a retiro únicamente los accionistas disidentes de la o las series afectadas;
6. **El saneamiento de la nulidad causada por vicios formales de que adolezca la constitución de la sociedad o alguna modificación de sus estatutos que diere este derecho.**
7. **Los demás casos que establezcan la ley o sus estatutos, en su caso: esto hace que no sea taxativo.**

Ejemplos: **Art. 2 inc 5** (una S.A.A a S.A.C, cancelando su inscripción en el registro de valores, no se cuenta en el primero porque sigue siendo sociedad anónima), **69 bis** (se refiere a las sociedades anónimas controladas por el Estado, cuando hay un cambio normativa que se considera arbitrario y que afecte los derechos de la sociedad, da derecho a retiro), **71 bis LSA** (cuando un controlador adquiere el 95% de la sociedad, quedan tan en desmedro los accionistas de ese 5% restante, que pueden pedir este derecho).

#### ¿Quién tiene derecho a retiro?

- **“EL ACCIONISTA DISIDENTE”:** este es el concepto importante.
  - Asistió a la Junta, y se opuso.
  - No asistió, y comunica su oposición dentro de los 30 días siguientes.
- La abstención no vale como oposición.
- El derecho a retiro es por TODAS las acciones que tenía el disidente, y sólo comprende las acciones tenía inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas a la fecha que determina su

derecho a participar en la junta. Es o todas o ninguna. ¿Cuándo se determina este derecho a participar en la junta? R:

- SAA: 5 días antes de la Junta (art. 62)
- SAC: al día de la Junta.
- Excepción: pueden ejercer parcialmente el derecho aquellas entidades legalmente autorizadas para mantener en custodia acciones por cuenta de terceros, pero a nombre propio. (Art. 129 RSA). Por ejemplo, un Banco. Este es el único caso en el que se pueden dividir las acciones respecto de las cuales se utiliza el derecho a retiro.
- **¿Qué pasa si 2/3 aprueba una fusión, y el tercio restante decide retirarse?**
  - Directorio puede citar a nueva Junta (extraordinaria) que reconsidere la decisión (Art. 71 LSA).
  - Queda la escoba. Sería un impacto muy grande para la sociedad. Por eso esta solución.

**Ejemplo:** Hubo una junta de fecha 23 de julio, se tomaron tales decisiones. Se abre un periodo de un mes para que los accionistas utilicen su derecho a retiro y una vez señalado el periodo el gerente general debe informar al mercado que tantas personas ejercieron su derecho a retiro y lo van a pagar.



## **HECHO ESENCIAL** **SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A.** (Inscripción Registro de Valores N°0362)

Santiago, 23 de agosto de 2018  
Acc.-074/2018

Señor  
Joaquín Cortez Huerta  
Presidente  
Comisión para el Mercado Financiero  
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449  
Santiago.

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, y estando debidamente facultado, informo a usted con carácter de Hecho Esencial de Sociedad Punta del Cobre S.A., ("la Sociedad" o "Pucobre") que con fecha 22 de agosto de 2018, ha expirado el plazo de que disponían los accionistas disidentes para ejercer el derecho a retiro que se originó por (i) la fusión por incorporación de Pacífico V Región S.A. en la Sociedad; y/o (ii) por la eliminación de las series de acciones en que se encontraba dividido el capital social, pasando a denominarse en acciones ordinarias de una misma serie. Los acuerdos antes referidos fueron aprobados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Pucobre celebrada con fecha 23 de julio de 2018.

Durante el plazo comprendido entre el 23 de julio y el 22 de agosto de 2018 ejercieron el derecho a retiro accionistas que representan en conjunto 813.894 acciones serie-A de la Sociedad, lo que equivale a un 0,6% del total de las acciones emitidas por la Sociedad. De acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, Pucobre pagará el precio de las acciones de los accionistas disidentes, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, dentro de los 60 días siguientes al 23 de julio de 2018, fecha en que se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas antes referida.

---

**B. Balances, resultados y distribución de dividendos de la S.A (Segundo derecho que se verá)**

A diferencia del derecho a retiro que casi nunca se utiliza, sino que, en eventos determinados, este derecho es realmente importante y frecuente. Este es el derecho más importante que emana de la calidad de accionista o de acciones. En primer lugar, hablaremos de balances.

- **Obligación de todo comerciante:** llevar contabilidad de sus operaciones. La S.A. no es la excepción.
  - Art. 73 LSA: “*Los asientos contables de la sociedad se efectuarán en registros permanentes, de acuerdo con las leyes aplicables, debiendo llevarse éstos de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general*” (IFRS o NIIF).

La sociedad anónima tiene una función social tremenda, ya que capta dinero del público, sale a ofrecer sus valores directamente. Hay mucha gente involucrada, por lo que por temas de fe publica, al legislador le interesa que la contabilidad sea llevada en estándares uniformes, que le permita al inversionista hacer comparaciones entre invertir en A o en B. Debe haber un estándar. En Chile durante muchos años estuvieron vigentes las reglas generales de contabilidad del colegio de contadores. Hace un par de años, se cambió por las normas IFRS o NIIF. Estos son estándares internacionales. Si bien no es obligatorio, en la actualidad ya todos se cambiaron.

- **Por defecto**, el ejercicio se cierra al 31/12. Podrían cambiarlo, pero en la práctica se haría muy difícil. Todos los plazos se hacen de acuerdo al año fiscal.
- **Lo prepara la administración, quien lo somete al directorio, y es este quien lo presenta a la Junta Ordinaria de Accionistas:** debe presentar al menos estas cuatro cosas:
  - Memoria: análisis razonado de las operaciones de la compañía. “Nos cambiamos de lugar, abrimos tal sucursal, etc”. Es como un relato, no es información tan numérica.
  - Balance: Activos + (Pasivos)= Patrimonio. Es una foto del patrimonio de la sociedad, en una fecha determinada. Nos permite observar la solvencia de la sociedad.
  - Estado de Resultados: muestra las ganancias o pérdidas del ejercicio. Es como una película del periodo finalizado a una fecha determinada. Es dinámico y nos permite ver los resultados del periodo.
  - Informe de auditores externos o inspectores de cuenta.
- **Art. 90 LSA:** La existencia de sociedades filiales obliga a la sociedad matriz a /i/ confeccionar el balance anual en forma consolidada y /ii/ el dividendo mínimo establecido en el artículo 79 de esta ley deberá calcularse sobre las utilidades líquidas consolidadas. A pesar de ser personas jurídicas diferentes, lo que se quiere es mostrar al inversionista la información más completa posible. Ver en el PPT ejemplos de balance, estado de resultados
- **Art. 56 N°1: el análisis de los balances y EE.FF es materia de JOA por excelencia.** Es quizás la razón de ser de la JOA.
- Distinción anterior es más bien contable: la LSA pareciera ocupar ambos conceptos con mayor laxitud. Ej. Art. 78 LSA.
- Art. 77 LSA: Si la JOA rechaza el “balance”, el directorio debe someter un nuevo a su consideración dentro del plazo de 60 días. Si este también es rechazado, el directorio se entenderá revocado, y los miembros que lo aprobaron inhabilitados. Es un castigo importante. Los miembros que aprobaron este balance, quedan inhabilitados para ser directores. **Todo esto, no se contrapone a acciones de responsabilidad personal de los directores.**

¿A quien mira la información financiera?

- Terceros:
  - Inversionistas.
  - Acreedores.
  - ¿Estado? Sí, sin perjuicio de que la contabilidad financiera  $\neq$  contabilidad tributaria. Hay otras disposiciones que sí usan la contabilidad financiera, por ejemplo en materia de libre competencia (particularmente en fusiones u operaciones de concentración que deben ser sometidas a la FNE)
- Accionistas:
  - Determinar el más relevante de los derechos económicos: Los Dividendos.

Ahora sí, vamos al tema central.

**Dividendos (este es el derecho como tal)**

- Puelma: “*Aquella parte de la utilidad que una sociedad acuerda repartir a sus accionistas*”. No es toda la utilidad, ya que pueden decidir distribuir solo el 30% o el 40%. Dividendo es solo lo que efectivamente se distribuye.
- La participación en los beneficios (utilidades) es un elemento esencial de toda sociedad.
- **Los dividendos se reparten en proporción al número de acciones que cada accionista tenga**, de una sola serie, o distinguiendo por series en caso de que ésta tenga alguna preferencia relativa a dividendos. Si hay series de acciones, una preferencia habitual es el “superdividendo”.

**Utilidades vs. Pérdidas (Art. 78 LSA)**

- No habrá dividendos, si la sociedad no tiene utilidades líquidas del ejercicio o utilidades retenidas de ejercicios anteriores (Si no, es disminución de capital).
- Al contrario, si la Sociedad tiene pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio se destinan primeramente a absorber las pérdidas.
- Si hay pérdidas en el ejercicio, éstas serán absorbidas por las utilidades retenidas.

**¿Quién tiene derecho a recibir dividendos?** Las acciones normalmente se transan. Por lo que puede tener varios dueños. Es importante determinar cuál de los dueños obtendrá dividendos.

- Accionistas inscritos en el Reg. de Accionistas el quinto día hábil anterior a la fecha establecida para el pago.
  - **¿Qué pasa si alguien vendió justo después de la JOA? ¿Qué pasa legalmente, y financieramente?** El efecto financiero es que al final se va a reflejar en el precio, por lo que no saldría perdiendo el que la vendió.
- ¿Qué pasaba con las acciones suscritas y no pagadas? (Art. 16 LSA). No tiene derechos económicos, pero sí políticos, no obstante, no es una regla de orden público, sino de orden privado y las partes podrían modificarlo.

**Tipos de dividendos**

i. Dividendos Provisorios vs. Definitivos.

- **Definitivos:** aprobados por la JOA, en base al ejercicio cerrado. Del que hemos venido hablando.
- **Provisorios:** aprobados por el directorio, bajo responsabilidad personal de sus miembros, con cargo a las utilidades del ejercicio. Puede que en el mes de enero, mucho antes de la junta de abril, se sepa que le fue bien a la sociedad. Los directores podrían distribuir antes y esto ya no es un resorte de la junta, sino del directorio. Los directores en este caso se hacen responsables personalmente por ese dividendo. Ese dividendo se imputa a las utilidades del ejercicio. Este dividendo se va a contar en la junta ordinaria cuando se haga el definitivo. El provisorio “adelanta” el pago.

ii. Dividendos mínimos, adicionales y eventuales.

- **Mínimo:** SAA mínimo de 30% de sus utilidades líquidas del ejercicio, salvo acuerdo unánime de las acciones emitidas. SAC, lo que diga el estatuto, y si nada dice, mínimo de 30%.
- **Adicionales:** los que acuerda la Junta por sobre el mínimo.
- **Eventuales:** utilidades de un ejercicio que se reparten en ejercicios siguientes (utilidades retenidas).

Supongamos que en el año 2017 nos fue bien, repartimos 30% y el resto libre. El 2018 nos fue muy bien, repartimos 30% y dejamos el resto libre. El año 2019 tenemos pérdidas y entonces hay que pagarlas y además también se podría repartir utilidades.

- **¿Por qué usted retendría utilidades?** R: para satisfacer contingencias futuras. Por ejemplo si hay un crédito a largo plazo. También podría ser que se quiera aumentar el capital en el futuro y no e le quiere salir a pedir a los accionistas, de esta forma se podría capitalizar las utilidades. También puede ser para que el día en que nos vaya mal, podamos seguir distribuyendo utilidades.

iii. Dividendos Opcionales (Art. 82 LSA): “en las SAA se podrá cumplir con la obligación de pagar dividendos, en lo que exceda a los mínimos obligatorios (...) otorgando opción a los accionistas para recibirlos en dinero, en acciones liberadas de la propia emisión (liberadas de pago) o en acciones de sociedades anónimas abiertas (no pueden ser cerradas) de que la empresa sea titular”.

**Forma de pago de dividendo:** Art. 82 LSA: “Salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva por la unanimidad de las acciones emitidas, los dividendos deberán pagarse en dinero”.

Excepción: dividendos opcionales SAA.

Incumplimiento en el pago del dividendo

- **Art. 83 LSA:** El acta certificada de la Junta o Directorio que acordó pagar el dividendo, sirve como título ejecutivo para su cobro.
- **Art. 84 LSA:** Los dividendos no pagados se reajustan por UF, entre la fecha que se hicieron exigibles y la del pago efectivo + interés corriente.

- **Art. 85 LSA:** Por el contrario, los dividendos y demás beneficios en efectivo no reclamados por el plazo de 5 años desde que son exigibles, pertenecerán al Cuerpo de Bomberos de Chile.

Martes 23 de octubre de 2018

#### 14. DIVISIÓN, TRANSFORMACIÓN Y FUSIÓN

**¿Por qué son tan importantes?** R: porque estas decisiones o modificaciones cambian o impactan en la esencia jurídica de la sociedad. Estos tres tipos de modificaciones sociales, impactan el corazón mismo de la persona jurídica.

**¿Dónde se encuentra normado?**

- Título IX de la LSA (bastante escueto)
- Título IX del RSA (mayor desarrollo)

**Son modificaciones sociales, de particular relevancia en la personalidad jurídica de la sociedad.**

- **Crean nuevas personas jurídicas**
- **Cambian el tipo social**, que es la estructura misma de la persona jurídica.
- **Disuelven persona jurídica:** por ejemplo en la fusión se disuelven las sociedades absorbidas

**Formalidades:** Materia de junta extraordinaria de accionistas, con Quorum especial del artículo 67 (2/3 acciones emitidas con derecho a voto). Se aplican las mismas formalidades que cualquier modificación social, más las adicionales que determine la LSA y el RSA.

##### 14.1. Transformación de una sociedad anónima

**Artículo 96 LSA:** “La transformación es el (i) cambio de especie o tipo social de una sociedad, (ii) efectuado por reforma de los estatutos, (iii) subsistiendo su personalidad jurídica (numeración es nuestra)

Efectos:

- **Subsiste la personalidad jurídica**, no hay una nueva sociedad. Los socios, el rut, son los mismos.
- **No se requiere de nuevos aportes**
- **Los socios conservan su participación en el capital** (sí puede cambiar su denominación). Por ejemplo, si se cambia a una de responsabilidad limitada, se habla de derechos sociales, no de acciones.
- **No hay término de giro, inicio de actividades, ni nuevo Rut**
- **De derecho a retiro, son decisiones sensibles.** Por ejemplo, si se cambia a una de responsabilidad limitada, es normal que muchos socios exijan derecho a retiro, ya que no podrán vender sus acciones libremente con este régimen.
- **Si puede haber diferencias a nivel tributario en el régimen de renta.** Con el régimen actual quedó todo muy enredado, y esos regímenes no son para toda sociedad, hay algunos que exigen que sea sociedad de personas o de capital. Entonces para efectos de renta, es posible que, si se produzcan efectos por la transformación, en el sentido que el régimen se va a determinar en virtud del sistema que tenga la sociedad hasta el día de la transformación, se hace un balance de giro, se terminan los impuestos adeudados y se sigue con el nuevo sistema de renta aplicable.

#### 14.1.1. Requisitos de la Transformación:

- i. JEA + Notario.
- ii. Reducción a E.P., una vez vencido el plazo para ejercer el derecho a retiro -30 días- (normalmente se puede reducir inmediatamente, esta diferencia se justifica en que es necesario determinar a los socios que efectivamente se quedarán y para el capital). Extracto inscrito y publicado.
- iii. Voto favorable de 2/3 acciones emitidas con derecho a voto.
- iv. **(Particularidad)** A más tardar a la fecha de la primera citación a la JEA, se debe poner a disposición de los accionistas:
  - i. Proyecto de estatuto de la sociedad resultante.
  - ii. Relación de canje propuesta entre acciones/derechos y derechos/acciones.

#### ¿Cuándo se producen los efectos?

- Acta reducida a E.P., inscrita y publicada oportunamente (sin efecto retroactivo a diferencia de otras modificaciones sociales).

#### ¿Qué pasa con la limitación de responsabilidad?

- Soc. En Comandita o Colectiva a S.A.: art. 98. La solución justa que establece la ley, es que los contratos celebrados se van a ver protegidos por el régimen de responsabilidad que la sociedad tenía al momento de contraer la obligación o suscribir dicho crédito.

#### 14.2. Fusión de una sociedad anónima

**Art. 99 inc. 1ero.** *“La fusión consiste en /i/ la reunión de dos o más sociedades en una sola /ii/ que las sucede en todos sus derechos y obligaciones, y /iii/ a la cual se incorporan la totalidad del patrimonio y accionistas de los entes fusionados”.* (Numeración es nuestra).

Es tomar dos sociedades y las reunimos en una sola, ya sea porque creamos una tercera o porque una absorbe a la otra.

#### • Tipos de Fusión:

- **Fusión por creación:** todo el activo y pasivo de dos sociedades o más que se disuelven, se aportan a una que se constituye (que tendrá nuevo rut, nueva persona jurídica, etc)
- **Fusión por incorporación:** una o más sociedades que se disuelven son absorbidas por una sociedad ya existente, la que absorbe el total del activo y pasivo de las absorbidas y esta es la continuadora.

#### • Efecto en la sociedad absorbida/fusionada:

- Se disuelve, pero no procede liquidación.
- Los bienes, derechos y obligaciones se radican en la continuadora.
- Por tanto, no hay transferencias de dominio ni cesiones de deuda. La sociedad post-fusión, es continuadora por el solo ministerio de la ley. Que esto sea así, no quiere decir que siempre sea así en la práctica, por una cosa bien sencilla:
  - **Porque existen los bienes registrables** y en este caso la sociedad absorbente lo que va a hacer es que va a ir a todos los registros de propiedad donde la sociedad absorbida tenía bienes raíces y se va a pedir que anote al margen quien es el

nuevo dueño. Ante esto, solo es una nota marginal, no una nueva inscripción. Un conservador que no sabe tanto, puede hacer una nueva inscripción. Lo mismo ante el registro civil (respecto de los automóviles)

### Requisitos de la Fusión:

- i. JEA + Notario por cada sociedad participante de la fusión (si se fusionan 3 sociedades, debe hacerse 3 juntas). Voto favorable de 2/3 acciones emitidas con derecho a voto (art. 67). Todas las juntas deben aprobar lo mismo.
- ii. El directorio debe poner a disposición de los accionistas (art. 155 RSA) (por página web o correo):
  - i. **Términos y condiciones de la Fusión:** es un documento en el que va a constar la individualización de las sociedades que forman parte de la fusión, cuales son los términos y condiciones, como se llegó a tales números, tendrá todos los elementos necesarios para la función.
  - ii. **Balances auditados de cada sociedad:** no nos sirve que cada gerente tenga su metodología para determinar su balance, lo que quiere la ley es que todos los balances sean llevados por el valor más generalmente aceptado.
  - iii. **Informe Pericial:** es tremendamente importante ya que un profesional independiente a la sociedad lo que hace es principalmente hacer la valoración de las diferentes sociedades que intervienen en la fusión y en base a eso determinar una regulación legal. Al tener esa valoración se puede ver la relación de canje.

**Cada uno de estos antecedentes se manda a cada una de las juntas y cada junta deberá determinar un perito (sin perjuicio de que en las S.A.C (o SpA, el profe no lo dijo bien) pueden ponerse de acuerdo para designar al mismo perito)**

- iii. Red. a E.P. (conjunta o separada) y extracto inscrito y publicado. Conjuntamente con reducir a E.P., se protocolizan los documentos anteriormente mencionados.
- iv. Requisitos especiales en caso de que sea Operaciones con partes relacionadas (en adelante OPR)

### Varios datos relacionados a la fusión

- **Relación de canje:** es cuantas acciones de la nueva sociedad se le deben dar a un accionista por las que ya tenían. La relación de canje la determina la junta extraordinaria de accionistas, no el perito. El perito solo informa la relación de canje, pero esta es determinada libremente por las partes.
- **Fusión impropia (art. 103 –causal de disolución-). (otro tipo de fusiones):** las S.A. requieren de tener dos o más accionistas y si tienen solo uno, es causal de disolución. Una manera de fusionar a costo muy barato una sociedad matriz con la filial, es que la matriz compre todas las acciones de la filial. Se produce la disolución de pleno derecho.
- **Fusión inversa:** es menos habitual porque normalmente la matriz absorbe a su filial. Pero hay determinados casos en que se quiere dejar como continuadora legal a la filial, ya que tiene determinados contratos o negocios que son importantes y no se pueden ceder en algunas oportunidades. En este caso es la filial la que absorbe a la matriz y se produce una disminución de capital.

### 14.3. División de una sociedad anónima

**Art. 94 LSA.** *“La división de una S.A. consiste en la /i/ distribución de su patrimonio entre sí y una o más sociedades anónimas que se constituyan al efecto, /ii/ correspondiéndole a los accionistas de la sociedad dividida, la misma proporción en el capital de cada una de las nuevas sociedades que aquella que poseían en la sociedad que se divide”.* (Numeración es nuestra).

En este caso, se tiene una sociedad que se dedica a la agricultura y al ámbito forestal y se quiere dividir para separar los giros. En este caso se divide esa agrícola y forestal y queda agrícola por un lado y forestal por el otro lado. ¿Cuál será el capital de esas sociedades? R: el que los accionistas decidan. Es como si tuvieran dos canastos y pudieran escoger a donde van los activos, pasivos, deudas, etc.

En este caso el patrimonio se ha dividido en dos, pero la participación de los accionistas es la misma. Si antes tenía un 20% del capital, ahora tengo acciones en ambas sociedades, pero siguen representando el 20%.

**Art. 149 RSA.** *“Cada nueva sociedad que se constituye producto de la división, se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente a la sociedad dividida respecto de los bienes que se le hubieren asignado”.*

Solo una es continuadora legal (la escidente, la que tendrá que disminuir su capital), las demás son nuevas sociedades que se constituyen (la escindida). En propiedad, es una modificación social en la escidente, y la constitución de la escindida. En la escidente es meramente una modificación social, mientras que en la escindida hay nuevas sociedades y no es una modificación social, sino que en propiedad es una constitución.

No da Derecho a Retiro. ¿Por qué creen ustedes? R: se mantienen los mismos socios y la misma participación en el capital. No han sido menoscabados en sus derechos, por eso no pueden tener derecho a retiro.

#### 14.3.1. Requisitos

- i. JEA + Notario. Voto favorable de 2/3 acciones emitidas con derecho a voto.
- ii. El directorio debe poner a disposición de los accionistas los antecedentes del art. 147 RSA.
- iii. Red. a E.P. y extracto (2) inscrito y publicado. Ya no se hace un extracto, sino que se hacen dos. Hay dos sociedades, por lo tanto se hacen dos: uno de modificación (escidente) y una de constitución (escindida)

#### 14.3.2. Situación especial de los pasivos en la división:

Antes los acreedores tenían un gran patrimonio, al dividirse podría producirse un conflicto. Por esto, la LSA se encarga de ello:

**Art. 148 inc. 2 y 3 RSA:** *“La delegación de obligaciones de la sociedad dividida a una sociedad que se crea producto de la división, no produce novación si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre a la sociedad dividida.*

A falta del consentimiento del acreedor, se entenderá que la nueva sociedad es solamente un diputado por la sociedad dividida para hacer el pago, o que, según se acordó en la junta de dicha sociedad, la nueva sociedad es solidaria o subsidiariamente responsable de esa obligación frente al acreedor."

**Los acreedores tienen el derecho de perseguir los bienes y el patrimonio de cualquiera de las dos sociedades.**

#### 14.3.3. Regla común a división, fusión y transformación

**Art. 100 LSA.** *"Ningún accionista, a menos que consienta en ello, podrá perder su calidad de tal con motivo de un canje de acciones, fusión, incorporación, transformación o división de una sociedad anónima."*

Si en la relación de canje, el accionista tuviera un porcentaje menor a una acción (0,001, por ejemplo) y por ende perdería su calidad de accionista, la sociedad tiene que concederle al menos una acción. En este caso normalmente se redondea hacia arriba.

Jueves 25 de octubre de 2018

**El profesor revisa algunas preguntas de la solemne.** Recomendando mirar el ppt, para entender las respuestas correctas. Algunos comentarios que me parecieron relevantes:

- En el pacto del Lock-up, se afecta a todos los socios, no solo a uno. Normalmente todos están impedidos de ceder sus acciones. Es como cerrar con candado la sociedad
- En cuanto a las diferencias entre sociedades de capital y sociedades de persona: son la confianza, el régimen de responsabilidad (regla general es ilimitada en las de personas y limitada en las de capital), la cesibilidad, la administración (más flexible en las de personas y más estricta en las de capital, aunque las SPA son muy flexibles y son de capital), las solemnidades (son más solemnes las de capital), y las causales de disolución son diferentes.

#### 15. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

Las causales de disolución que estaban en el código civil que se aplicaban a las colectivas o a las limitadas, difieren bastante de las S.A. principalmente por su carácter de sociedad de capital.

##### 15.1. Causales de disolución (Art. 103 LSA): (no es un catalogo cerrado, pero comprende casi todas)

- Por el vencimiento del plazo de su duración, si lo hubiere,** esto es poco usual, ya que casi siempre ponen plazo indefinido.
  - Rara vez lo hay. Es una causal muy en desuso.
- Por reunirse, por un período ininterrumpido que exceda de 10 días, todas las acciones en manos de una sola persona:** hay que recordar que la concepción de sociedad antigua entendía que la sociedad siempre debía estar formada por al menos dos personas.
  - Excepción 1: si se transforma en EIRL dentro del plazo de 30 días desde que se produjo la reunión. Esto puede servir para salvar la sociedad.

- ii. Excepción 2: Art. 107 para SAA y S.A. Especiales no se produce la disolución hasta que es aprobada por la Comisión para el Mercado Financiero o el órgano de supervisión. Entonces apenas se produzca el registro de la última transacción que dio lugar a que un solo accionista fuera el dueño, tiene que aprobar.
    - i. ¿No decíamos que las acciones se adquirirían con el traspaso, y no con la inscripción en el Registro? R: esta es una excepción al parecer.
  - iii. Vimos la clase anterior el concepto de Fusión Impropia, esto es lo mismo. Cuando una sociedad adquiere todas las acciones de otra sociedad y pasan 10 días, se disuelve de pleno derecho.
- iii. **Por acuerdo de junta extraordinaria de accionistas;**
- i. Es similar a modificación social.
  - ii. JEA + Notario: Quorum de 2/3 acciones emitidas con derecho a voto.
  - iii. Extracto inscrito y publicado.
- iv. **Por revocación de la autorización de existencia de conformidad con lo que disponga la ley;**
- i. Aplica a S.A. Especiales.
  - ii. Causales Especiales: en cada ley (la general de bancos, la que crea la afp, etc)
  - iii. Causales Generales: “por infracción grave de ley, de reglamento o de las normas que le sean aplicables” (Art. 104 LSA).
  - iv. OJO Norma de Responsabilidad Gerente y Directores (Art. 106 LSA).

Art. 106. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 133, se presumen culpables y serán solidariamente responsables de los perjuicios que eventualmente se causaren a los accionistas, los directores y el gerente de una sociedad que haya sido disuelta por sentencia judicial ejecutoriada o revocada por resolución fundada de la Superintendencia, a menos que constare expresamente su falta de participación o su oposición al o los hechos que han servido de fundamento a la resolución judicial o administrativa.

- v. **Por sentencia judicial ejecutoriada en el caso de las sociedades anónimas cerradas (Art. 105 LSA), y**
- i. Demandan accionistas que representen al menos el 20% del capital social.
  - ii. Causales: “por estimar que existe causa para ello, tales como infracción grave de ley, de reglamento o demás normas que les sean aplicables, que causare perjuicio a los accionistas o a la sociedad.” Todo esto se ve en juicio sumario.
  - iii. OJO Norma de Responsabilidad Gerente y Directores (Art. 106 LSA).

**¿Ahora, pueden exonerarse de su responsabilidad?** Pueden exonerarse, pero deben representar los actos o determinar su oposición.

- vi. **Por las demás causales contempladas en el estatuto.**
- vii. **Habría que agregar: por declaración de nulidad.**

## 15.2. ¿Cómo se materializa la disolución?

- a. Acordada por JEA: ya lo vimos.
- b. **¿Reunión de Acciones, Llegada del Plazo o Causal Establecida en los Estatutos?**

- 
- i. Directorio debe dejar constancia por E.P. dentro del plazo de 30 días. Luego se inscribe y publica.
  - c. **¿Sentencia, revocación de existencia o declaración de nulidad?** El directorio debe dejar nota al margen de la inscripción social. "Por tal x razón se disuelve la sociedad".

¿Cuándo se producen los efectos? Cumplida la última formalidad (salvo la reunión de acciones, ya que al estar en la ley, opera prácticamente de pleno derecho).

### 15.3. Efectos de la disolución

- i. Subsiste la personalidad jurídica, y la sociedad opera bajo R.S. + "*en liquidación*".
- ii. Se mantienen vigente los estatutos en lo referido al proceso de liquidación.
- iii. Las acciones siguen existiendo y se pueden enajenar libremente.
- iv. Se mantiene la limitación de responsabilidad.
- v. Se mantienen las Juntas de Accionistas, pero el Directorio es reemplazado por el liquidador o comisión liquidadora.

Miércoles 31 de octubre de 2018

### 15.4. Efectos de la liquidación de las S.A.

En la vida práctica no se ve tanto, en general o se dejan morir, o se fusionan, etc. Varias alternativas por medio de las cuales no se hace formalmente un proceso de liquidación, o en que las partes simplemente de común acuerdo se distribuyen las cosas, los activos de la sociedad. Lo que vamos a ver está pensado para aquellos escenarios en que la sociedad efectivamente se disuelve.

Desde el momento en que se cumplen todos los trámites de la disolución de la sociedad (como dijimos la clase pasada: el último trámite y sin efecto retroactivo) la sociedad entra formalmente en el proceso de liquidación. Siendo esto no solo es "hacia adentro", sino que se lo debe comunicar al Estado, pasando a llamarse, por ejemplo: Derecho UC SA, en liquidación. Se quiere comunicar al público en general que esta sociedad está en un proceso de liquidación.

**¿Cuándo no hay liquidación?** No hay liquidación en la disolución por fusión (todos los procesos de fusión): ya sea **propia** o **impropia**.

- a) Propia: dos SA acuerdan en la reunión extraordinaria de accionistas que una absorbe la otra. En ese caso la sociedad absorbida en rigor se disuelve, no se liquida.
- b) Impropia: cuando un accionista compra el 100 de las acciones emitidas por una sociedad, se produce la fusión de pleno derecho. Caso en el cual la disolución se asimila a una fusión impropia, no siendo necesaria la liquidación porque hay un solo accionista, para qué se van a repartir si hay solo uno.

### A. Efectos propiamente tales de la disolución

- a) **La sociedad mantiene su personalidad jurídica**: es decir, los efectos de los actos y contratos que la sociedad celebre se radican en la sociedad y no se confunde con los patrimonios de los

---

accionistas individualmente considerados. Por tanto, el patrimonio de la sociedad y sus accionistas continúa separado.

- b) **Se debe agregar el nombre “en liquidación”, para todas las operaciones de la sociedad:** Se comunica al mercado y el público en general que la sociedad se está disolviendo. Nadie querría firmar un contrato de largo plazo, por ejemplo, con una constructora en liquidación.
- c) **Quedan vigentes los estatutos sociales en lo concerniente al proceso de liquidación:** No es que se ponga término a todo el contrato de sociedad, pues queda vigente los estatutos sociales en aquello concerniente a la liquidación. Si los estatutos contemplan reglas especiales de liquidación habrá que estarse a ellas y siguen estando vigentes.
- d) **Las acciones siguen existiendo y se pueden enajenar libremente:** lo que pasa es que esas acciones no dan derecho para la distribución de utilidades en el futuro, ni varios de los otros derechos que vimos de las acciones, pero sí dan derecho a los repartos de remanente del activo que realice en el futuro el liquidador o la acción liquidadora.
- e) **Cesan las funciones de la administración, pero la Junta de Accionistas y los fiscalizadores mantienen sus funciones (importante):** Ya no hay directorio, ya no hay gerente general, ahora quien administra la sociedad es un liquidador o una comisión liquidadora, según sea el caso. No obstante, sigue vigente las facultades de la Junta de Accionistas, y quienes hayan sido los fiscalizadores de la sociedad siguen cumpliendo su rol, ya haya sido una comisión revisora de cuarta o un auditor externo.
- f) **El Directorio es sustituido por la Comisión Liquidadora o el Liquidador.**
- g) **Cesa el objeto social (tremendamente importante):** La constructora Echeverría Izquierdo SA en liquidación ya no es una empresa constructora, ya no va a contratar obras de construcciones, sino que lo que se quiere es simplemente vender el activo y pagar todo el pasivo.

## B. ¿Quién liquida?

Lo habitual es que sea un liquidador o una Comisión Liquidadora

- **Si la disolución ha sido decretada judicialmente:** 1 liquidador, elegido por la Junta, de una quina propuesta por el juez. El juez va a proponer una quina de 5 miembros y la Junta va a elegir a uno de ellos, quien va a ser un único liquidador.
- **En los demás casos,** habrá que ver si el estatuto dispuso o no:
  - Si dispone una forma de liquidación: se estará a esta. Ej: si el estatuto dice que será una Comisión Liquidadora (CL) de 5 miembros, será de 5 miembros, etc.
  - Si no dispone nada: una Comisión Liquidadora formada por 3 integrantes, elegida por la Junta conforme las reglas de votación de Directorio (salvo acuerdo unánime, como se verá en el siguiente punto).
  - Nos podríamos saltar esto, que el estatuto no haya dicho nada, y aun así nombrar 1 solo liquidador y no una CL, pero para ello es necesario el voto unánime.
- **Hay casos especiales** en que la ley dispone de un procedimiento de liquidación: En determinados cuerpos legales se establece que la liquidación de determinadas SAE está sujeta a reglas

especiales, por ejemplo la Compañía de Seguros, que dice que podrá liquidar directamente el Superintendente, lo cual referiría a la SVS, pero actualmente a la CMF.

### **C. Duración de los Liquidadores (Cuánto dura la liquidación)**

- Se trata de una norma de Orden Público (O.P): Plazo máximo de la función liquidadora son 3 años desde su nombramiento. Y si nada se dice, serán esos mismos 3 años.
  - Se pueden reelegir por una vez (art. 111 LSA). Es decir, hasta 6 años. Si la CL no ha terminado de liquidar, ya no se podrá reelegir y habrá que designar a otra si es que todavía falta. Por lo tanto, un proceso de liquidación podría durar más de 6 años, pero no así la CL o el liquidador (pero sería raro que así fuera).
- La CL o el liquidador son revocables anticipadamente
  - a. por la Junta cuando ha sido designada por esta.
  - b. Si han sido elegidos de quinas propuestas por la CMF o la justicia (el juez), se puede revocar, pero requerirá la autorización de estos mismos para revocarlos.

### **D. Atribuciones/Obligaciones de los Liquidadores**

- i. **Efectuar la liquidación de la Sociedad:** Se trata de la obligación esencial. Qué entendemos por liquidar la sociedad:
  - i. Liquidar el activo: es decir, venderlo, llevarlo a plata, chin chin, tan tan.
  - ii. Pagar pasivos: pagar las deudas de la sociedad.
  - iii. Repartir los excedentes –si los hay- entre los accionistas.
- ii. **Administrar la Sociedad:** El Liquidador o la CL continuará administrando la sociedad. Por lo que si hay contratos pendientes de ejecución, tendrá que terminar de cumplirlos, y si la sociedad todavía tiene trabajadores, tendrá que seguir pagando los sueldos, las imposiciones, las obligaciones previsionales, etc
- iii. **Habiendo asegurado el pago de los pasivos, efectuar repartos a los accionistas:** Asegurado, se puede empezar a repartir capital o utilidades obtenidas a los accionistas. Pero tiene que haber asegurado primero que los bienes alcanzan para pagar todos los pasivos, y esto tiene una serie de obligaciones que tiene responsabilidad personal del Liquidador o de la CL. Si reparten toda la plata y no alcanzó para pagar los pasivos, van a responder ellos personalmente.
- iv. **Citar a Juntas de Accionistas cuando se requiera:** Citar ordinariamente a informar cómo va el avance de los negocios, si requiere de la autorización de la Junta para una enajenación en particular, etc.
- v. **Rendir cuentas:** No está en la ley expresamente, pero se entiende que es una obligación conforme a los Principios Generales de Derecho, en que el mandatario está obligado a rendir cuenta de su mandato.

## **16. OPERACIONES DE PARTES RELACIONADAS:**

### **16.1. Breve reseña de la regulación de OPR**

Hasta antes de la llamada “Ley de Gobiernos Corporativos” (2009), era una materia regulada muy pobremente, no distinguía mucho entre las OPR de SAC y las de SAA. Por lo que con la nueva ley se mejora en una serie de cuestiones: todas las materias de conflictos de interés, de administración de la sociedad, de OPR, etc. Lo que busca la ley es, de algún modo, modernizar toda la normativa societaria chilena, poniéndola acorde con los usos internacionales, y garantizar de este modo que los accionistas (sobre todo minoritarios), no se vean vulnerados en sus derechos por parte del controlador. Toda la regulación de OPR está encaminada a proteger siempre al minoritario, porque lo que se teme es que el mayoritario, controlando la SAA de que se trata y otra SAC que es de él (el mismo), no pase plata de la abierta en la que tendría el 55% a la cerrada en la que tendría el 100%, sin tener una justificación económica, o siendo esta inacabada.

Por primera vez la “Ley de Gobiernos Corporativos” distinguió entre S.A. Cerradas y Abiertas, con una salvedad: que las SAA incluyen a sus filiales, cualquiera sea el tipo social, y es lógico que sea así, porque si no el bypass sería muy fácil, no se sacaría plata indebidamente de Empresas COPEC, sino que se sacaría de una SPA que sería una filial, indebidamente. Por ello la ley dice: le voy a aplicar a la SAA y a todas las que estén bajo su control “hacia abajo”.

- a) **¿Cómo se regulan las Cerradas?:** procedimiento está en el Art. 44 LSA. Es relativamente simple: las OPR deben ser aprobadas por el Directorio, con exclusión del director con interés, y el mismo Art. 44 señala quién se entiende ser un *director con interés*. Y obliga a que se informe en próxima Junta a la Junta de todas las OPR que se aprobaron durante el año.
- b) **Abiertas y sus filiales:** Nuevo Título XVI de la LSA, con una regulación nueva y bastante más completa.

Lectura complementaria: C. Eyzaguirre e I. Valenzuela. Según el profesor, leer las primeras 5-7 páginas servirían mucho para el examen

### 16.2. ¿Qué es una OPR?

Definición en el Art. 146 LSA, en el que se dicta primero qué es la operación y el requisito subjetivo: con quién se celebra. Artículo que solo rige para las SAA.

**Art. 146 LSA:** Son OPR de una SAA toda **negociación, acto, contrato u operación** en que deba intervenir la sociedad y, además, alguna de las siguientes personas:

- 1) Una o más personas relacionadas a la sociedad, conforme al artículo 100 de la LMV.
- 2) Un director, gerente, administrador, ejecutivo principal o liquidador de la sociedad, por sí o en representación de personas distintas de la sociedad, o sus respectivos cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive.
- 3) Las sociedades o empresas en las que las personas indicadas en el número anterior sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital, o directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales.
- 4) Aquellas que establezcan los estatutos de la sociedad o fundadamente identifique el comité de directores, en su caso, aun cuando se trate de aquellas indicadas en el inciso final del artículo 147.
- 5) Aquellas en las cuales haya realizado funciones de director, gerente, administrador, ejecutivo principal o liquidador, un director, gerente, administrador, ejecutivo principal o liquidador de la sociedad, dentro de los últimos dieciocho meses.

---

**16.3. Hay 2 elementos:**

- A) **Elemento objetivo:** Una definición muy amplia al decir “**toda negociación, acto, contrato u operación**”, si solo hubiera dicho “acto o contrato”, o incluso “acto, contrato u operación”, se habría entendido que referiría a un contrato efectivamente firmado. Al decir “negociaciones” se amplía mucho el ámbito de aplicación de la norma, porque se refiere también a todo acto preparatorio, oferta, negociación, intento, etc. “Usted no se acerque a hacer negocios con la SAA si es que es una parte relacionada sin antes pasar por este procedimiento”. La ley ha sido extremadamente estricta. Este es el primer requisito, de tipo objetivo: cuál es el tipo de operación que se persigue
- B) **Elemento subjetivo:** Y el segundo requisito es el **requisito subjetivo**: con quién se tiene que celebrar.
- 1) *Una o más personas relacionadas a la sociedad, conforme al artículo 100 de la LMV.* Puede parecer chino, pero cuando se intenta definir con propias palabras la OPR, por lo general se dice la que se encuentra en la LMV
  - 2) *Un director, gerente, administrador, ejecutivo principal o liquidador de la sociedad, por sí o en representación de personas distintas de la sociedad, o sus respectivos cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive.* Se traspapelan también con personas del Art. 100 de la LMV. Refiere a cualquier persona que tenga un cargo relativamente alto en la sociedad, con influencia, poder en la administración, se va a considerar persona relacionada.
  - 3) *Las sociedades o empresas en las que las personas indicadas en el número anterior sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital, o directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales.* Si se dejara solo con el N° 1 Y 2, sería muy fácil para el director, su cónyuge, el gerente, etc. Por lo que se incluye a las sociedades de estas personas
  - 4) *Aquellas que establezcan los estatutos de la sociedad o fundadamente identifique el comité de directores, en su caso, aun cuando se trate de aquellas indicadas en el inciso final del artículo 147.* Da la oportunidad a que la sociedad misma regulen quienes son sus partes relacionadas, así en el estatuto podría haber otras. Por ejemplo: la ley dice cónyuges o pariente, quizá en el estatuto de la sociedad los socios quieran por precaver decir también el conviviente, que no caería en el N° 2, o un amigo cercano, o un socio de su oficina de abogado. Se da la oportunidad de ampliar el listado del 2 y el 3.
  - 5) *Aquellas en las cuales haya realizado funciones de director, gerente, administrador, ejecutivo principal o liquidador, un director, gerente, administrador, ejecutivo principal o liquidador de la sociedad, dentro de los últimos dieciocho meses.* La ley establece un plazo de operaciones sospechosas. Si dejo hoy el directorio de COPEC y me voy a Falabella, la ley dice que independiente de que haya renunciado como director de COPEC, por el plazo de 18 meses posteriores a la renuncia la ley va a asumir que sigue siendo parte relacionada de la misma.

Por lo tanto, se trata de dos elementos que deben concurrir de manera copulativa:

- i. **Elemento objetivo:** Negociación, acto, contrato u operación.
- ii. **Elemento subjetivo:** Que ese negocio, acto, contrato u operación sea celebrado por alguna de las personas señaladas en el artículo 146. Como este último es lo suficientemente amplio, es muy probable que una transacción relativamente grande caiga dentro de la definición de OPR, porque muchas veces resulta ser que por ejemplo la matriz tenga participación en la sociedad, o que otra sociedad u otra persona del mismo grupo empresarial tenga cierta participación en la transacción. Lo veremos con un caso práctico.

#### **16.4. ¿Son las OPR malas en sí?**

No, podrían haber legítimas razones de negocio para que empresas COPEC quiera comprar celulosa a Arauco, la cual podría tener legítimas razones de negocio para comprar combustible a COPEC. Esta última tiene el 70% del mercado de combustible en Chile y Arauco necesita combustible para sus maquinarias, camiones, etc. Es legítimo, pero como los 2 son miembros de un mismo grupo económico, y los 2 tienen acciones minoritarias, la ley no es que se oponga a la celebración de estos contratos, solo se exige que cumpla con los 2 requisitos copulativos, que veremos a continuación.

#### **16.5. Requisitos OPR**

Una SAA y/o sus filiales, solo podrá llevar a cabo una OPR si se cumplen los siguientes dos requisitos (art. 147 LSA):

- i. **Condiciones sustantivas mínimas:** “cuando tengan por objeto /i/ contribuir al interés social, /ii/ se ajusten en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación”.
- ii. **Procedimiento Regulado:** aprobaciones establecidas en los numerales 1-7 del art. 147 LSA. El procedimiento a través del cual se va a celebrar el contrato.

Proviene de una concepción de los años 40, que decía que cuando hay una OPR la justicia o el fairness, refiere a que no basta que el precio sea un precio justo, sino que la negociación por la cual se llegó a esta, también sea justa, que no haya fuerza desmedida de una empresa sobre la otra, que no haya chantaje, etc.

- i. **Condiciones sustantivas:** Refiriendo en concreto al precio, debe:
  - a) **Se ajusten en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación.** Debe ser precio de mercado, en términos objetivos. No hay razón alguna por la cual Celulosa Arauco le debiese comprar bencina a COPEC a \$1100 el litro, si es que el precio de mercado es otro.
  - b) **Contribuir al interés social:** Hubo discusión sobre a qué se refería con esto, porque podría ser relativamente engañosa. Lo que dice Enrique Alcalde es que nos tenemos que referir necesariamente a utilidad, el negocio que sea útil necesariamente en términos económicos a la sociedad, no nos va a interesar otras consideraciones subjetivas. Cuando decimos “contribuir al interés social” estamos hablando de lucro, que el negocio sea beneficioso a la sociedad, no basta que se desarrolle en términos de mercado.
- ii. **Procedimiento Regulado:** aprobaciones establecidas en los numerales 1-7 del art. 147 LSA.

### **16.6.¿Qué busca el procedimiento regulado?**

Se quiere una negociación justa, especialmente para los minoritarios. Estos son los 3 fines que persigue el procedimiento regulado:

- i. **Obliga a que la operación tenga que ser aprobada expresamente:** Que nadie diga “ay pero si esto lo hacemos siempre, era evidente que le íbamos a comprar a COPEC”. Se quiere aprobación formal, que se ponga en un papel cuál va a ser el precio, la cantidad y a quién se le está comprando.
- ii. **Excluye a los directores y ejecutivos involucrados de la toma de decisión sobre dicha operación:** Se saca a los involucrados y se le pregunta a los demás, para que la operación la lleven los independientes. Cuando se habla de “involucrados” no se define a qué se refiere, pero en el Art. 44 se define el director con interés. La SVS, hoy CMF, dijo al respecto que involucrados se asimila a la definición de interés del Art. 44.
- iii. **En caso que la decisión sea sometida a conocimiento de los accionistas, exige que éstos cuenten con información suficiente (informe de evaluadores, del comité de directores y de los directores individualmente considerados) y logren un acuerdo de 2/3 de las acciones con derecho a voto para aprobar la operación:** Que no se les muestre una operación a medias, solo la versión del directorio con interés, sino que se llama a un tercero evaluador independiente a que opine sobre los términos de esto. Se pide así también a los directores que individualmente, ya no como directores, que pongan su firma, su nombre, afirmando si la operación es justa o injusta. Y por último se pone un quorum más alto que lo habitual: 2/3 de las acciones emitidas con derecho a voto.

### **16.7.Procedimiento Art. 147** (saber en detalle para el examen, en clases se vio resumido)

- i. **Se debe de informar el interés al directorio tan pronto la transacción sea ofrecida o se vayan a iniciar las negociaciones, bajo sanción de responder por los perjuicios ante la sociedad y accionistas.** Esto se ve si se va a la página de la CMF, “ha llegado una oferta de fusión de X a X, y los directores Pedro, Juan y Diego declaran desde ya que tienen interés en ella”. Es lo primero que hay que hacer cuando salga un hecho esencial. Porque si esconden su interés, se exponen a la sanción de responder por los perjuicios personalmente.
- ii. **Aprobación de la mayoría absoluta del directorio, con exclusión del director involucrado:** Es decir, si hay un directorio de 7, y 2 son involucrados, quedan 5, deberá aprobarse por 4 votos, porque 4/7 es mayoría absoluta del directorio
- iii. **Se debe informar la aprobación de la OPR en la próxima junta:** No basta la aprobación del directorio, sino que en la próxima Junta se debe señalar las OPR que se realizaron en el año. La podemos ver también en la página de la CMF en que aparece la memoria de cuáles son las OPR, son varias.

- iv. **Qué pasa si la mayoría absoluta del directorio está involucrado:** Ocurre generalmente cuando el accionista controlador es el interesado, siendo él quien nombra a la mayoría de los directores. Entonces el directorio no va a tener la objetividad para aprobar ellos la transacción, cuando 5 de los 7 están involucrados se lavan las manos y se someten al pronunciamiento de la Junta. Ahí podría ser:
- a) Por la unanimidad de los miembros restantes, cosa poco común; o
  - b) Se somete a la JEA: con 2/3 de las acciones emitidas con derecho a voto. Lo que sucede usualmente es que no hay unanimidad posible porque hay solo 1 director independiente, o simplemente no hay acuerdo, de manera que no se da la primera alternativa.
- v. **Si se convoca a JEA para aprobar la OPR:**
- a) Va a tener que contratarse un Evaluador Independiente designado por el directorio cuya función será informar a la Junta respecto de las condiciones de la operación, sus efectos y potencial impacto, de manera que pueden decir: ojo, los términos de esa operación son condiciones muy malas, les están metiendo el dedo en la boca, o que quizá sí es buena.
  - b) Y si al Comité de Directores no le gusta ese Evaluador Independiente, puede designar un segundo evaluador independiente. Por lo que pueden haber 2.
  - c) Se exige el pronunciamiento individual de cada director sobre la conveniencia de la operación, que expliquen el por qué creen que la transacción se debe celebrar, por qué es buena, que la firme con puño y letra, de manera que se haga responsable de sus palabras.

#### **16.8.¿Sanción si no se sigue el procedimiento?**

*“la infracción a este artículo no afectará la validez de la operación, pero otorgará a la sociedad o a los accionistas el derecho de demandar, de la persona relacionada infractora, /i/ el reembolso en beneficio de la sociedad de una suma equivalente a los beneficios que la operación hubiera reportado a la contraparte relacionada, /ii/ además de la indemnización de los daños correspondientes. En este caso, corresponderá a la parte demandada probar que la operación se ajustó a lo señalado en este artículo”.*

Es decir, no afecta la validez de la operación, pero da derecho a la sociedad o a los accionistas a demandar a la persona o parte relacionada en cuestión, por ejemplo: al controlador, o a un director involucrado. **¿Qué va a demandar?** El reembolso del beneficio de la sociedad en una suma equivalente a los beneficios que la operación le hubiese reportado a la contraparte relacionada, es decir, se hizo la operación, tu sacaste plata indebidamente de la sociedad, reembolsa los beneficios que obtuviste. Y, en segundo lugar, podrá demandar indemnización por todos los daños que ese accionista o que la sociedad hubiere sufrido.

Acá hay un tema procesal muy importante, ya que, si hubo una infracción al procedimiento regulado, se invierte la carga de la prueba, de manera que es el demandado quien debe demostrar que sí se ajustó a lo exigido por la ley, por ejemplo: que sí se ajustó al precio de mercado, por lo que debe llamar peritos, hacer informes de precios, etc. Todo para acreditar que la operación estaba en términos justos.

#### **16.9.Excepciones al Procedimiento Regulado**

Parece ser un procedimiento engorroso, y podría haber operaciones pequeñas respecto de las cuales sería molesto tener que seguir un procedimiento tan complejo. Por ello es que la misma ley consagra ciertas excepciones.

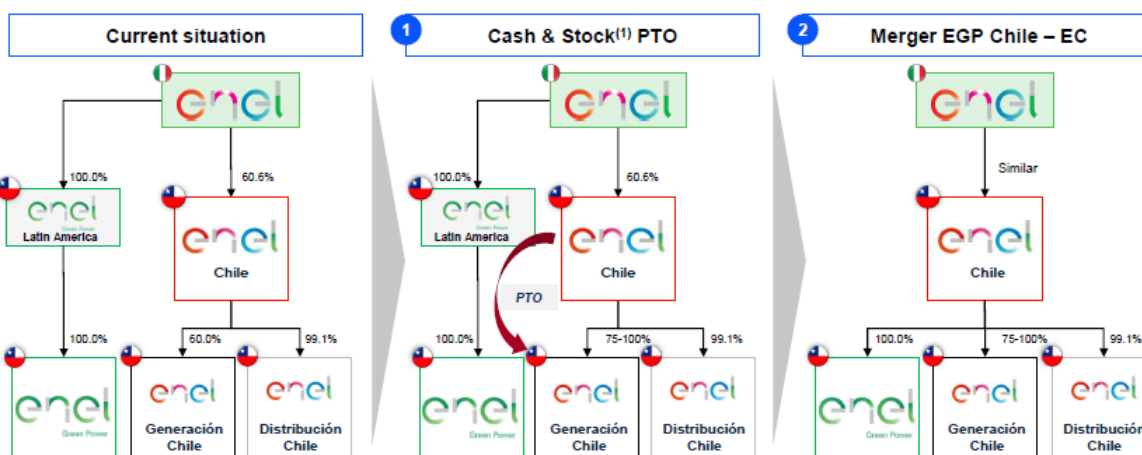
i. **Aquellas que no sean de “monto relevante”, según lo define el 147 letra a).**

a) Aquellas operaciones que no sean de monto relevante. Para estos efectos, se entiende que es de monto relevante todo acto o contrato que supere el 1% del patrimonio social, siempre que dicho acto o contrato exceda el equivalente a 2.000 unidades de fomento y, en todo caso, cuando sea superior a 20.000 unidades de fomento. Se presume que constituyen una sola operación todas aquellas que se perfeccionen en un periodo de 12 meses consecutivos por medio de uno o más actos similares o complementarios, en los que exista identidad de partes, incluidas las personas relacionadas, u objeto.

ii. **Aquellas operaciones ordinarias en consideración al giro social (políticas de habitualidad preestablecidas por el Directorio):** Es probable que Celulosa Arauco compre combustible a COPEC todo el tiempo, porque lo necesita, celebrando contratos por miles de millones al año con COPEC. Sería engorroso que la Junta o el directorio de ambas compañías tuviera que estar todo el tiempo aprobándolo. No funcionaría. Por ello, lo que va a hacer el directorio es establecer una **política de habitualidad**, que dice “nosotros Celulosa Arauco efectivamente compraremos productos a COPEC todo el tiempo en la medida que se cumplan las siguientes condiciones” regulando los términos y condiciones de la política de habitualidad, ya que permite saltarse toda la otra trama burocrática vista.

iii. **Aquellas operaciones entre personas jurídicas en las cuales la sociedad posea, directa o indirectamente, al menos un 95% de la propiedad de la contraparte:** La Ley asume que hay identidad de intereses, que no se trata de intereses contrapuestos. Si una matriz es dueña del 97% de una filial, no tiene muchos incentivos a tratar de perjudicarla, porque a la larga la sociedad de abajo es prácticamente del mismo dueño. Tiene un incentivo del 3% por los accionistas minoritarios, pero probablemente no se va a arriesgar a cobrar precios que considera ilegítimos si los intereses son prácticamente idénticos.

#### 16.10. Caso Práctico



Enel viene haciendo una organización societaria bastante compleja en Chile desde el 2012. Se trataba de una compañía italiana mayoritariamente estatal, con cierta participación de privados, muy grande en Europa, pero pequeña en América con solo Enel Green Power que era energía renovable no convencional. En cambio, están las españolas Endesa y Enersis que eran muy grandes, sobre todo en Chile y en el resto de América (gran parte).

El 2012, Enel la italiana, compra a Endesa España, pero se da cuenta que al mismo tiempo compra toda la línea de negocios que estaba para abajo, que era principalmente Enersis en Chile y toda Sudamérica. Aquí hubo un pequeño conflicto de interés latente de los accionistas minoritarios en Chile y EEUU, porque la sociedad chilena tanto Enersis como Endesa estaban en la bolsa de Nueva York. Ese conflicto consistía en que acá era dueño de Enel Chile de un 60% y de Enel Green Power de un 100%, por lo que tenía un problema. Solo preguntarnos qué pensaba una AFP o cualquier minoritario que entraba a Enel Generación como minoritario, porque cuando a los italianos les llegaba un proyecto bueno de energía renovable seguro lo van a desarrollar con Enel Green Power, porque es totalmente de ellos, mientras que si les llega un proyecto más riesgoso y menos seguro lo van a desarrollar con la otra, ya que el 60% es de ellos, y el otro 40% es de los minoritarios.

Entonces, el 2015 hubo mucho ruido de parte de los minoritarios: “acá hay una cierta injusticia en cómo están puestos tus incentivos (poner todo lo bueno en lo tuyo, y todo lo malo en la mía donde solo tienes un 60%)”. Por ello el mismo año se compromete Italia, admitiendo el conflicto de interés, a que en los próximos 2-3 años se va a solucionar fusionando Enel Green Power Latinoamérica con Enel Chile. Enel Chile por lo demás era la matriz para toda América. Así todos los proyectos fotovoltaicos y eólicos van a quedar en la misma matriz, y no van a poder alegar que se elige lo bueno para uno y lo malo para otro. Esta era la situación de hecho.

Incluso el problema era un poco más complejo, porque había que cumplir con las normas de OPR de Chile y de EEUU.

Ahora, si ya hubo un conflicto de interés en relación a los proyectos, se agrega el conflicto de interés respecto a los términos de la fusión. Se tiene que poner precio a los proyectos que tenía Enel Green Power y a los que tenía Enel Chile Generación. Si el controlador quiere hacer uso malicioso de su condición de influencia, va a valorar muy caros los proyectos en los que él tiene el 100% y va a tirar para abajo de los que es dueño solo de un 60%, porque al fusionar consigue términos de intercambio muchos más beneficiosos, aumentando su participación.

Por ello se contrató a informes de Evaluadores Independientes, y en eso se dirá cuánto vale cada sociedad, en términos de mercado, no pudiendo el controlador poner el precio. Así la Junta puso un precio, cumpliendo todas las reglas. Y así fue como Enel llegó a ser lo que es hoy.

Martes 13 de noviembre de 2018

## **17. AGENCIA DE SOCIEDADES ANÓNIMAS EXTRANJERAS**

- a) **¿Qué es una Agencia de SA Extranjera? (Artículos finales de la ley)** Es un mecanismo por el cual una SA extranjera puede constituir una agencia en Chile.

- b) **¿Cuál es la naturaleza jurídica de esa agencia?** ¿Es persona jurídica nueva? R: NO. Es solo un establecimiento de una persona jurídica extranjera en Chile, pero la ley no le reconoce una entidad particular, sino que simplemente se permite al inversionista extranjero que establezca una agencia en Chile y con eso le da un funcionamiento operativo a su negocio en el país, va a tener RUT, actuará con mayor facilidad en la vida del derecho que si fuese simplemente un inversionista extranjero, podrá designar administradores, alojar un determinado capital, es decir, traer plata desde afuera. Esto no quiere decir que ese capital constituye una limitación a la responsabilidad a las operaciones de la sociedad en Chile o de la agencia en Chile, sino que va a responder primeramente con ese capital, pero luego si es insolvente la agencia chilena, se puede continuar hacia arriba hacia la SA Extranjera por cuanto no constituye una persona jurídica nueva (como ya se dijo), es solo una agencia/sucursal de la SA Extranjera.
- c) **¿Cómo se constituye?** No son los requisitos de la SA, en cuanto aquí no hay una sociedad y la constituye una sola persona. Lo que le exige el legislador está en los artículos 121, 122 y 123 de la LSA, que es básicamente: traer todos los antecedentes legales de la sociedad a Chile y protocolizarlos en una notaría chilena, y el mismo día se otorga una escritura pública con las menciones del Art. 122 en que la sociedad o más bien su representante en Chile declara que se constituye la agencia, y esa escritura pública se va a extraer y publicar, al igual que como fuese una sociedad.
- d) **Utilidad:** Es muy común que cuando un inversionista está entrando al país sus primeros movimientos los haga a través de una agencia, porque es muy fácil de constituir y no requiere tener un socio, un segundo accionista, etc. Por ejemplo: que un nuevo inversionista extranjero quiera participar de una licitación para el MOP, es probable que participe de esta como agencia de sociedad anónima extranjera y después si se le adjudica constituirá una filial y tendrá una sociedad hecha y derecha, pero en el intertanto va a tener solo una agencia para evitar algún problema operativo, tributario, etc.
- e) **Lo novedoso:** no es mucho, ya que aun sin tener agencia en Chile pueden obtener RUT, hay una categoría especial para ellos en el SII, por lo que sí va a poder celebrar escrituras públicas y firmar contratos en Chile. Pero da la sensación de que da más certeza jurídica a la contraparte y permite alocar determinadas cantidades de dinero a modo de capital.

## 18. CONSTITUCIÓN SIMPLIFICADA DE SOCIEDADES

Cuando Chile ingresa a la OSD, realiza en Chile una serie de críticas y sugerencias, una de ellas era que el trámite para desarrollar negocios en el país era muy engorroso, demorando muchos días. Ello impacta mucho en la imagen del país para atraer inversionistas. Solo recordar la polémica con el ranking que el Banco Mundial hizo en el gobierno de Michelle Bachelet. Una de las variables que se miden en el ranking es qué tan fácil es desarrollar negocios.

En el gobierno del Pdte. Piñera, en particular el Ministerio de economía tomó como uno de sus proyectos estrella el simplificar el sistema de constitución y modificación de sociedades. Lo que se denominó el sistema de Empresa en Un Día. Se eliminan a los abogados que intervienen en algo tan simple como constituir una sociedad, se reducen los trámites notariales, los costos de los mismos (ahora gratis), se elimina lo del Conservador de Bienes Raíces (ya no se inscriben en el Registro de Comercio, sino que se registran en un Registro Electrónico). De este modo es posible constituir una

sociedad en un día, y tenerla con inicios de actividades, es decir, se podrá estar firmando contratos, arrendar el local comercial, etc. en 2 o 3 días, en algo que quizá habría demorado 1,2 o 3 semanas.

En la teoría no se podría criticar. Se hizo bien, funciona, el 75-80% de las sociedades se constituye bajo este régimen, pero es un sistema que tiene una serie de limitaciones.

**a) ¿Para quién es útil este sistema?**

Hay que tener ojo a quién se le recomienda la “empresa en un día” y a quien no. Probablemente para un empresario muy chiquitito, un emprendimiento pequeño que quiere tener un solo local comercial, o solo necesita “boletear” ciertos servicios para no hacerlo como persona natural, **le sirve**.

Pero, si es un startup, de alguien con ganas de iniciar un emprendimiento y después, recibir inversionistas que ponen plata, o vender una parte, etc., es decir, transacciones con un nivel de más sofisticación, no le va a servir mucho, porque lo “barato cuesta caro”. Si el emprendedor tiene un afán un poco más sofisticado, ya sea meter fondos de terceros, vender parte de su participación, etc., al tercero que vaya a ingresar no le gustará porque es un sistema rígido, muy simple y su abogado le dirá “transfórmame esta cosa en una sociedad común y corriente y ahí recién te inyecto plata”. Esto no permite regular con mayor fineza los estatutos, pactos de accionistas, etc.

**Esas son las críticas:**

- i. **Es muy rígido**, tratando de sacarle burocracia al sistema en realidad para determinados tipos de inversionistas le pone bastante más. Hay que tener en cuenta que si no se tiene firma electrónica avanzada hay que ir a la notaría para que el notario firme en tu representación (ya que él sí tiene firma electrónica avanzada) y eso quita mucho tiempo, desgasta recursos, hay que llenar formularios, etc. y el cliente, de buena situación no va a querer ir a cada rato a la notaría cuando no tenga esa firma electrónica (la mayoría de la gente no la tiene). En cambio, en caso de una constitución normal no se da tal problema.
- ii. **En SpA y SA todo se hace por instrumento privado que se reduce a EP**. De hecho, en la práctica (no digan que lo dijo el profe D:) las JA no existen, basta con tener un acta de junta de accionista y los socios firman, sin necesidad de junta real física. Pero, con esto simplificado se requiere hacer una junta de verdad, ya que el notario va a exigir que vayan un determinado día, a una determinada hora.
- iii. **Es un formulario, lo cual por definición no da suficiente flexibilidad**, podría querer regular otras series de acciones, más ventajas, etc. No regula super a fondo las materias de juntas de accionistas (extraordinaria, ordinaria), no podemos definir cuál será una OPR (operación con partes relacionadas), etc.

La **ventaja** será para aquel que quiera un negocio chiquitito, ya que le quita burocracia.

**b) Registro electrónico de empresas y sociedades del Ministerio de Economía (página web)**

- 
- A. **Si ya se tiene una sociedad:** se va a tener un usuario, y se pueden poner “aumentos de capital”, “cambiar administrador”, etc. Se llena un formulario, luego va a dar un numerito, el cual hay que llevar a firmar a notaría.
- B. **Si todavía no se tiene una sociedad:** hay que ir a “constituir”. (Esto es cuando el profesor explicó en la página ☺, es solo para que entiendan)
- a) Se puede SRL, EIRL, y SpA (creo, pero eran 3). Supongamos que queremos una SpA. Veremos que no requiere de un abogado, la que es un formulario nada más.
  - b) Se coloca un nombre de fantasía como “Banco del Estado de Chile”, y el oficial “Banco Estado”, pero no es obligatorio
  - c) Domicilio tributario: puede ser el de uno de los socios, se utiliza como domicilio social, y permite que te den el RUT al tiro.
  - d) Objeto: para aquellos que no saben lo que es el objeto, te tira sugerencias. “Fabricación de relojes y muebles”, etc.
  - e) Capital de la sociedad: Lo hicieron bien, ya que se pone el monto del capital y da la alternativa de tener series de acciones, lo cual es un poco más sofisticado y menos común (se dieron la lata de introducir). Y el plazo para pagar, por ejemplo, los 45 millones faltantes que el profesor puso, con un máximo de 36 meses para entregar ese capital. Pero se podría subir a 60, que son los 5 años por la ley de SpA.
  - f) Número de acciones: acá se puede establecer series de acciones. Incluye el tipo de voto, y el profesor señala que es de una legalidad discutida, ya que en las SA se prohíben las acciones de voto múltiple (La discusión va a si es una norma de orden público o no). Se pueden elegir los derechos políticos y económicos que se ocurran y estén permitidos.
  - g) Valor nominal las acciones: SIEMPRE PONER NO
  - h) Laminas físicas de las acciones: SIEMPRE PONER NO
  - i) Gozarán de algún Derecho las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado: NO.
  - j) Duración: (no se dijo nada).
  - k) Administración social: Si son 3 socios y dicen “vamos a administrar por directorio” sería un cacho, porque habría que hacer sesiones de directorio y otro tipo de trámites más complejos. Es más conveniente para un emprendedor pequeño poner simplemente un administrador, que administre una sola persona y así la designe al tiro
  - l) Facultades de la administración: es importante que están listadas, se trata de un formulario de poder típico, se va designando cuáles le sirven y cuáles no.
  - m) Comunicación de la sociedad y sus accionistas (opcional): se coloca cuál va a ser el medio de comunicación, si es un emprendedor pequeño poner correo electrónico o carta certificada.
  - n) Juntas ordinarias de accionistas: poner una vez al año, durante el primer cuatrimestre default.
  - o) Arbitraje: Aquí se cayó, puso default al árbitro arbitrador. NO elegir árbitro arbitrador, porque a menos que tengamos certeza absoluta de quién es nuestra contraparte y nuestro arbitro se sugiere no elegir cual será le arbitro arbitrador porque no se sabe quién va a resolver una eventual disputa, cuál será la disputa ni cuanta confianza se tendrá con esa persona en particular. En cambio, si pongo arbitro mixto, conozco al menos las normas legales a las que me voy a someter. Si es un emprendedor pequeño elegir un solo árbitro, porque una comisión saldría muy cara. Da la alternativa de poner en la cláusula compromisoria el nombre del árbitro, pero es preferible poner un árbitro designado por la justicia, si no elegir el CAM o el CNA.
  - p) Distribución de utilidades: por default en relación a los aportes, a prorrata de su participación accionaria. O podemos complementar el privilegio o las preferencias de acciones, etc.

- q) Agregar otros pactos a los estatutos: aquí sugiere pedir ayuda a abogado. Aquí se puede agregar algún derecho preferente.
- r) **Luego, uno apreta seguir y arroja un texto refundido que hay que ir a firmar a la notaría.**

### Caso práctico:

Dos amigos del profesor, uno del colegio y otro de la universidad. Al quinto año de universidad uno de ellos comienza a desarrollar una receta para un producto alimenticio en su casa, le queda tan rico que consigue que sus papás le presten la mansarda de su casa y le pone baldosa para logra sacarle resolución sanitaria. Este producto dice que fue fabricado en una dirección en Lo Barnechea (su casa), porque fabricaba el producto en el segundo piso de su casa.

Alguien que parte cocinando algo en su casa, luego llega a los restaurantes, hasta entrar al Líder o Jumbo, naturalmente, no quiere ni tiene para gastar 200 lucas, etc. para constituir sociedad. A ellos les dio vergüenza preguntarle al profesor, por lo que fueron a empresa en un día. Les funcionó muy bien, constituyeron sin asesoría de abogados. Se les ocurrió con el agravante que constituyeron una limitada y no establecieron reglamentación para la cesión de derechos de acciones.

Pasan los meses, años, les va muy bien, ganan todos los capitales de semilla de CORFO, etc. Y el socio minoritario de esta Ltda., dueño del 20% se empieza a poner un poco pesado, y habían puesto administración conjunta de dos socios, y teniendo en cuenta que tenían muchas ordenes de entrega, había mucho movimiento. Pero **¿qué herramienta usó el socio minoritario?** bloquear la firma conjunta, dijo: “no te firmo nada”. Siendo un emprendimiento top ayudado por la CORFO que estaba creciendo, estuvo bloqueado cerca de un año por un conflicto entre los socios, todo porque ningún abogado les dijo: “oye si lo vas a hacer en la casa de tus papás y vas a tener el 80%, tú debes tener la administración, no los dos”. En esa época, se solucionó, se le compró el 20% muy caro a ese socio que estaba chantajeando, le pusieron cláusula de no competir por 3 años. Ahora ya volvió y está compitiendo.

Después entró el amigo del profesor. Tuvieron que ir con estos papeles a Philippi, asesores legales de los inversionistas. Los inversionistas eran gente de mucha plata y los atiende un socio de Philippi muy reconocido. Le ponen encima de la mesa la sociedad sobre la cual su cliente, un inversionista de mucha plata, tenía que invertir. Imaginen la reacción de un socio abogado de uno de los estudios más prestigiosos de Chile cuando le ponen un formulario del ministerio de economía de empresa en un día. El socio les dijo que no dejaría que inviertan un peso en su sociedad hasta que constituyan una Sociedad de verdad.

Para peor, en ese año el registro de empresas y sociedades por un problema legal tuvo bloqueadas las migraciones desde el Ministerio de Economía al conservador de bienes raíces (migrar es el trámite en el cual se modifica una sociedad de registro). El profesor lo solucionó con una cláusula de un pacto de accionistas en que se obligaban a que tan pronto se abriera el sistema de migraciones, suscribir determinada escritura de migración (se dejó negociada en ese minuto y anexa al pacto) para irse al registro tradicional. Más aun, dijeron que, si es que a determinada fecha no habían podido migrar, iban a crear una nueva sociedad matriz de la otra y le iban a comprar todas las acciones a la primera. Fue exitoso, se reabrió el sistema de migraciones a principios de este año. Se fueron al conservador de bienes raíces.

Martes 30 de octubre de 2018

## VI.

# SOCIEDADES POR ACCIONES

### 1. GENERALIDADES

Las sociedades por acciones se incorporaron a nuestro código de comercio mediante la ley 20.190, que vino a realizar distintos cambios en nuestro ordenamiento comercial y uno de estos fue el incorporar esta nueva figura social. Las sociedades por acciones

Definición: Art. 424: *Es una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado de acuerdo a los preceptos siguientes, cuya participación en el capital es representada por acciones"*

Esto ya suena raro, ya que antes se definía una sociedad como un contrato. Esta sociedad en particular pese a llamarse como sociedad, no está definida como contrato. En la actualidad, nadie duda de su calidad de sociedad.

### 2. ORIGEN

Origen: Ley 20.190, Ley de Mercado de Capitales II, modifica el libro II, título VII, de nuestro Código de Comercio. Artículos 242 al 446. Su objeto fue fomentar la industria del capital de riesgo. Se quiso fomentar que pequeños y medianas empresas que no tenían acceso a créditos, pudieran constituirse de esa forma, limitando su responsabilidad y así en el fondo generar dinero.

### 3. CARACTERÍSTICAS

- A. **Se admite la posibilidad de crear una sociedad unipersonal (A 424):** por primera vez en nuestro ordenamiento se reconoce la posibilidad de que una sociedad sea constituida por una sola persona.
- B. **Es una sociedad de capital (A 424):** se relaciona con que se buscaba potenciar los capitales de riesgo. Se fomenta a que aquellas personas que no tenían socio, o faltaba capital, lo hagan, porque esta es una figura bastante flexible.
- C. **Accionistas responden hasta monto de sus respectivos aportes (429):** todos los socios que después entran a participar después, su monto estará limitado al valor de las respectivas acciones.
- D. **"Posee" un régimen corporativo de funcionamiento (424 inc. 2):** dice relación con que la sociedad y su funcionamiento va a estar regulado por normas legales de carácter corporativo. La ley regula la participación de los socios, etc. Está entrecomillas porque el legislador es un poco más flexible, se da espacio a los socios, para que mediante la autonomía de la voluntad puedan ver cómo va a estar regulado el funcionamiento de la sociedad en los estatutos. Si los estatutos nada dicen, supletoriamente el legislador se encarga de señalar que en subsidio se aplicarán las

normas de las SA Cerradas. Por eso se dice que tiene un régimen corporativo de funcionamiento y demás pactos (supletorio).

**Art. 424 inciso segundo.** La sociedad tendrá un estatuto social en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de los accionistas, el régimen de su administración y los demás pactos que, salvo por lo dispuesto en este Párrafo, podrán ser establecidos libremente. En silencio del estatuto social y de las disposiciones de este Párrafo, la sociedad se regirá supletoriamente y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas.

E. **Son siempre mercantiles (A 425 n°2):** Independiente del giro de la sociedad por acciones.

#### 4. CONSTITUCIÓN

(Artículo 425 Coco): **“La sociedad se forma, existe y prueba por un acto de constitución social escrito, inscrito y publicado”.**

El *acto de constitución* puede realizarse: i) por escritura pública o ii) instrumento privado suscrito por sus otorgantes cuyas firmas sean autorizadas por notario público, y sea protocolizado (esto último es una novedad).

Luego debe realizarse un extracto del acto de constitución, autorizado por el notario, que debe inscribirse en el Registro de Comercio respectivo y publicarse una vez en el diario oficial, dentro del mes siguiente a su celebración (distinto a SA, que es de 60 días).

##### 4.1. Contenido de los estatutos (A 425):

- a) **Nombre de la sociedad** que concluya con “SpA”
- b) **Objeto de la sociedad** (siempre mercantil)
- c) **El capital social y el número de acciones en que está dividido** (pueden haber series de acciones)
- d) **La forma en que se realizará la administración de la sociedad y la designación de sus representantes**
- e) **Duración de la sociedad**, que será indefinida si nada se dice

##### 4.2. Contenido del extracto (A 426):

- A. Nombre de la sociedad
- B. Nombre de los accionistas concurrentes al acto constitutivo
- C. El objeto social
- D. El monto al que asciende el capital suscrito y pagado de la sociedad
- E. La fecha de otorgamiento, el nombre y domicilio del notario que inscribió la escritura o protocolizó el documento privado.

#### 5. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES (427)

- a) **Por acuerdo de la junta de accionistas**, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública

- b) **También podrán ser modificados por un acuerdo unánime de los accionistas mediante escritura pública o instrumento privado protocolizado en que conste tal modificación** (una novedad, de mayor flexibilidad).

Al igual que en las otras sociedades, debe realizarse un extracto del acto de modificación, autorizado por el notario, debe inscribirse en el registro de comercio respectivo y publicarse una vez en el diario oficial, dentro del mes siguiente a su celebración.

**Sanción en caso de omisión de las formalidades (Art. 428 Coco) (Tanto de constitución como de modificación)**

- Nulidad absoluta de pleno derecho: Solo se aplica en aquellos casos en que el acto en sí no ha sido otorgado por escritura pública ni por instrumento privado firmado ante notario y protocolizado; en esos dos casos. Todos los demás casos la ley permite un mecanismo para sanear el vicio.
- Nulidad saneable (Ley 19.499)

**6. CONVERSIÓN DE LA SPA A UNA S.A. ABIERTA (Art. 430 Coco):**

Esta conversión opera por el solo ministerio de la ley cuando se cumplan los requisitos de los números 1) o 2) del inciso segundo del art. 2 de la ley 18.046, esto es que la SpA reúna por más de 90 días 500 o más accionistas o al menos el 10% de su capital esté en manos de un mínimo de 100 accionistas (responde al objetivo del legislador de que se trataría de sociedades más pequeñas, por lo que cuando creciera, reguló esta situación).

Artículo 430.- La sociedad por acciones que durante más de 90 días seguidos tenga 500 o más accionistas o, a lo menos, el 10% de su capital suscrito pertenezca a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a través de otras personas naturales o jurídicas, excedan dicho porcentaje, por el solo ministerio de la ley se transformará en una sociedad anónima, **siéndole totalmente aplicables las disposiciones pertinentes de dicha ley, las que en este caso prevalecerán sobre el estatuto social**. La siguiente junta de accionistas deberá resolver las adecuaciones que reflejen la nueva modalidad social y elegir los miembros del directorio que continuará la administración.

La siguiente junta de accionistas deberá resolver las adecuaciones que reflejen la nueva modalidad social y elegir los miembros del directorio que continuará la administración.

**7. ADMINISTRACIÓN DE LA SPA (Art. 424)**

En la práctica, la administración de la sociedad por acciones va a depender de lo que se establezca en los estatutos.

La sociedad tendrá un estatuto social donde se deben establecer los derechos y obligaciones de los accionistas y el régimen de su administración. Supletoriamente, se aplican normas aplicables a las SA Cerradas (18.046): Directorio, junta de accionistas y órganos inspectores o auditores externos.

**8. CAPITAL DE LA SPA**

Se dividirá en acciones que pueden ser ordinarias o preferidas, en soporte material o no (puede ser documento electrónico, una novedad, pero debe quedar registro de ello en los estatutos). El capital se rige por los siguientes principios:

- A. Principio de fijeza o inmutabilidad: se establece de manera invariable en los estatutos, solo puede variar por una reforma de estatutos.
- B. Principio de efectividad o integración, el capital debe ser real y efectivo: el capital social y sus aumentos deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo que se indique en los estatutos, o en su defecto, en 5 años, si no se reduce de pleno derecho. [se refiere más al aumento de capital].
- C. Principio de conservación: debe conservar su valor durante la vida de la sociedad.

#### **8.1. Casos de acuerdos en los estatutos sociales que pueden limitar la participación de los socios en el capital social (435):**

- Dentro de los estatutos se pueden establecer **porcentajes o montos mínimos de capital** que podrán ser controlados por uno o más accionistas (elemento accidental de los estatutos). Si no se hacen estas estipulaciones, se tendrán por no escritas.
- Se pueden pactar ciertas circunstancias en las cuales **se puede exigir a los accionistas la venta de todo o parte de sus acciones**, ya sea a favor de la sociedad o de un tercero. Son pactos que pueden incorporarse en los estatutos.

#### **8.2. Acciones de propia emisión (art. 438):** no se mencionó, pero recomiendo leer artículo.

#### **9. DIVIDENDOS DE UTILIDADES DE UNIDADES DE NEGOCIOS O ACTIVOS ESPECÍFICOS (Art. 443)**

Este artículo contempla una novedad que tiene por objeto incentivar la creación de este tipo de sociedades e incrementar el capital de riesgo, autorizando el pago de dividendos provenientes de unidades de negocios o activos específicos.

Requisitos: debe llevar cuentas separadas (si no se utilizan, se integran a los resultados generales). En este caso lo que se permite es que la repartición de utilidades no se haga al momento en que termine el ejercicio respectivo, sino que cuando termine un negocio específico.

#### **10. TEMAS IMPORTANTES**

##### **10.1. Derecho de suscripción preferente (439)**

En caso de emisión de acciones de pago, el derecho de suscripción preferente no es obligatorio como en las S.A., solo existirá si en los estatutos se establece.

##### **10.2. Registro de accionistas (431)**

Como sociedad de capital, la SpA. debe contar con un registro de accionistas (en cualquier medio que garantice su integridad) que indique a lo menos: Nombre, domicilio, cédula de identidad y número de acciones. Además, debe indicar gravámenes en el caso de existir. Es responsabilidad de la Administración (y el gerente general).

**10.3. Traspaso de acciones (446)**

Dentro del traspaso de acciones, el cesionario debe hacer una declaración, referente al conocimiento de la normativa y estatutos. Si no lo contiene, la cesión es válida, pero el cedente queda responsable de los perjuicios.

**11. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SPA**

La ley no establece normas específicas por lo que se regula por la legislación supletoria (SA Cerradas). Art. 444: Salvo que los estatutos dispongan lo contrario, la SpA no se disuelve por la reunión de todas las acciones en manos de un solo accionista.

## VII.

# **LEY DE SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE NULIDAD**

### **(LEY 19.499)**

#### **1. SITUACIÓN ANTERIOR A LA LEY 19.499**

Incumplimiento de las formalidades de constitución de una sociedad: Nulidad absoluta. La sociedad es un contrato (art. 2053 del CC) y como tal se le aplican las normas de nulidad establecidas en ese cuerpo legal. Por tanto, había un régimen único.

Artículo 1681 del CC: “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estados de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa”.

Artículo 1682 del CC: “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, ...”

Conforme al artículo 1683 del CC la nulidad absoluta:

- No puede convalidarse por la ratificación de las partes
- Solo puede sanearse por el lapso de 10 años
- Puede alegarse por todo el que tenga un interés en ello (Excepto quien ejecutó el acto sabiendo o debiendo conocer el vicio)
- Debe ser declarada por el juez cuando aparece de manifiesto

**Efectos de la declaración de nulidad de una sociedad en el antiguo régimen:** (tener en cuenta la fe pública, un tema de proteger a terceros que de buena fe contrataban con la sociedad)

- Los socios quedaban **solidariamente responsables** frente a los terceros que hubieren contratado con la sociedad
- Los socios **no podían oponer a los terceros los incumplimientos de las solemnidades**
- Los **terceros podían acreditar la existencia de la sociedad por cualquier medio**
- Conflictos entre terceros (acreedor social y acreedor de un socio), **el que tenía interés en la existencia de la sociedad debía acreditarla**
- **Caso del tercero deudor.** No está legitimado para pedir la nulidad
- **Modificaciones sin cumplir solemnidades, eran inoponibles a terceros** (además de ser nulas entre los socios)

#### **2. RÉGIMEN VIGENTE: LEY 19.499**

Esta ley se publicó el 11 de abril de 1997. Viene a distinguir entre la nulidad absoluta de pleno derecho y **además una nulidad saneable**.

Cuando la sociedad no conste en Escritura pública o en un instrumento reducido a escritura pública o en un instrumento protocolizado, la sanción será la nulidad de pleno derecho (que no requiere declaración judicial y que además no puede ser saneada).

Todas aquellas sociedades que sí sean constituidas por escritura pública o instrumento reducido a escritura pública y protocolizado, pero al cual no se le haya dado cumplimiento a todas las formalidades o requisitos formales (que no se cumpla dentro del plazo, que se omitan algunas enunciaciones, etc) van a adolecer de un vicio de nulidad, pero que podrá ser saneado.

### **2.1. Ámbito de aplicación de la ley 19.499:**

En conformidad con el art. 1 de la ley, esta aplica a:

1. Soc. colectivas Mercantiles
2. Soc. de responsabilidad limitada
3. Sociedades en comandita mercantiles y por acciones
4. Sociedades anónimas
5. Luego se incorporaron la EIRL y la SpA

No se aplica a la sociedad colectiva civil, porque son consensuales y no tienen las formalidades.

### **2.2. Ámbito de aplicación material:**

Esta ley solo permite sanear los **vicios formales**, que son aquellos que consisten en “*el incumplimiento de alguna solemnidad legal, tales como la inscripción o publicación tardía del extracto de la escritura, o falta de cumplimiento o cumplimiento imperfecto de las menciones que la ley ordena incluir en las respectivas escrituras, como, por ejemplo, lo relacionado con la razón social*” (art. 1 inc. 3 ley 19.499)

La norma se limita a enumerar de manera meramente enunciativa algunos vicios. Utiliza expresiones como: “tales como” o “por ejemplo”. Ejemplos: (Recomiendo leer el artículo)

- Si falta extracto o este omite alguna de las menciones esenciales que prescribe la respectiva ley
- Contradicciones entre las menciones de las escrituras sociales y las indicaciones del extracto
- Inscripción y/o publicación del extracto fuera del plazo de 60 días fatales ordenados por la ley (en caso de SpA).

### **2.3. Vicios que no requieren saneamiento (art. 9 de la ley)**

Establece estos casos que no requieren saneamiento. No constituyen vicios formales de nulidad de una sociedad o de sus modificaciones y, por lo tanto, no requieren ser saneados, los siguientes errores que puedan contener las correspondientes escrituras públicas, o sus extractos inscritos o publicados:

- a) Errores gramaticales u ortográficos
- b) Errores numéricos
- c) Errores en los datos o características

### **2.4. Vicios de fondo (art. 1 inc. 4 de la ley)**

“Los defectos relativos al contenido de las escrituras no se considerarán vicios formales, sino de fondo, si implican la privación de algún elemento esencial al concepto de sociedad o algún vicio de carácter substancial de general aplicación a los contratos” **Se contraponen a los vicios formales y no admiten saneamiento.** Entonces la ley se refiere a vicios formales (y estos son los que se sanean), no de fondo.

Ejemplos:

- Omisión o defectos relativos a los requisitos propios de la sociedad: estipulación de aportes, participación utilidades o periódicas, affectio societatis, etc.
- Elementos particulares que caracterizan un tipo societario determinado
- Omisión o defectos de requisitos de existencia o de validez del contrato.

## **2.5. Requisitos exigidos y forma de hacer el saneamiento**

- a. Se requiere que el acto fundacional o la reforma, consten de escritura pública o instrumento reducido a escritura pública o instrumento protocolizado
- b. No se establece un plazo para realizar el saneamiento, pero si dice expresamente que incluso podrá sanearse antes de la sentencia ejecutoriada.
- c. Debe otorgarse una escritura pública, cuyo objeto exprese la voluntad de sanear los vicios u omisiones y proceder a corregirlos
- d. Un extracto de la escritura debe inscribirse y publicarse dentro de los 60 días a su otorgamiento.

Art. 4 de la ley 19.499: Señala las menciones del extracto.

- Fecha de la escritura
- Nombre y domicilio del notario
- Fecha de la escritura pública en que consta en el acto que se sana
- Indicar cuales son los vicios que se corrigen en el acto: los saneables y de forma.

### **Casos particulares:**

-Soc. colectiva comercial por ser una sociedad de personas, deben concurrir los socios en la escritura de saneamiento. Deben ser los socios al momento de celebrar la escritura de saneamiento.

-Sociedad de responsabilidad Limitada (lo mismo)

-En comandita simple (además de lo anterior, debe concurrir además los cedentes y los cesionarios que celebraron ese acto)

-Sociedades anónima o en comandita por acciones: En JEA se levantará acta y reducirá a escritura pública.

### **Saneamiento de vicios anteriores a la ley 19.499:**

La ley permite el saneamiento de vicios que adolezcan sociedades constituidas o modificadas antes de su entrada en vigencia.